

Republique du Sénégal
Primature
AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

**BULLETIN DES DÉCISIONS
ET AVIS RENDUS
PAR LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS**

ANNÉE 2016

Edition 2018

SOMMAIRE

PREFACE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLIC (ARMP).....	4
INTRODUCTION.....	6
1- INAPPLICABILITE DU CODE DES MARCHES PUBLICS AU CONTRAT DE LOCATION SIMPLE (ARTICLE 4 DU CODE DES MARCHES PUBLICS).....	7
2- NULLITE ABSOLUE DU CONTRAT CONCLU PAR UNE PERSONNE INCOMPETENTE (ARTICLES 21 ET 22 DU COA ET ARTICLE 27 DU CODE DES MARCHES PUBLICS).....	12
3- INAPPLICABILITÉ DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BÂTIS OU DE TERRAIN (ARTICLE 4 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)	18
4- INCOMPÉTENCE D'UN COMPTABLE PUBLIC À REMETTRE EN CAUSE UNE QUALIFICATION D'UN MARCHÉ PUBLIC VALIDÉE PAR LA DCMP (ARTICLE 30 DU COA ET ARTICLE 6 DU CODE DES MARCHES PUBLICS).....	24
5- LA SIGNATURE DU PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX (DRP) DISPENSÉE D'UNE FORME ÉCRITE N'EST PAS DEVOLUE A LA COMMISSION DES MARCHÉS (ARTICLE 78 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET ARRÊTÉ N°0017 DU 7 JANVIER 2015).....	30
6- LES CONCILIATIONS (ARTICLES 30 NOUVEAU ET 45 DU COA, ARTICLE 138 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS, ARTICLE 2 DU DÉCRET N°2007-546 DU 25 AVRIL 2007, ARTICLE 16 DE LA LOI DES FINANCES 2016).....	32
6-1 Après exécution d'un marché entaché de vices, il est possible d'indemniser l'entreprise ayant fourni des prestations avec l'assentiment de l'autorité contractante (article 45 du COA)	
6-2 La résiliation unilatérale du marché par l'autorité contractante ouvre droit à une indemnité au bénéfice de l'attributaire (articles 137 et 138 du COA)	
6-3 Le retard accusé par l'attributaire du marché dans l'exécution des travaux peut entraîner son dessaisissement partiel au profit de sous-traitants	
6-4 L'impossibilité pour l'attributaire de livrer le véhicule objet du marché, peut être réglée par la livraison, en substitution, d'un autre véhicule de gamme supérieure	
7- LE CRD EST INCOMPETENT A L'EGARD DES MARCHÉS DES ASSOCIATIONS DE DROIT PRIVÉ, DES MARCHÉS DE CERTAINES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVÉ ET DES MARCHÉS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES OBÉISSANT À DES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES.....	48
8- LES RECOURS DECLARÉS IRRECEVABLES PAR LE CRD.....	56
8-1 Irrecevabilité pour forclusion	
8-2 Irrecevabilité pour absence de recours gracieux préalable	

8-3 Irrecevabilité pour absence de consignation	
8-4 Irrecevabilité pour inobservation du délai d'attente du recours gracieux	
8-5 Irrecevabilité pour saisine avant notification de l'avis d'attribution provisoire	
8-6 Irrecevabilité pour absence de grief	
9- LA COMMISSION DES MARCHÉS QUI REJETTE PAR DÉCISION MOTIVÉE UNE OFFRE ANORMALEMENT BASSE NE VIOLE PAS LA LOI (ARTICLE 59-4 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS).....	76
10- PEUT ÊTRE CLASSÉ SANS SUITE UN APPEL D'OFFRES DONT LES MONTANTS DES OFFRES DÉPASSENT LE BUDGET PRÉVISIONNEL (ARTICLE 65 DU CODE DES MARCHES PUBLICS).....	85
11- LA NON PUBLICATION D'UN MARCHÉ DANS LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES AVANT SON LANCEMENT ENTRAÎNE SON ANNULATION (ARTICLE 76-2 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET ARTICLE 24 NOUVEAU DU COA).....	94
12- L'IRRESPECT DES CONDITIONS ET SPECIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES ENTRAÎNE LE REJET DE L'OFFRE (ARTICLE 68 DU CODE DES MARCHES PUBLICS).....	100
13- LA NON VALIDITÉ DE LA GARANTIE DE SOUMISSION ENTRAÎNE LE REJET DE L'OFFRE (ARTICLES 44 ET 114 DU CODE DES MARCHES PUBLICS).....	106
14- L'ABSENCE DE SOUS- CRITÈRE PRÉCIS D'ÉVALUATION EST SOURCE DE SUBJECTIVITÉ ENTRAÎNANT UNE RUPTURE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES CANDIDATS (ARTICLE 24 NOUVEAU DU COA).....	114
15- L'IRRESPECT DE L'OBLIGATION DE NOTIFICATION DES NOTES TECHNIQUES AU MOMENT INDICÉ ET LE FAIT DE NE PAS LES LIRE À HAUTE VOIX À LA SÉANCE D'OUVERTURE DES OFFRES FINANCIÈRES PORTENT ATTEINTE AU PRINCIPE DE TRANSPARENCE.....	126
16- LES MANQUEMENTS DU CANDIDAT RELATIFS À L'EXÉCUTION DE MARCHES ANTERIEURS DOIVENT ENTRAÎNER LA SAISINE DU CRD (ARTICLE 148 DU CODE DES MARCHES PUBLICS).....	135
17- L'APPEL D'OFFRES EST LE PRINCIPE ET L'ENTENTE DIRECTE OBEIT À DES CONDITIONS LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉES PAR LA LOI (ARTICLE 26 NOUVEAU DU COA, ARTICLE 76 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET ARTICLE 38 DE LA DIRECTIVE 4/2005/UEMOA).....	143
18- LA DÉROGATION D'OUVRIR UN MARCHÉ À L'INTERNATIONAL NE SE LIMITE PAS AU SEUL CAS D'INEXISTENCE DE COMPÉTENCE DANS L'ESPACE UEMOA (ARTICLE 52 DU CODE DES MARCHES PUBLICS).....	150
19- LES MARCHÉS À COMMANDE SONT SOUMIS À L'AVIS DE LA DCMP QUEL QUE SOIT LEUR MONTANT (ARTICLE 141 DU CODE DES MARCHES PUBLICS).....	157

PREFACE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLIC (ARMP)

L'autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a pour attributions, entre autres, de veiller au respect de la réglementation dans le domaine des marchés publics et de contribuer à la formation des acteurs de la commande publique.

Pour les mener à bien, non seulement elle met en œuvre des procédures d'audits réalisés par des cabinets indépendants, mais également elle tranche les litiges dont elle est saisie.

En effet, son Comité de Règlements des Différends (CRD) a pour compétence de régler les conflits qui naissent dans le processus de passation et d'exécution des marchés publics.

Pour ce faire, lorsqu'un différend lui est soumis, le CRD rend des décisions et des avis, procède à des conciliations et prononce des sanctions.

Pour garder la pratique du CRD dans les standards internationaux, depuis plus de quatre ans, l'ARMP soumet régulièrement l'ensemble des actes du CRD à l'analyse critique de spécialiste du droit neutre et indépendant.

Le dit spécialiste, dans un premier temps, exploite et analyse les actes pris par le CRD ; il a pour mission de s'assurer de leur pertinence et de leur cohérence au regard, non seulement du cadre juridique communautaire et national, des arrêts de la Cour Suprême et de la jurisprudence française, mais également par rapport à leur impact sur l'efficacité du système de passation des marchés publics en vigueur depuis 2008 dans le cadre de l'UEMOA.

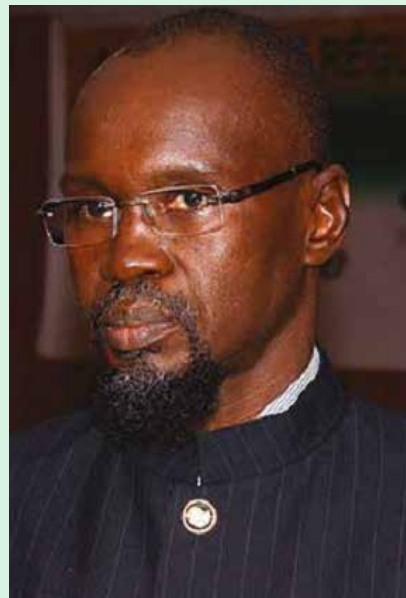
Dans un second temps, le spécialiste en question conçoit un bulletin des décisions, des avis et des conciliations.

C'est dans ce cadre que le présent bulletin, qui est le troisième en la matière, est édité.

Il est destiné aux acteurs du système de passation des marchés publics, notamment aux autorités contractantes, aux opérateurs économiques, aux bailleurs de fond, à la famille judiciaire et au monde universitaire.

Il regroupe l'essentiel des décisions, avis et conciliations rendus par le CRD en 2016, commentés par un consultant sélectionné à la suite d'une procédure concurrentielle.

La publication de ce bulletin est devenue une tradition à travers laquelle l'ARMP met régulièrement à la disposition des acteurs un document commenté pour provoquer



un débat public dans lequel les universitaires, les avocats et experts en passation des marchés publics auront l'opportunité de formuler leur opinion sur la pratique du CRD.

Par ailleurs, c'est parce qu'elle est convaincue que le Code ne doit pas être seulement pour des questions de célérité et de transparence, mais qu'il doit être aussi un moyen de développer et de renforcer les capacités des acteurs, que l'ARMP s'investit, sans relâche, dans la formation et l'édition de bulletin et de guides.

Ce bulletin, qui s'ajoute aux autres guides élaborés par l'ARMP, permet aux acteurs de la commande publique de se former et d'éviter des erreurs au niveau de toutes les étapes du processus des marchés, de l'identification à la liquidation, en passant par la préparation, l'attribution, l'exécution et la réception, et de minimiser les risques de rejet de leur dossier et de leur recours au niveau des différents organes d'attribution, de contrôle et de régulation.

Nous invitons l'ensemble des acteurs à visiter le bulletin et de nous faire parvenir leurs observations afin que nous puissions mieux servir le système de passation des marchés publics.

Saer NIANG

Directeur Général de l'ARMP

INTRODUCTION

La mission d'exploitation et d'analyse des décisions et avis rendus par le CRD de 2008 à 2013 avait permis d'élaborer et de publier le premier bulletin des décisions et avis regroupant vingt-six (26) thèmes.

Celle relative aux décisions des années 2014 à 2015 avait débouché sur la réalisation du second bulletin comptant vingt-et-un (21) thèmes et dix (10) sous-thèmes.

Le présent bulletin, qui est le troisième en la matière, a été conçu et édité à partir de l'exploitation et de l'analyse des décisions, des avis et des conciliations du Comité de Règlement des Différends de l'année 2016, deuxième année de l'application du Code des marchés publics de 2014.

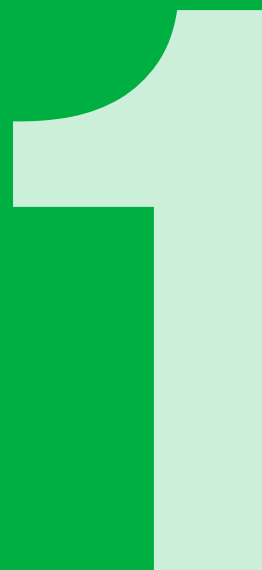
Il apporte une plus-value par rapport aux deux premiers bulletins, car pour la première fois des conciliations sont publiées ; ceci, dans le but d'embrasser l'ensemble des activités du CRD et de maintenir la complémentarité devant exister entre les bulletins successifs.

En effet, il renferme dix(10) sous-thèmes, relatifs aux conciliations (4) et aux causes d'irrecevabilité (6), et dix-neuf (19) thèmes principaux dont douze (12) nouveaux.

Parmi les douze nouveaux thèmes principaux, on compte, entre autres :

- L'inapplicabilité du code des marchés publics au contrat de location simple ;
- La nullité absolue du contrat conclu par une personne incompétente ;
- L'inapplicabilité du code des marchés publics à l'acquisition d'immeubles bâtis ou de terrain ;
- L'incompétence d'un comptable public à remettre en cause une qualification d'un marché public validée par la DCMP ;
- Les conciliations ;
- La soumission de tous les marchés à commande à l'avis de la DCMP, quel que soit leur montant ... etc.

L'édition des bulletins et des guides par l'ARMP, de même que les sessions de formation destinées aux acteurs de la commande publique, montrent que l'ARMP s'investit sans relâche dans la formation en vue de doter tous les acteurs d'une compétence avérée afin de faire des marchés publics un véritable instrument de la croissance économique.



**INAPPLICABILITE DU CODE DES
MARCHES PUBLICS AU CONTRAT
DE LOCATION SIMPLE**

(ARTICLE 4 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

Voulant faire face au déficit d'électricité, la SENELEC comptait louer des groupes électrogènes.

Elle saisit donc le CRD pour lui demander si le Code des marchés publics est applicable au contrat de location de groupes électrogènes, qui est un contrat de location simple de biens.

S'appuyant sur les dispositions de l'article 4 dudit Code, le CRD en a déduit que le contrat de location simple n'est pas soumis au Code des marchés publics, contrairement à la location-vente et au crédit-bail, parce que la location simple n'a pas été retenue par le législateur sénégalais au moment de l'internationalisation de la directive 04/2005/CM/UEMOA portant procédure de passation et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'UEMOA.

L'avis donné par le CRD est le numéro 002 du 16 mars 2016 qui suit :

AVIS N° 002/16/ARMP/CRD DU 16 MARS 2016

DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

**COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE SENELEC RELATIVE A
L'APPLICABILITE DU CODE DES MARCHES PUBLICS AUX CONTRATS DE
LOCATION DE GROUPE ELECTROGENE**

8

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 5 août 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la résolution n°14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Vu la saisine de SENELEC en date du 02 mars 2016 ;

Madame Khadijetou Dia LY, contrôleur de gestion entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l'ARMP, rapporteur général du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération :

Par lettre du 02 mars 2016, reçue le même jour, la SENELEC a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) d'une demande d'avis sur la question de savoir si les contrats de location de groupes électrogènes sont soumis ou non au Code des Marchés publics.

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD

Considérant qu'aux termes de l'article 2.5 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007, l'ARMP est chargée de veiller, par ses avis et recommandations, à l'application de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics et délégations de service public et de contribuer à la promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence ;

Considérant qu'à ce titre, l'ARMP peut être saisie par toute autorité contractante, tout candidat ou titulaire de marchés pour avis sur l'application, le sens ou la portée de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics, délégations de service public, des documents standards, ou des décisions relatives aux procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics ;

Considérant que la saisine de la SENELEC vise à recueillir l'avis du CRD sur l'applicabilité du Code des Marchés publics aux contrats de location de groupes électrogènes ;

Qu'une saisine du CRD, dans un tel cas, n'est soumise à aucune condition de délai et de forme ;

Qu'à cet égard, il convient de la déclarer recevable.

LES FAITS

SENELEC qui a en charge la production, la distribution, la commercialisation et le transport de l'électricité aux populations ambitionne d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Pour ce faire, SENELEC utilise des moyens de production qui lui sont propres en plus de l'achat d'énergie auprès des producteurs indépendants et auto-producteurs d'électricité avec lesquels elle a signé des contrats d'achat d'énergie conformément à la loi 98-29 du 14 avril 1998.

Cependant, en raison d'un parc de production obsolète et d'un retard dans la mise en service de nouvelles centrales, SENELEC déclare devoir faire face à un déficit de production récurrent avec comme conséquence des délestages intempestifs ;

SENELEC informe dans sa saisine qu'en attendant l'aboutissement des projets structurants de centrales électriques qui apporteront une solution définitive aux problèmes, elle compte louer des groupes électrogènes pour faire face aux déficits et répondre à la demande de la clientèle.

C'est pourquoi, elle souhaite être édictée sur la soumission ou non des contrats de location de groupes au Code des Marchés publics.

L'OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que la demande de SENELEC vise à obtenir l'avis du Comité de Règlement des Différends (CRD) sur l'applicabilité du Code des Marchés publics aux contrats de location de groupes électrogènes.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que l'article 4.24 du Code des Marchés publics dispose qu' « un marché public est un contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, ou à des besoins combinant ces différentes catégories » ;

Qu'il résulte de la définition précitée qu'il existe en définitive trois (03) catégories de marchés publics, en l'occurrence les marchés de travaux, de fournitures et de services y compris les prestations intellectuelles ;

Considérant qu'en référence à l'article 1er de la Directive 04/2005/CM/UEMOA, le marché public de fournitures est un marché qui a pour objet l'achat, le crédit bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipement et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens ;

Qu'à la lecture de cette directive, la location de biens est expressément classée dans la catégorie « fournitures de biens » ;

Que dès lors la location de groupes électrogènes qui est une location de biens, rentre également dans la catégorie précitée et ne concerne par conséquent ni les marchés de services, ni les marchés de travaux ;

Considérant que l'article 4.19 du Code des Marchés publics (CMP) définit le marché de fournitures comme étant un marché de biens mobiliers de toutes sortes y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse et l'électricité, y compris également les biens acquis par crédit-bail ou location-vente et les services accessoires à la fourniture des biens, si la valeur de ces derniers services ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes ;

Qu'il ressort de l'examen de cet article, que la location, contrairement à la location-vente et le crédit-bail, n'a pas été retenue par le législateur au moment de l'internalisation de la Directive 04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest africain ;

Considérant que le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics est le seul texte réglementaire qui a vocation à régir les procédures

de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, même si les Directives de l'UEMOA en pose les principes directeurs qui ne sont pas d'application immédiate puisque devant être transposés ;

Que cette transposition dans le cas d'espèce n'a pas été intégrale ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la location de groupes électrogènes n'est pas un marché public aux regards des textes réglementaires ;

EMET L'AVIS QUI SUIT :

- 1) Constate que la Directive 04/2005/CM/UEMOA classe la location de biens dans la catégorie « fournitures de bien »;
- 2) Dit, en conséquence, que la location de groupes électrogènes doit être classée dans la catégorie fourniture de biens ;
- 3) Constate toutefois que le législateur, en internalisant les Directives de l'UEMOA n'a pas listé la location de bien au titre des marchés de fournitures au regard de l'article 4.19 du Code des Marchés Publics ;
- 4) Dit que le décret N°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics constitue le texte réglementaire applicable en la matière ;
- 5) Dit, en conséquence, que la location de groupes électrogène n'est pas un marché public au sens de la réglementation ;
- 6) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à SENELEC ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), le présent avis qui sera publié dans le portail des marchés publics.

11

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG

2

NULLITE ABSOLUE DU CONTRAT CONCLU PAR UNE PERSONNE INCOMPETENTE

**(ARTICLES 21 ET 22 DU COA ET ARTICLE 27 DU CODE
DES MARCHES PUBLICS)**

Il ressort des articles 21 et 22 du Code des Obligations de l'Administration (COA) que seule l'autorité administrative compétente peut conclure des contrats au nom et pour le compte de la personne administrative qu'elle représente et qu'à défaut, le contrat est nul et d'une nullité absolue.

De même que l'article 27 du Code des marchés publics reprend le même principe en précisant que la procédure de passation est conduite par la personne responsable du marché, qui est habilitée à signer le marché au nom et pour le compte de l'autorité contractante et que les marchés conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls et d'une nullité absolue.

C'est ainsi que suite à l'avis qui lui a été demandé par l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP), le CRD lui a fait savoir que le contrat qu'elle a conclu avec l'entreprise Toubha Khaira est nul et d'une nullité absolue.

En effet, le CRD s'est fondé sur les dispositions précitées pour constater cette nullité parce que le mandat qui avait été donné à l'ACBEP le 22 avril 2014 par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ayant été révoqué par le même ministère le 11 novembre 2014, l'ACBEP n'était plus compétente pour agir dans le domaine dudit mandat, mais a quand même conclu le marché y relatif.

L'avis donné par le CRD porte le numéro 003 du 23 mars 2016 suivant :

AVIS N° 003/16/ARMP/CRD DU 23 MARS 2016

**DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSIONLITIGES SUR LA SAISINE DE L'AGENCE DE CONSTRUCTION
DES BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS.**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSIONLITIGES ;**

VU la loi 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

VU le décret n° 201 1.657 du 1^{er} juin 2011 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) du Ministère du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie ;

VU le décret n° 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation ;

VU le décret n° 2014-565 du 6 mai 2014 portant organisation du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;

VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 20 Mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

VU la résolution n° 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

VU la demande de l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics ;

Après avoir entendu le rapport de Madame Henriette Diop Tall, Chef du Département des Ressources Humaines et de l'Administration Générale, présentant les moyens et conclusions des parties

En présence de Monsieur Mademba Gueye, Président, de Messieurs Samba Diop, Boubacar Mar et Cheikhou Issa Sylla, membres du Comité de Règlements des Différends (CRD)

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD assisté par ses collaborateurs, observateurs ,

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre du 30 Décembre 2015, enregistrée au service courrier de l'ARMP le même jour sous le numéro 3525, l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP), du Ministère du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie, a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour solliciter son avis sur l'arrêté préfectoral de suspension provisoire de la construction du centre médico-social de l'Université de Bambey.

L'ACBEP précise que, par décision de versement n° 07052/MESR/DC/DAGE du 22 avril 2014, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche l'avait autorisée à exécuter les travaux de construction du centre susvisé sur les fonds obtenus dans le cadre du BCI 2014.

SUR L'OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que la demande porte sur l'arrêté préfectoral de suspension provisoire de la construction du centre médico-social de l'Université de Bambey pour des raisons de risque de trouble à l'ordre public.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que l'arrêté n° 047/PDB du 10 novembre 2015 a été pris par le Préfet du Département de Bambey pour risque de trouble à l'ordre public à la suite de la présence sur le site des entreprises « Touba Khaira » et « Seneconstruction », toutes deux attributaires du même marché lancé, d'une part, par l'ACBEP du Ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie et, d'autre part, par la Direction de la Maintenance, des Constructions et des Equipements de l'Enseignement supérieur (DMCEES) du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le CRD ne peut pas apprécier la légalité de la suspension provisoire des travaux de construction du centre médico-social de l'Université Alioune DIOP ordonnée par le Préfet du département de Bambey pour prévenir tout risque de trouble à l'ordre public ;

Considérant qu'en outre, il apparaît au regard des faits de l'espèce que deux procédures de passation de marchés publics, ayant le même objet, ont été lancées par deux autorités contractantes distinctes en l'occurrence l'ACBEP et la DMCEES ;

Considérant qu'il ressort des articles 21 et 22 du Code des Obligations de l'Administration (COA) que seule l'autorité administrative compétente peut conclure des contrats au nom et pour le compte de la personne administrative qu'elle représente, qu'à défaut, le contrat est nul et d'une nullité absolue ;

Que l'article 27 du Code des Marchés publics (CMP) reprend le même principe en disposant que la procédure de passation du marché est conduite par la personne responsable du marché qui est habilitée à signer le marché au nom et pour le compte de l'autorité contractante, que les marchés conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls et d'une nullité absolue,

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :

- L'existence du mandat donné par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à l'ACBEP pour la construction du centre médico-social de Bambey suivant ;
- Décision n 0 07052/MESR/DC/DAGE du 22 avril 2014 ayant pour objet le versement d'un montant de 250.000.000 FCFA au profit de ladite agence ;
- Par lettre du 11 novembre 2014, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a informé le directeur de l'ACBEP, d'une part, de l'inexistence de couverture budgétaire pour le marché relatif à la construction du centre médico-social de l'Université Alioune DIOP pour l'année 2014 puisque tous les crédits initialement ouverts pour ces projets ont été ponctionnés ou réaménagés et, d'autre part, de la relance de ce marché par la direction de la maintenance, des constructions et des équipements de l'Enseignement supérieur (DMCEES) au titre de la gestion 2015 ;
- Par lettre du 31 décembre 2014, cette direction a sollicité le transfert de tous les documents relatifs à ce marché afin d'éviter la reprise des procédures entamées par l'agence ;

Considérant que, certes, l'ACBEP a pour mission générale de conduire des projets et travaux de construction de l'Etat au regard du décret n 0 201 1 .657 du 1^{er} juin 2011 portant création, organisation et fonctionnement de cette agence ;

Que cependant, il ressort du décret 11 n°2014-565 du 6 mai 2014 portant organisation du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que la DMCEES a été créée au sein de ce ministère avec, notamment, pour mission l'évaluation de leurs besoins de construction et d'entretien ainsi que la planification de leur exécution ;

Qu'ainsi, c'est à bon droit que le Ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche, faisant état de l'impossibilité pour son budget de prendre en charge des dépenses de marchés ayant comme autorité contractante l'ACBEP, a demandé à cette dernière de lui transférer tous ses projets de construction au profit d'une de ses directions, en l'occurrence la DMCEES ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le mandat légal précédemment donné à l'ACBEP a été révoqué au regard de la réglementation ;

Considérant que malgré cette révocation, l'ACBEP a continué la procédure de passation du marché relatif à la construction du centre médico-social de l'Université de Bambey en procédant d'une part à l'attribution dudit marché à l'entreprise Touba Khaira et d'autre part, à son approbation par son conseil de surveillance le 19 juin 2015, qu'elle a, ensuite, émis des ordres de service le 03 septembre 2015 alors qu'à ces dates, l'agence, nonobstant l'avis de non objection de la Direction centrale des Marchés publics, n'avait plus le pouvoir de continuer la procédure de passation du marché litigieux au nom et pour le compte du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ,

Qu'il y a lieu de constater, en application des articles 21, 22 du COA et 27 du CMP, la nullité absolue du contrat conclu entre l'ACBEP et l'entreprise Touba Khaira, à charge pour cette autorité contractante d'en tirer toutes les conséquences de droit puisque cette absence de pouvoir de représentation vicie de manière substantiel la régularité de la poursuite de la procédure de passation de ce marché ;

Considérant que la procédure lancée par la DMCEES ayant abouti à l'attribution du marché à l'entreprise Seneconstruction, n'est pas entachée d'irrégularité de forme ou de fond, que dès lors, la continuation de la procédure avec ledit attributaire n'est pas en contradiction avec la réglementation ;

Considérant, toutefois, que l'article 45 du COA dispose qu'en cas de défaut de conclusion ou d'approbation du contrat, même en l'absence de faute, le titulaire du marché peut obtenir une indemnité si les prestations ont été fournies avec l'assentiment de l'Administration et lui ont profité ;

Qu'en application de cette disposition, la DMCEES devra se rapprocher de l'entreprise Touba Khaira qui a effectué des travaux sur le site, afin de discuter des modalités d'une indemnisation,

EMET L'AVIS QUI SUIT :

- 1) Constate la révocation du mandat donné à l'ACBEP par le décret 11 0 2014-565 du 6 mai 2014 portant organisation du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a créé la DMCEES et fixé ses missions ;
- 2) Constate qu'au moment de l'approbation du marché lancé par l'ACBEP et de l'émission des ordres de service, l'agence n'avait plus le pouvoir d'agir au nom et pour le compte du Ministère précité ;
- 3) Dit que le contrat conclu entre l'ACBEP et l'Entreprise Touba Khaira est frappé de nullité absolue au regard de la réglementation ;

- 4) Dit que l'ACBEP et l'entreprise Touba Khaira devront en tirer toutes les conséquences de droit ;
- 5) Dit que la procédure de passation du marché lancée par la DMCEES est régulière ;
- 6) Dit, toutefois, que cette direction (DMCEES) devra se rapprocher de l'Entreprise Touba Khaira afin de discuter des modalités d'une indemnisation au regard des dispositions de l'article 45 du COA ;
- 7) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au ministère du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie, au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et à la Direction centrale des Marchés publics, le présent avis qui sera publié sur le site officiel des Marchés publics.

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Le directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG

3

INAPPLICABILITÉ DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BÂTIS OU DE TERRAIN

(ARTICLE 4 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

En vertu de l'article 4.24 du Code des marchés publics, le marché public a pour objet : « le contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à des besoins en matière de travaux, fournitures ou services »

S'appuyant sur cette disposition, le CRD donne l'avis selon lequel l'acquisition d'immeubles bâtis ou de terrains n'est pas soumise au Code dans la mesure où d'une part elle concerne des ouvrages déjà réalisés insusceptibles d'être qualifiés de marchés de travaux tels que définis par le Code à l'article 4.36 et que d'autre part il ne s'agit ni de marché de fournitures dont l'objet porte sur des biens mobiliers, ni de marchés de services dont l'objet correspond soit à de la main d'œuvre, soit à une prestation intellectuelle, soit à la maîtrise d'ouvrage ; qu'en conséquence les contrats d'achat de locaux existants se distinguent de par leur objet des marchés de travaux, de fournitures ou de services.

L'avis du CRD n°004 du 20 avril, ci-dessous, est donné à titre d'exemple :

AVIS N° 004/16/ARMP/CRD DU 20 AVRIL 2016

DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

**COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DU FOND DE GARANTIE DES
INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES (FONGIP) D'ACQUERIR DIRECTEMENT UN
IMMEUBLE POUR ABRITER SON SIEGE**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES,**

19

VU la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30

VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

VU le décret n° 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

VU la résolution n° 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends ;

VU la demande d'autorisation initiée par correspondance du 08 avril 2016 par le FONGIP ;

Mame Aïssatou Dieng TRAORE, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux principes de la régulation;

EMET LE PRÉSENT AVIS

Par lettre du 08 avril 2016, reçue le 11 avril au bureau du courrier et enregistrée le lendemain, au secrétariat du CRD sous le rfi 12/16, le Fonds de garantie des Investissements prioritaires (FONGIP) a saisi le CRD d'une demande d'autorisation relative à l'acquisition d'un immeuble pour y loger son siège.

A l'appui de sa demande, le FONGIP expose qu'il a reçu mandat de son Conseil d'administration pour acquérir un immeuble destiné à loger son siège. Une copie du relevé des conclusions des travaux du Conseil d'Administration n o 7 tenu le 03 décembre 2015, est jointe à la demande.

Le FONGIP compte payer l'acquisition des locaux visés et entièrement aménagés par un emprunt bancaire dont le remboursement se fera sur la base des ressources propres générées par ses placements et commissions de garanties.

Il ajoute que cette acquisition vise à réduire des charges locatives de son siège estimé à plus de cent millions (100 000 000) FCFA/an.

Par ailleurs, le FONGIP fait remarquer que le décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics (CMP) ne prévoit pas de procédure spécifique à ce mode d'acquisition.

C'est pourquoi, le FONGIP sollicite l'autorisation du Comité de Règlement des Différends pour acquérir directement ces locaux conformément aux dispositions relatives aux règles de gestion comptable et domaniale.

L'OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine que la demande d'avis porte sur la soumission de l'acquisition d'immeubles bâtis au Code des Marchés publics.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du Code des Obligations de l'Administration, « les règles régissant la préparation, la passation, l'approbation et le contrôle des commandes publiques visées à l'article 24 sont fixées par un décret portant Code des Marchés publics » ;

Qu' « aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d'acheteurs ou une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le Code des Marchés publics » ;

Considérant que les seules exclusions et dérogations à cette prescription, ci-dessous énumérées et accordées aux autorités contractantes, résultent respectivement des dispositions des articles 3 et 4 du Code des Marchés publics :

EXCLUSIONS :

- Les services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance et de représentation juridiques ;
- Les services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert des titres ou d'autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou capital des autorités contractantes, et les services fournis par des banques centrales ;
- Les contrats de travail.

DÉROGATIONS :

- Le service du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères publiques sans limitation de prix et sans appliquer les procédures prévues par le présent décret. Le règlement de ces achats peut avoir lieu sur production du procès-verbal de vente de sa personne habilitée à effectuer les ventes aux enchères ;
- Les missions diplomatiques et consulaires à l'étranger peuvent faire des acquisitions sans appliquer les procédures prévues par le Code des Marchés publics ;
- Les acquisitions de produits pétroliers dénommés super carburant, essence ordinaire et gasoil, destinés uniquement à l'usage des véhicules administratifs ainsi que l'acquisition de gaz butane à usage domestique, et dont l'acquisition est soumise à l'application du prix en vigueur figurant au barème de la structure des produits pétroliers publié périodiquement par la Commission nationale des Hydrocarbures du Ministère chargé de l'Energie. Sont exclus de cette dérogation les produits destinés à l'exploitation ;
- Les titres de transport aérien et maritime pour les besoins des missions de leurs agents ;
- L'hébergement et la restauration des participants dans les réceptifs hôteliers ou dans les structures ayant une telle vocation, à l'occasion de l'organisation de sommets officiels, de séminaires ou d'ateliers ;
- La publication par voie de presse d'insertions publicitaires ainsi que les publiereportages par supports audio-visuels ;
- En cas de rupture de stocks, les médicaments et produits essentiels utilisés dans la médecine d'urgence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de l'organe de régulation des marchés publics ;

- Les médicaments et produits pharmaceutiques essentiels conformément à l'arrêté du ministre en charge de la santé fixant les modalités de l'approvisionnement pharmaceutique des services de formations sanitaires.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles du paragraphe 2 de l'article 3 relatif aux éventuelles dérogations conférées par les accords de financement ou de traités, qu'aucun marché public ne peut être passé en dehors des règles fixées par le Code des Marchés publics.

Que donc, à défaut de texte législatif ou réglementaire écartant un achat du champ du Code des Marchés publics, l'exclusion de cet achat des règles de passation des marchés publics ne peut être examinée que sous l'angle de l'objet des marchés publics ;

Qu'alors, la question est de savoir si une acquisition d'immeuble correspond à l'objet du marché public tel que défini par l'article 4.24 du Code des Marchés publics : « le contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à des besoins en matière de travaux, fournitures ou services » ;

Considérant que l'acquisition d'immeubles bâtis ou de terrains concerne des ouvrages déjà réalisés qui ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de marchés de travaux tels que définis par le Code des Marchés publics à l'article 4.36 ;

Que s'agissant, par ailleurs, des marchés de fournitures ou de services, outre cette exigence de définition préalable des besoins, il faut relever que l'achat d'immeuble existant se distingue de ces marchés de par leur objet en ce sens que, d'une part, les marchés de fournitures portent sur des biens mobiliers, d'autre part, les marchés de services ont pour objet soit une prestation de services correspondant à de la main d'œuvre, sans concrétisation d'un ouvrage : maintenance ou entretien, soit une prestation intellectuelle où il s'agit de production de l'esprit, de réflexion, soit la maîtrise d'ouvrage ;

Qu'il en résulte que les contrats d'achat de locaux existants se distinguent de par leur objet des marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

Qu'en conséquence, les règles de passation de ces marchés, telles qu'établies par le décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics (CMP), ne leur sont pas applicables ;

Qu'il y a lieu, toutefois, de signaler que les éventuels aménagements pour rendre les locaux fonctionnels devront se faire après cette acquisition ;

Que ces aménagements sont des marchés de travaux à passer suivant les règles édictées par le Code des Marchés publics ;

EMET L'AVIS QUI SUIT :

- 1) Constate que le FONGIP veut acquérir un immeuble bâti pour abriter son siège ;

2) Dit, cependant, que l'acquisition d'immeubles bâtis ou de terrains ne figure pas dans la liste des exclusions et dérogations prévues à l'article 3 du Code des Marchés publics ;

3) Dit que cette acquisition ne répond pas à la définition d'un marché public tel que prévu à l'article 4.24 du Code des Marchés publics ;

4) Dit, en conséquence, que l'acquisition d'immeubles bâtis ou de terrains ne rentre pas dans le champ d'application du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

5) Dit, cependant, que les éventuels aménagements à faire sont détachables de l'opération d'acquisition et sont des marchés de travaux soumis au Code des Marchés ;

6) Dit que le Directeur général de la Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier à la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP), au fond de garantie des Investissements prioritaires (FONGIP), la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Le directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG

4

INCOMPÉTENCE D'UN COMPTABLE PUBLIC À REMETTRE EN CAUSE UNE QUALIFICATION D'UN MARCHÉ PUBLIC VALIDÉE PAR LA DCMP

**(ARTICLE 30 DU COA ET ARTICLE 6 DU CODE DES
MARCHES PUBLICS)**

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 30 du COA et de l'article 6 du Code des marchés publics que la DCMP, qui assure le contrôle à priori des procédures de passation, les missions de collecte et diffusion d'informations sur l'attribution et les conditions d'exécution de ces marchés, reçoit les plans de passation des marchés et vérifie la conformité du document puis en assure la publication ; que cette vérification de conformité portant, entre autres, sur le libellé des marchés, leur qualification et leur mode de passation envisagé, lorsqu'un marché est qualifié « de travaux » ou autre et publié comme tel par la DCMP, l'autorité contractante est donc tenue par ladite qualification, qu'en conséquence, il ne revient pas à un comptable public de remettre en cause ladite qualification.

Telle est la position du CRD donnée dans son avis numéro 005 du 1er juillet 2016, suite à la demande du maire de la Commune de Niahkène :

**AVIS N O 005116/ARMP/CRD DU 01 JUILLET 2016 DU COMITE DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR
LA SAISINE DE LA COMMUNE DE NIAKHENE CONCERNANT UN MARCHE
D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC, LANCE
SOUS FORME D'UN « MARCHE DE TRAVAUX »**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES,**

VU la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 2 ;

VU le décret n° 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation ;

VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU la décision n° 005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

VU la résolution n° 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la lettre du 10 juin 2016 de la Commune de NIAKHENE ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Conseiller juridique chargé des études et de la stratégie de développement de l'ARMP, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD)

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

ADOpte LA PRÉSENTE DÉCISION ;

Par lettre du 10 juin 2016, reçue et enregistrée le même jour au secrétariat du Comité de Règlement et des Différends sous le numéro 170/16, le Maire de la Commune de NIAKHENE a saisi le CRD pour demander un avis sur le marché d'entretien et de réparation du réseau d'éclairage public suite aux observations du Trésorier/Payeur du département de Tivaouane.

Selon l'autorité contractante, le marché porte sur des activités de réparation des systèmes d'allumage automatique des lampadaires (contacteurs et horloges), de changement des ampoules grillées, de réparation des autres composantes défectueuses (transformateurs, douilles, calendres, etc.) et de nettoyage des appareils (enlèvement des nids d'oiseau et autres papillons). Justifiant qu'il a été publié dans le plan de passation de la commune sous la forme d'un marché de travaux.

Toutefois, il signale que le Payeur du département de Tivaouane a requalifié le marché de « marché de fourniture » et a exigé la présentation du procès-verbal d'attribution du marché signé par tous les membres de la commission des marchés de la Commune de NIAKHENE.

26

La Commune de NIAKHENE conteste cette attitude du Payeur en invoquant le dernier (...) tiré du sixième paragraphe de l'article 3 de l'arrêté n° 00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix en application de l'article 78 du Code des Marchés publics qui indique que l'autorité contractante « attribue le marché au candidat présentant l'offre conforme évaluée la moins-disante, rédige un procès-verbal d'attribution et informe les candidats dont les offres n'auront pas été retenues

Elle signale, d'ailleurs, que dans la mise en œuvre de la procédure de DRP restreinte, il n'est nullement indiqué l'intervention de la commission des marchés contrairement à la procédure de DRP ouverte où il est clairement décrit au paragraphe sept de l'article 5 du même arrêté l'intervention de la commission des marchés.

Enfin, la Commune souligne, dans son argumentaire, que les modifications apportées par le nouveau Code des Marchés publics (décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014) et portant essentiellement sur la réduction des délais réglementaires, le relèvement des seuils et la responsabilisation accrue des autorités contractantes ont pour but de concilier les exigences de transparence à la nécessaire célérité des procédures.

L'OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d'avis porte sur :

- La requalification d'un marché de travaux en marché de fourniture par le Payeur ;

- L'intervention obligatoire de la Commission des Marchés dans la procédure de demande de renseignements et de prix.

AU FOND

1) Sur la requalification d'un marché de travaux en marché de fourniture par le Payeur

Selon l'article 30 du Code des Obligations de l'Administration, une structure administrative spécialement mise en place assure le contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics, délégation de service public, les missions de collecte et diffusion d'informations sur l'attribution et les conditions d'exécution de ces marchés... ;

Qu'à cet effet, l'article 6 du Code des Marchés publics dispose que les plans de passation de marchés doivent être communiqués à la Direction chargée du contrôle des marchés publics au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée et que celle-ci vérifie la conformité du document puis en assure la publication dans les trois (03) jours francs suivant la réception ;

Que les vérifications de conformité de l'organe chargé du contrôle a priori portent, entre autres, sur le libellé des marchés, la qualification de ces derniers et la procédure passation envisagée (mode de passation)

Qu'ainsi, lorsqu'un marché est qualifié de travaux, de fournitures ou de services et publié comme tel par la Direction chargée du contrôle des marchés publics, l'autorité contractante est tenue par ladite qualification validée par cette dernière ;

Considérant qu'en l'espèce, le Payeur a requalifié le marché en question en acquisition de fournitures pour remettre en cause la procédure de passation utilisée, tandis que celui-ci est publié sous la forme de marché de travaux dans le plan de passation de la commune de NIAKHENE — version 3 du 06 juin 2016 —, validé par la Direction centrale des Marchés publics ;

Que les acteurs du système de passation et d'exécution des marchés publics étant investi chacun en ce qui le concerne de compétences précises, il ne revient pas à un comptable public, dans le cadre de la vérification de la régularité externe des procédures de passation, de remettre en cause une qualification d'un marché public validé par l'organe chargé du contrôle a priori au risque d'entamer la stabilité juridique des procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;

2) Sur la signature du procès-verbal d'attribution par les membres de la commission

Considérant qu'en application de l'article 78 du Code des Marchés publics, l'article premier de l'arrêté n 0 00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix dispose que l'autorité contractante peut utiliser les procédures spécifiques qui suivent :

- a) La demande de renseignements et de prix simple dispensée d'une forme écrite ;
- b) La demande de renseignements et de prix à compétition restreinte ;
- c) La demande de renseignements et de prix à compétition ouverte ;

Que pour la procédure de demande de renseignements et de prix simple dispensée d'une forme écrite, l'autorité contractante attribue le marché au candidat ayant soumis la proposition la moins-disante et en dresse le procès-verbal signé par la personne habilitée, que la procédure ainsi décrite ne nécessite ni cahier de charges formel ni publicité ou saisine écrite et que les commandes découlant de cette procédure feront l'objet de règlement sur simple mémoire ou facture ;

Que dans le cas de la procédure de demande de renseignements et de prix à compétition restreinte, sous réserve de l'application d'autres procédures spécifiques ou de règles prévues par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, l'autorité contractante attribue le marché au candidat présentant l'offre conforme évaluée la moins-disante, rédige un procès-verbal d'attribution et informe les candidats dont les offres n'auront pas été retenues ;

Que s'agissant de la procédure de demande de renseignements et de prix à compétition ouverte, la commission des marchés de l'autorité contractante procède à l'évaluation en fonction des critères mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence ; qu'elle propose à l'autorité contractante l'attribution du marché au candidat qui a l'offre conforme évaluée la moins-disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence ;

Considérant, ainsi, que dans une logique d'allègement des procédures de passation des marchés publics, la réglementation ne fait obligation de recourir à la commission des marchés publics pour l'ouverture, l'évaluation et la proposition d'attribution que pour la procédure de demande de renseignements et de prix à compétition ouverte ;

Que relativement à la procédure de demande de renseignements et de prix simple dispensée d'une forme écrite, la signature du procès-verbal d'attribution est dévolue à une personne habilitée au sein de l'autorité contractante et non à la commission des marchés publics ;

Qu'au vu de sa nature de marché de travaux et de son montant (3 400 000 F CFA TTC) celui-ci ayant été passé, en toute légalité, en demande de renseignements et de prix simple dispensée d'une forme écrite, le Payeur ne peut pas exiger que le procès-verbal d'attribution soit signé par les membres de la commission des marchés de la commune de NIAKHENE ;

Que de même si le marché devait être passé par demande de renseignements et de prix à compétition restreinte, l'exigence du Payeur pour que le procès-verbal soit signé par les membres de la commission de l'autorité contractante ne peut légalement prospérer ;

EMET L'AVIS QUI SUIT :

- 1) Constate que le Payeur a requalifié le marché en question en acquisition de fournitures pour remettre en cause la procédure de passation utilisée, tandis que celui-ci est publié sous la forme de marché de travaux dans le plan de passation de la commune de NIAKHENE — version 3 du 06 juin 2016 validé par la Direction centrale des Marchés publics ;
- 2) Dit que la réglementation confie principalement le contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public à la Direction centrale des Marchés publics ;
- 3) Dit que les plans de passation de marchés doivent être communiqués à la Direction chargée du contrôle des marchés publics et que celle-ci vérifie la conformité du document puis en assure la publication ;
- 4) Dit qu'il ne revient pas à un comptable public, dans le cadre de la vérification de la régularité externe des procédures de passation, de remettre en cause une qualification d'un marché public validé par l'organe chargé du contrôle a priori ;
- 5) Constate que le marché est passé, en toute légalité, en demande de renseignements et de prix simple dispensée d'une forme écrite ;
- 6) Dit que pour un marché passé par demande de renseignements et de prix simple dispensée d'une forme écrite ou à compétition restreinte, la signature du procès-verbal d'attribution n'est pas dévolue à la commission des marchés publics de l'autorité contractante ;
- 7) Dit, en conséquence, qu'en l'espèce, le Payeur ne peut pas exiger que le procès-verbal d'attribution soit signé par les membres de la commission des marchés de la commune de NIAKHENE ;
- 8) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Commune de NIAKHENE et à la Direction centrale des Marchés publics, le présent avis qui sera publié sur le portail des marchés publics.

Le président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Le directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG

5

**LA SIGNATURE DU PROCES-
VERBAL D'ATTRIBUTION DE LA
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
ET DE PRIX (DRP) DISPENSÉE
D'UNE FORME ÉCRITE N'EST PAS
DEVOLUE A LA COMMISSION DES
MARCHÉS**

**(ARTICLE 78 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET
ARRÊTÉ N°0017 DU 7 JANVIER 2015)**

En application de l'article 78 du Code des marchés publics, l'article premier de l'arrêté n°00107 du 7 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix précise que pour la procédure de renseignements et de prix simple dispensée d'une forme écrite, l'autorité contractante attribue le marché au candidat ayant soumis la proposition la moins-disante et en dresse le procès-verbal signé par la personne habilitée.

(Voir l'avis précédent avis n° 005 du 1ier juillet 2016)

6

LES CONCILIATIONS

**(ARTICLES 30 NOUVEAU ET 45 DU COA,
ARTICLE 138 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS,
ARTICLE 2 DU DÉCRET N°2007-546 DU 25 AVRIL 2007,
ARTICLE 16 DE LA LOI DES FINANCES 2016)**

En cas de différends relatifs à l'exécution des marchés publics, l'autorité contractante ou le titulaire du marché peut recourir au CRD dont la mission sera de rechercher des éléments de droit ou de fait, en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends qui lui sont soumis.

Cette compétence du CRD se fonde sur l'article 30 nouveau du COA, l'article 138 du code des marchés publics et l'article 2 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.

C'est ainsi qu'en 2016, le CRD, saisi par les parties intéressées, a procédé à quinze (15) conciliations ayant donné lieu à l'établissement de 15 procès-verbaux.

Ces conciliations sont fondamentales, car non seulement elles évitent aux parties de recourir à une procédure contentieuse, mais également elles interviennent dans des domaines très sensibles (fonctionnement des services d'un hôpital etc..).

Il s'agit souvent de régler à l'amiable un différend né dans le cadre de l'exécution d'un marché entaché de vices au sens du code des marchés, mais dont les prestations ont été fournies avec l'assentiment de l'autorité contractante et lui ont profité, mais dont l'agent comptable refuse de payer, ou de marché résilié par l'autorité et devant entraîner le paiement d'une indemnité de l'article 45 du COA et de l'article 16 de la loi des finances 2016. Il peut s'agir également d'un marché dont l'attributaire n'arrive pas à respecter les délais d'exécution à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, ou de l'application de la clause de garantie en cas de dommage subi par le bien objet du marché.

Quelle que soit la situation, la conciliation des parties, encadrées par le CRD, entraîne leur renoncement à toute réclamation dans le cadre du marché concerné.

Nous donnerons, à titre d'exemple, les conciliations suivantes :

6-1 Après exécution d'un marché entaché de vices, il est possible d'indemniser l'entreprise ayant fourni des prestations avec l'assentiment de l'autorité contractante (article 45 du COA)

PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DU MERCREDI 01 JUIN 2016

PORTANT SUR LE REGLEMENT A L'AMIABLE DU DIFFEREND ENTRE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME ET LA SOCIETE MOUMINATOU DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE CACHETS POUR LE REFERENDUM DU 20 MARS 2016.

L'an deux mille seize et le premier juin ;

Par devant le Comité de Règlement des Différends saisi en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration, de l'article 138 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics et de l'article 2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Etaient présents :

- d'une part : Messieurs Ibrahima DIAGNE et Mamadou Bachirou NIANG, respectivement Secrétaire Général et Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;
- d'autre part : Monsieur Abdou Salam KANE, Directeur de la société MOUMINATOU.

Pour le compte de l'ARMP :

- Monsieur Ely Manel FALL, Conseiller juridique chargé des études et de la stratégie de développement de l'ARMP ;
- Monsieur Alioune Badara DIOP, Assistant à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques.

SUR L'EXPOSÉ DU DIFFÉREND

Suite à une Demande de Renseignements et des Prix à compétition restreinte, l'entreprise MOUMINATOU a été attributaire du marché relatif à la fourniture de cachets pour le référendum du 20 mars 2016 avec un montant de 70 156 900 FCFA TTC, lancé par la Commission Electorale nationale Autonome (CENA).

34

Toutefois, après dépouillement, la CENA a constaté que le montant de la DRP susvisé a dépassé le seuil prévu par ledit Code des Marchés publics.

En revanche, compte tenu de l'échéance électorale, le planning qui était fixé pour la confection des cachets et leur distribution dans tous les bureaux de vote avait fait qu'elle a dû conclure le marché parce que sans le cachet de la CENA, aucun procès-verbal de bureau de vote ne peut être valable.

A cet effet, vu que le marché signé avec le fournisseur ne lui permet pas de payer les prestations parce qu'entaché d'un vice du fait que le montant total du marché dépasse le seuil fixé pour passer une Demande de Renseignements et des Prix à compétition restreinte, et que le matériel a déjà été livré, la CENA a ainsi saisi le Comité de Règlement des Différends pour un règlement amiable du différend conformément à l'article 138 du Code des Marchés publics et aux stipulations relatives à l'arbitrage contenues dans le contrat.

A cet égard, les deux parties ont été conviées à une rencontre au siège de l'ARMP, le mardi 24 mai 2016, afin de rechercher des éléments de droit ou de fait, pour une solution amiable et équitable au différend.

Sur les points d'accord :

Les parties ont marqué leur accord sur une indemnisation du titulaire du marché, l'entreprise MOUMINATOU, par la CENA, conformément à l'article 45 du Code des Obligations de l'Administration. Ce faisant, elles ont accepté, d'accord-parties, de défalquer 3% du prix total du marché pour fixer le montant de l'indemnité.

Ainsi, ce dernier est arrêté à la somme de 68 052 193 (soixante-huit millions cinquante-deux mille cent quatre-vingt-treize) francs CFA qui représente la différence entre le montant total du marché à savoir 70 156 900 (soixante-dix millions cent cinquante-six mille neuf cent) francs CFA TTC et 2 104 707 (deux millions cent quatre mille sept cent sept) francs CFA qui est la valeur des 3%.

Il est à noter qu'à titre d'avance sur ce marché, l'entreprise MOUMINATOU reconnaît avoir reçu de la CENA deux chèques (BICIS) d'un montant total de 15 000 000 (quinze millions) de francs CFA.

Par conséquent, le montant restant dû par la CENA, au titre de l'indemnisation, est de 53 052 193 (cinquante-trois millions cinquante-deux mille cent quatre-vingt-treize) francs CFA.

Enfin, au titre dudit accord, l'entreprise MOUMINATOU renonce à tout recours qu'il pourrait exercer dans le cadre de l'exécution du marché, susvisé.

Pour matérialiser cet accord, les parties ont convenu de se rapprocher de l'ARMP pour la signature du procès-verbal de conciliation.

Le CRD, au cours de sa séance du 01 juin 2016, après avoir donné acte aux parties de leur accord, a rappelé la substance des articles 17 et 45 du Code des Obligations de l'Administration qui disposent que « la conclusion d'un contrat susceptible d'engager les finances de la personne administrative contractante est soumise à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles d'engagement des dépenses publiques, l'inexécution de cette obligation n'est pas opposable au cocontractant de l'Administration » et ce, surtout si les prestations ont été exécutées par le titulaire du marché avec l'assentiment de l'autorité contractante.

Le présent procès-verbal, soumis aux membres du Comité de Règlement des Différends, réuni en session du 01 juin 2016 en présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du CRD et de Saer NIANG, Secrétaire-rapporteur du CRD, a été adopté.

L'ARMP est le garant de ce protocole

Lecture faite, les parties et les membres du CRD de l'ARMP ont signé le présent procès-verbal délivré en trois originaux.

Fait à Dakar le 01 juin 2016.

Pour la CENA

Monsieur Ibrahima DIAGNE, Secrétaire Général de la CENA

Pour l'entreprise MOUMINATOU

Monsieur Abdou Salam KANE, Directeur de la société MOUMINATOU

Pour le Comité de Règlement des Différends

Mademba GUEYE, Président

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général de l'ARMP, rapporteur

Saër NIANG

6-2 La résiliation unilatérale du marché par l'autorité contractante ouvre droit à une indemnité au bénéfice de l'attributaire (articles 137 et 138 du COA)

En vertu des articles 137 et 138 du COA, l'autorité contractante peut, nonobstant les clauses conventionnelles, résilier les contrats devenus inutiles ou inadaptés compte tenu des nécessités du service public, sous réserve d'indemnisation du cocontractant par une réparation intégrale couvrant la perte subie, le gain manqué, et, éventuellement, le préjudice moral causé au cocontractant par la résiliation de la convention.

PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DU 01 JUILLET 2016

PORTANT SUR LE REGLEMENT A L'AMIABLE DU DIFFEREND RELATIF AUX TRAVAUX DE REMISE A NIVEAU DE LA VOIE FERREE DU MOLE 1, SORTIE GARE FERROVIAIRE JUSQU'A L'ENRACINEMENT DU MOLE 3, OPPOSANT LE PORT AUTONOME DE DAKAR AU GROUPE MLG

L'an deux mille seize et le premier juillet ;

Par devant le Comité de Règlement des Différends saisi en vertu des dispositions de l'article 30 nouveau de la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration, de l'article 137 du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics et de l'article 2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics,

Etaient présents :

- d'une part : Pour le compte du Port Autonome de Dakar :
 - Monsieur Papa Sidy TALL, chef de la division des infrastructures et superstructures,
 - Monsieur Daouda TALL, chargé d'études, représentant du Coordonnateur de la cellule de passation des marchés ;
- d'autre part : Pour le compte du groupe MLG :
 - Monsieur Arona GUEYE, conseiller technique ;

Pour le compte de l'ARMP :

- Madame Khadijetou Dia LY, contrôleur de Gestion.

SUR L'EXPOSÉ DU DIFFÉREND

Le groupe MLG a saisi le Comité de Règlement des Différends, par courrier du 18 janvier 2016 reçu et enregistré au secrétariat du CRD sous le numéro 020/16, d'une réclamation contre le Port autonome de Dakar suite à la résiliation du marché N° 04/2012/M relatif aux travaux de remise à niveau de la voie ferrée du môle 1, sortie gare ferroviaire jusqu'à l'enracinement du môle 3, pour un montant

de cent quarante-deux millions six cent vingt-quatre mille huit cent soixante-dix-sept (142 624 877) F CFA TTC.

A l'appui de sa saisine, le groupe MLG expose qu'après la signature et l'approbation du marché précité, les travaux y relatifs ont démarré le 23 juillet 2012. Cependant, il rappelle la suspension du chantier depuis le 03 septembre 2012 par l'autorité contractante qui avait invoqué l'indisponibilité de matériels et accessoires, dont la fourniture lui incombait.

Le requérant informe que deux années après, au cours desquelles plusieurs relances ont été adressées au PAD pour la reprise des travaux, ce dernier, par lettre du 22 décembre 2014 lui a notifié la résiliation du marché.

Suite à cette résiliation unilatérale, le groupe MLG a adressé au Port Autonome de Dakar, par correspondance du 29 janvier 2015 reçue le 2 février 2015, une demande d'indemnisation pour un montant de trente-trois millions cent soixante-dix-huit mille vingt-deux (33 178 022) FCFA TTC représentant le préjudice matériel, le manque à gagner sur la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée ainsi que le préjudice moral subi.

Le groupe MLG précise que cette demande d'indemnisation n'a pas connu une suite positive car le PAD refusait d'intégrer le préjudice moral dans le montant de l'indemnité. Suite à la saisine du CRD, plusieurs rencontres ont eu lieu dans les locaux de l'ARMP dont la dernière, en date du 1er juin 2016, a permis de trouver une solution amiable.

Au cours de cette rencontre, les représentants du PAD, à la lecture des articles 137 et 138 du Code des Obligations de l'Administration par le représentant de l'ARMP, ont marqué leur accord pour le paiement intégral du montant de trente-trois millions cent soixante-dix-huit mille vingt-deux (33 178 022) FCFA TTC réclamé par le groupe MLG.

En effet, l'article 137 du COA dispose que : « l'administration peut, nonobstant les clauses conventionnelles, résilier les contrats devenus inutiles ou inadaptés compte tenu des nécessités du service public, sous réserve d'indemnisation du cocontractant ».

Au terme de l'article 138, « l'indemnisation est intégrale. Elle couvre la perte subie, le gain manqué, et éventuellement le préjudice moral causé au cocontractant par la résiliation de la convention ».

Les représentants du PAD, avouant être désormais convaincus du bienfondé de la réclamation du groupe MLG, ont proposé de revenir avec une proposition concrète après avoir rendu compte à leur Direction générale.

Par lettre en date du 27 Juin 2016, reçue le même jour au service courrier de l'ARMP, le Directeur général du PAD a marqué son accord pour l'indemnisation du groupe MLG à hauteur de trente-trois millions cent soixante-dix-huit mille vingt-deux (33 178 022) FCFA TTC, en autorisant l'établissement d'un procès-verbal de conciliation à cet effet.

Ainsi, pour matérialiser les points d'accord, les parties ont convenu de la signature du présent procès-verbal de conciliation, présenté au Comité de Règlement des

Différends, réuni en session du 01 juillet 2016 en présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres CRD, qui l'on adopté.

SUR LES POINTS D'ACCORD

Après discussions, les deux parties se sont accordées sur les points suivants :

- Le Port Autonome de Dakar s'engage à indemniser le groupe MLG à hauteur de trente-trois millions cent soixante-dix-huit mille vingt-deux (33 178 022) FCFA TTC, suite à la résiliation du marché n° 04/2012/M relatif aux travaux de remise à niveau de la voie ferrée du môle 1, sortie gare ferroviaire jusqu'à l'enracinement du môle 3, au plus tard quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception par le Port autonome de Dakar du présent protocole signé par les parties ;
- Le groupe MLG accepte l'indemnisation de trente-trois millions cent soixante-dix-huit mille vingt-deux (33 178 022) FCFA TTC et s'engage à renoncer à toute autre réclamation dans le cadre du contrat.

L'ARMP est le garant de ce protocole.

Lecture faite, les parties et les membres du CRD de l'ARMP ont signé le présent procès-verbal délivré en trois originaux.

Fait à Dakar le 01 juillet 2016.

Pour Le Port autonome de Dakar

Daouda TALL

Papa Sidy TALL

Chargé d'Etudes

Chef de division des infrastructures

Cellule Passation des Marchés

et superstructures

Pour le groupe MLG

Arona GUEYE

Conseiller Technique

Pour le Comité de Règlement des Différends

Mademba GUEYE, Président

Samba DIOP

Boubacar MAR

Le Directeur Général de l'ARMP,

Rapporteur

Saër NIANG

6-3 Le retard accusé par l'attributaire du marché dans l'exécution des travaux peut entraîner son dessaisissement partiel au profit de sous-traitants

PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DU 10 AOÛT 2016

PORTANT SUR LE REGLEMENT A L'AMIABLE DU DIFFEREND ENTRE L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (ETPB) ET LE MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE RELATIF AU MARCHE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE R+2 DEVANT ABRITER LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET LES ARCHIVES, LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DE LA RECHERCHE ET DES STATISTIQUES ET L'INSPECTION DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE

L'an deux mille seize et le dix août ;

VU la loi no 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration, modifiée par la loi no 06-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

VU le décret no 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en son article 2 ;

VU le décret no 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation ;

VU le décret no 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics, notamment en son article 138 ;

VU la résolution no 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Etaient présents :

- d'une part : Pour le compte du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale :

Messieurs :

- Papa Amadou Diack, Docteur, Directeur Général de la Santé ;
- Vincent Vercruysse, Docteur, Coresponsable PAGOSAN Volet offre, coordonnateur du Programme Santé ;

- d'autre part : Pour le compte de l'Entreprise des Travaux Publics et Bâtiment (ETPB):

Messieurs :

- Moussa Diallo, Directeur Général ;
- Moussa Guèye, Directeur financier.

Pour le compte de l'ARMP :

Madame :

- Marie Delphine NDIAYE, Cellule d'enquêtes et d'Inspection,

Messieurs :

- Ousseynou CISSE, Coordonnateur Cellule d'enquêtes et d'Inspection,

- Moustapha NGAIDO, Cellule d'Inspection des Recours, rapporteur.

SUR L'EXPOSÉ DU DIFFÉREND

Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS), a saisi le Comité de Règlement des Différends, par courrier du 23 mai 2016, enregistré au secrétariat du CRD le 24 mai 2016 sous le numéro 156/CRD, pour solliciter une mission de conciliation sur le différend qui oppose le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale à l'Entreprise des Travaux Publics et Bâtiments (ETPB) dans le cadre de l'exécution du contrat no T 0404/15 relatif aux travaux de construction d'un immeuble R+2 devant abriter le centre de documentation et les archives, la DPRS et l'Inspection du Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS). Le marché d'un montant de 378 393 439 F CFA HTVA est financé par le Projet d'Appui à la Gouvernance Sanitaire (PAGOSAN) dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et le Royaume de Belgique.

40

A l'appui de sa demande, le MSAS a rappelé que l'ordre de service de démarrage des travaux a été transmis à l'entrepreneur le 28 juillet 2015 pour un démarrage effectif le 13 août 2015. Dans le planning d'exécution des travaux, transmis à l'autorité contractante par l'entreprise, les travaux de fondation devaient se terminer le 1er décembre 2015 et ce qui n'a pas été le cas. Un second planning a été proposé par l'entrepreneur qui, non plus, n'a pas été respecté pour défaut d'approvisionnement du chantier en matériaux et de grèves cycliques du personnel pour non paiement de salaires.

Une première mise en demeure a été adressée à l'entreprise le 14 janvier 2016 pour finaliser les travaux de fondation sous quinzaine et un mois plus tard, l'entreprise s'est engagée à finaliser les fondations et les travaux du gros œuvre au plus tard, le 31 mai 2016, à raison d'un plancher par mois.

Toutefois, un mois après l'expiration du délai, pour la livraison du plancher haut Res de chaussée (RDC), le niveau d'exécution de ce dernier n'était guère satisfaisant. Ainsi, l'autorité contractante a fait une nouvelle mise en demeure à l'entreprise qui a demandé et obtenu un nouveau délai jusqu'au 29 avril 2016 ; à la date du 9 mai 2016, le plancher n'était toujours pas finalisé.

Par conséquent, le MSAS ayant constaté qu'après plus de huit (8) mois et demi, soit plus de 70 % du délai contractuel, le niveau d'avancement global des travaux ne dépasse guère les 25 %, et en raison de l'imminence de la fin du projet, qui a été prolongé, exceptionnellement, jusqu'en 2017, le MSAS a sollicité l'ARMP pour trouver une solution à ce problème.

A la suite de ce courrier, l'ARMP a saisi l'entreprise pour un complément d'informations. Celle-ci a reconnu qu'il y a eu du retard dans l'exécution du marché qui était dû à des difficultés auxquelles l'entreprise était confrontée.

Toutefois, l'entreprise prend l'engagement de terminer le chantier dans un délai supplémentaire de quatre (4) mois et, à cet effet, souhaite une prorogation du contrat jusqu'en fin décembre 2016. Par la même occasion, elle promet que le chantier sera approvisionné régulièrement et que le personnel qui posait problème a été changé.

Sur la base de ces informations, une rencontre a été organisée le 4 août 2016 au MSAS, entre les agents de l'ARMP et les responsables du projet au ministère de la santé afin de leur faire part des propositions de l'entreprise.

Le Directeur Général de la Santé a rappelé le contexte qui a généré ce litige et a fait observer que toutes les voies de recours ont été utilisées pour régler le différend. Il a réitéré son souhait de trouver une solution amiable relativement au contentieux. Il a souligné que la date du 13 août 2016 correspond à la fin de l'exécution du contrat et qu'il a déjà entamé une procédure auprès de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) pour la résiliation du marché.

Pour l'entreprise, l'essentiel est de trouver une issue qui ne lèse aucune des parties. Le 8 août 2016, l'entreprise a envoyé ses propositions écrites à l'ARMP qui ont été transmises au MSAS.

Le MSAS et les responsables du PAGOSAN ont proposé de confier en sous-traitance (fourniture et pose) le second œuvre du bâtiment, à des sous-traitants qui seront payés directement par le PAGOSAN sans avance de démarrage du PAGOSAN contrairement à la demande par l'entreprise.

Une dernière rencontre de conciliation a été organisée au MSAS en présence de l'entreprise sous l'égide de l'ARMP pour s'entendre définitivement sur les différentes propositions. Dans ce cadre, un nouveau planning d'exécution a été proposé par l'entreprise qui a eu à travailler en étroite collaboration avec le maître d'œuvre et les experts du PAGOSAN.

Au terme des échanges, un accord a été trouvé entre les deux parties.

Pour matérialiser les points d'accord, les parties ont convenu de la signature du présent procès-verbal de conciliation, présenté aux membres du Comité de Règlement des Différends, réunis en session du 10 août 2016 en présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres CRD, qui l'ont adopté.

SUR LES POINTS D'ACCORD

Les deux parties se sont accordées sur les points suivants :

- Tous les travaux relatifs au second œuvre qui ne peuvent dépasser 40 % du marché seront confiés à des sous-traitants spécialisés dans les différents domaines ;

- La liste des sous-traitants proposée par l'entreprise sera validée par le MSAS ;
- La qualité du matériel proposé par les sous-traitants sera contrôlée avant la pose par le maître d'œuvre ;
- Le montant des prestations des sous-traitants sera négocié entre ces derniers et l'entreprise ;
- Les sous-traitants seront payés directement par le PAGOSAN et non par l'entreprise et le reliquat du montant du second œuvre sera payé à l'entreprise ;
- L'entreprise, qui dispose de facilités de paiement auprès de Diamond Bank, prendra les dispositions financières nécessaires pour approvisionner le chantier dans le cadre d'un financement « revolving » ;
- Un plan de suivi du chantier impliquant notamment la Direction des Infrastructures, des Equipements et de Maintenance(DIEM), le maître d'œuvre, les techniciens de la DAGE et du PAGOSAN sera mis en place pour un suivi hebdomadaire de l'évolution du chantier ;
- Le présent procès-verbal qui tient lieu d'accord entre les parties sera suivi de la signature d'un avenant entre les deux parties pour proroger la durée d'exécution du marché jusqu'au 25 décembre 2016, conformément au planning d'exécution annexé au présent procès-verbal.

L'ARMP, garant de ce protocole, recommande le respect scrupuleux de ses termes, étant entendu qu'il en est le garant.

Lecture faite, les parties et les membres du CRD de l'ARMP ont signé le présent procès-verbal délivré en trois (3) originaux.

Fait à Dakar, le 10 août 2016.

Pour le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale et le PAGOSAN
Dr Papa Amadou Diack
Directeur Général de la Santé et responsable national du PAODES
Dr Vincent Vercruysse
Corresponsable PAODES, coordonnateur du Programme Santé Volet offre
Pour l'Entreprise de Travaux Publics & Bâtiment (ETPB)
Moussa Diallo,
Directeur Général ;
Moussa Guèye,
Secrétaire Général.

Pour le Comité de Règlement des Différends
Mademba GUEYE, Président

Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA
Le Directeur Général de l'ARMP, rapporteur
Saer NIANG

6-4 L'impossibilité pour l'attributaire de livrer le véhicule objet du marché, peut être réglée par la livraison, en substitution, d'un autre véhicule de gamme supérieure.

PROCES-VERBAL DE CONCILIATION DU 11 MAI 2016

DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT

**EN COMMISSION LITIGES AU DIFFEREND OPPOSANT CCBM INDUSTRIE-
ESPACE AUTO ET LE MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE,
PORTANT SUR L'EXECUTION DU MARCHE N° F2789/15 RELATIF A
LA FOURNITURE DE MOYENS LOGISTIQUES POUR LE PROJET DE
FINANCEMENT SANTE NUTRITION (PFSN)**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES :**

VU la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

VU la décision n° 005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

VU la résolution n° 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends ;

VU la lettre en date du 18 avril 2016, reçue le 24 avril 2016, le Ministère de la Santé a saisi le Comité de Règlement des Différends d'une demande d'autorisation de suivre la procédure de passation du marché relatif à la fourniture de moyens logistiques pour le PFSN ;

Monsieur Baye Samba DIOP, Chef de division régulation et affaires juridiques, entendu en son rapport ;

Le Comité de Règlement des Différends, saisi en vertu des dispositions de l'article 30 nouveau de la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de l'Administration ; de l'article 138 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics et de l'article 2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assistée par ses collaborateurs, observateurs ;

Faisant suite aux rencontres tenues dans la Salle de Conférence de l'ARMP entre les parties, le mardi 10 mai 2016, en présence :

-D'unepart, de l'entreprise CCBM Industrie Espace Auto, 55, Avenue Lamine Guèye, BP : 27 256, Dakar-Sénégal, Tel : 221 33 849 65 49, représentée par :

- Monsieur Assane NDIAYE, Directeur d'Exploitation de CCBM ESPACE AUTO ;

- Monsieur Ndiogou SECK, département Appel d'Offres et Marchés de CCBM ESPACE AUTO ;

- D'autre part, du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, représenté par :

- Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Expert en marchés publics du Projet de Financement Santé et Nutrition du Ministère de la Santé et de l'Action sociale ;

- Madame Ndèye Yacine NIANG, Chef de garage central du Ministère de la santé ;

- Madame Marième SY LOUM, Chef de division de la programmation et du suivi des Appels d'Offres du Ministère de la santé et de l'Action sociale ;

- Et enfin de l'ARMP, représentée par :

- Monsieur Baye Samba DIOP Chef de division régulation et affaires juridiques ;

- Monsieur Ousseynou CISSE, Coordonnateur de la cellule d'enquête et d'instruction ;

- Madame TakiaNafissatouFall CARVALHO, Directeur des Affaires juridiques et de la Réglementation, par intérim ;

- Monsieur Moustapha NGAIDO, Commissaire à la cellule d'enquête et d'instruction ;

- Monsieur Alioune Badara DIOP, Direction des Affaires juridiques et de la Réglementation.

SUR L'EXPOSÉ DU DIFFÉREND :

Les motifs de CCBM Industrie-Espace Auto :

CCBM Industrie-Espace Auto déclare que dans le cadre de l'exécution du marché F2789/15 pour la fourniture de moyens logistiques, les véhicules de supervision 4x4 Station Wagon (onze) du lot 2 ont été livrés.

En revanche, les deux berlines, objet du lot n° 4 ne seront pas disponibles dans les délais requis du fait d'un retard intervenu dans la chaîne de production de son constructeur.

L'entreprise CCBM Industrie-Espace Auto exprime son regret de la situation imprévue et indépendante de sa volonté.

Toutefois, aux fins d'une solution heureuse, elle a proposé le même modèle (CheryArrizo) en boîte de vitesse manuelle, ou un autre véhicule qui remplit les mêmes critères de conformité du marché, en l'occurrence la Volkswagen POLO SEDAN avec une boîte de vitesse automatique.

Elle dit que les deux véhicules sont actuellement disponibles dans son stock et peuvent être présentés à la convenance de l'autorité contractante pour essais et inspections.

Les motifs du Ministère de la Santé et de l'Action sociale :

L'autorité contractante affirme que dans le cadre du Projet de Financement Santé et Nutrition (PFSN), le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a lancé un appel d'offres international portant sur l'acquisition de moyens logistiques (véhicules et motos) destinés à la supervision des activités des composantes, en cinq (05) lots séparés :

- Lot 1 : 01 véhicule de direction ;
- Lot 2 : 11 véhicules de supervision 4x4 station wagon ;
- Lot 3 : 10 véhicules de supervision 4x4 Pick up double cabine ;
- Lot 4 : 2 véhicules berline ;
- Lot 5 : 8 motos de supervision.

45

Après évaluation, l'autorité contractante a déclaré attributaire provisoire des lots 2 et 4, le soumissionnaire CCBM Industrie-Espace Auto.

Le lot 2 est constitué de 11 véhicules de supervision 4x4 Station wagon pour un montant de deux cent soixante-sept millions trois cent mille (267 300 000) FCFA TTC.

Le lot 4 est constitué de deux véhicules berline pour un montant de vingt-sept millions (27 000 000) franc CFA TTC.

L'évaluation des lots du marché a fait l'objet d'un avis de non objection de la part de la DCMP et de la Banque mondiale et les contrats y afférents ont été approuvés.

CCBM Industrie-Espace Auto a exécuté le lot 2 à la satisfaction du Ministère de la santé et de l'Action sociale.

Toutefois, selon l'autorité contractante, CCBM Industrie-Espace Auto a été confronté à des difficultés lors de l'exécution du lot 4 (berlines).

L'autorité contractante dit avoir reçu une lettre du 04 février 2016 par laquelle CCBM Industrie-Espace Auto déclare ne pas être en mesure de livrer les deux berlines (CheryArrizo) en boîte de vitesse automatique, en raison du retard intervenu dans la chaîne de production du constructeur, ce qui diffère leur arrivée à Dakar dans la première quinzaine du mois d'avril 2016.

Pour pallier cette situation, CCBM Industrie-Espace Auto a proposé la livraison d'une berline (CheryArrizo) en boîte de vitesse manuelle et d'un véhicule VW POLO SEDAN qui sont disponibles en stock.

Suite à l'avis défavorable du Projet de Financement Santé et Nutrition (PFSN) sur cette proposition, CCBM Industrie-Espace Auto a introduit une nouvelle proposition qui vise à livrer une POLO SEDAN et une JETTA de marque Volkswagen qui sont disponibles, en substitution des véhicules de marque chinoise (CHERRY ARRIZO) proposés dans son offre. Le PFSN a donné son accord de principe.

C'est pourquoi le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a marqué son accord pour la substitution des véhicules de marque chinoise notamment, Cherry Arrizo qui étaient prévus dans l'offre de CCBM Industrie-Espace Auto, par les véhicules POLO SEDAN et JETTA de marque Volkswagen de gamme supérieure, sous réserve de saisir le CRD de l'ARMP.

OBJET DU DIFFÉREND :

Après avoir entendu les deux parties, il apparaît que le litige porte sur la possibilité de substitution des véhicules prévus dans l'offre de l'attributaire par des véhicules de gamme supérieure.

SOLUTION RETENUE :

Les parties ont marqué leur accord pour la substitution des deux véhicules prévus dans l'offre de CCBM Industrie-Espace Auto par des véhicules de gammes supérieures, sous réserve de l'autorisation du Comité de Règlement des différends de l'ARMP.

Les parties ont convenu de la substitution des véhicules de marque chinoise notamment, Cherry Arrizo qui étaient prévus dans l'offre de CCBM Industrie-Espace Auto, par les véhicules POLO SEDAN et JETTA de marque Volkswagen de gamme supérieure.

Vu l'adoption de la solution, le CRD constate l'accord des parties portant sur ladite solution.

L'ARMP est le garant de ce protocole

Lecture faite, les parties et les membres du CRD de l'ARMP ont signé le présent procès-verbal délivré en trois originaux.

Pour CCBM Industrie Espace Auto

Pour le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale

M. Assane NDIAYE

Dr Adjaratou NDIAYE,

Directeur de l'Exploitation

Coordonnatrice du PFSN/MSAS

Mme NdèyeCoumbaGuissé DRAME, DAGE/PFSN

Fait à Dakar le 11 mai 2016.

Pour le Comité de Règlement des Différends

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

7

**LE CRD EST INCOMPETENT
A L'EGARD DES MARCHÉS
DES ASSOCIATIONS DE
DROIT PRIVÉ, DES MARCHÉS
DE CERTAINES SOCIÉTÉS
DE DROIT PRIVÉ ET DES
MARCHÉS DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES OBÉISSANT À
DES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES.**

Pour apprécier les domaines de compétence du CRD, il faut se référer aux textes et articles suivants :

- Articles 11 et 12 de la directive n° 05/2005/CM/UEMOA ;
- Article 31 nouveau Code des Obligations de l'Administration ;
- Article 2 du code des marchés publics ;
- Articles 20 à 24 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

En application de ces dispositions, le CRD s'est déclaré incompétent chaque fois qu'il a été saisi d'une affaire n'entrant pas dans le champ de sa compétence.

C'est ainsi que de 2008 à 2016 le CRD a rendu trente-cinq décisions d'incompétence ne représentant que 2,31% du total du nombre de recours tranchés. En 2016, il a rendu les cinq (5) décisions d'incompétence suivantes :

n° d'ordre	n° et date de la décision	Parties au litige	Motifs d'incompétence invoqués par le CRD
1	n° 062 du 24 février 2016	Société Diaariémou Industrie contre l'association YokuxYokit	YokuxYokit est une société de droit privé et n'est pas une autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des marchés publics
2	n° 68 du 2 mars 2016	Entreprise Idill Global services group contre le Programme des Nations Unis pour le Développement(PNUD)	Le marché litigieux a été lancé selon les règles de procédures spécifiques au PNUD et non selon le Code des marchés publics.
3	n° 094 du 6 avril 2016	GIE Diamono House contre l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES)	L'IPRES est un organe de droit privé disposant de règles internes pour la p assation de ses marchés et n'est pas une autorité contractante au sens de l'article 2 du code des marché publics
4	n° 272 du 7 septembre 2016	Société ECCOTRA contre L'IPRES	- -
5	n° 331 du 26 octobre 2016	Général Industrielle contre Japan International Cooperation System (JICA)	Le marché a été lancé selon les directives de l'approvisionnement pour l'aide non remboursable du Japon et les différends y afférents sont soumis à l'arbitrage

Les motifs d'incompétence invoqués par le CRD sont conformes aux dispositions des textes qui fondent sa compétence ; et les règles de compétence étant d'ordre public, tout organe investi du pouvoir de trancher des litiges doit d'abord vérifier sa compétence avant d'aborder la recevabilité de l'affaire qui lui est soumise.

Nous donnerons à titre d'exemple, les décisions numéros 062 du 24 février 2016 et 068 du 2 mars 2016.

DECISION N° 062/161ARMP/CRD DU 24 FEVRIER 2016

DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

**COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DIAARIEMOU
INDUSTRIE CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE CONCERNANT LA
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE
(DRPCO), LANCEE PAR L'ASSOCIATION YOKUX YOKIT POUR LA**

**CONSTRUCTION DE 110 LATRINES, FABRICATION DE 110 CANARIS
AMELIORES ET LA FOURNITURE DE LAVES-MAINS AU NIVEAU DES VILLAGES
DE POMBANE ET NOMBADANE**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en Ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 5 août 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la résolution n° 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Vu le recours de la société DIAARIEMOIJ Industrie ;

Vu la quittance de consignation du 26 novembre 2015 ;

Monsieur Moussa DIAGNE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP

Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saêr NIANG, Directeur général de l'ARMP, rapporteur général du CRD assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation

Adopte la présente décision

Par lettre du 25 novembre 2015, enregistrée le 27 novembre 2015 au secrétariat du CRD sous le numéro 331/15, la société DIAARIEMU Industrie a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester le rejet de son offre concernant la Demande de Renseignements et de Prix à Compétition ouverte (DRPCO) relative à la construction de 110 latrines, la fabrication de 110 canaris améliorés et la fourniture de 110 lave-mains au niveau des Villages de Pombane et Nombadane, lancée par l'association YokuxYokit.

SUR LA COMPETENCE DU CRD

Considérant que l'article 24 nouveau du Code des obligations de l'Administration (COA) précise que les principes fondamentaux qui régissent les marchés publics s'appliquent aux achats effectués par l'Etat les collectivités locales et leurs établissements publics, par les personnes qui agissent au nom et pour le compte des acheteurs publics et par les organismes dont l'activité est financée majoritairement par des fonds publics déterminés conformément aux dispositions du Code des Marchés publics ;

Qu'en application des dispositions ci-après, l'article 2 du Code des Marchés publics fixe le champ d'application dudit code par énumération exhaustive des personnes morales auxquelles il s'applique ;

Considérant que le recours de la société DIAAREMOU Industrie vise un marché passé par l'association YokuxYokut qui est de droit privé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21, alinéa 2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) le Comité de Règlement des Différends (CRD) est compétent pour recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu'à leur objet ;

Qu'il résulte des faits exposés que l'association YokuxYokut n'est pas une autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des Marchés publics, et, en conséquence, n'est pas soumise audit Code ;

Qu'ainsi, le CRD doit se déclarer incompétent ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que le recours de la société DIAARIEMU Industrie concerne un marché lancé par l'association YokuxYokut qui est une association de droit privé et qui n'est pas une autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des

Marchés publics ;

2) Dit que le CRD est incompétent pour statuer sur le recours ;

3) Ordonne la restitution de la consignation ;

4) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à la société DIAARIETOU Industrie, à l'Association YokuxYokit ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des Marchés publics.

Le président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général,

Rapporteur

Saer NIANG

**DECISION N 0 068/16/ARMP/CRD DU 02 MARS 2016 DU COMITE DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN**

**COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE IDILL
GLOBAL SERVICES GROUP CONTESTANT LE MODE D'EVALUATION ET
D'ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME
INFORMATISE DE SUIVI EVALUATION (SISE), OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
REFERENCE DAO/PNUD/PUDC/078/2015 , LANCE PAR LE PROGRAMME DES
NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D'URGENCE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PUDC)
DE L'ETAT DU SENEGAL.**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu la loi 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration, modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu l'Accord type d'assistance de base conclu entre le Gouvernement du Sénégal et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), signé le 4 juillet 1987 à Dakar ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu le décret 2013-1385 du 01 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la résolution n° 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends ;

Vu le « PROGRAMME D'URGENCE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE » signé le 05 février 2015 entre l'Etat du Sénégal et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ;

Vu le recours de l'entreprise I.D.I.L.L GLOBAL SERVICES GROUP, par lettre datée du 15 février 2016, reçue le lendemain à l'ARMP, enregistrée sous le n c 045 au secrétariat du CRD ;

Vu la quittance de consignation du 16 février 2016 ;

Madame Catherine Aïssata BA, Commissaire à la Cellule d'instruction des Recours, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur Général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assisté de ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération

Par lettre du 15 février 2016, l'entreprise I.D.I.L.L GLOBAL SERVICES GROUP a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester le mode d'évaluation et d'attribution du marché susvisé.

SUR LA COMPETENCE

Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le marché précité a pour objet le recrutement d'un cabinet chargé de la mise en place d'un système informatisé de suivi évaluation dans le cadre du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) dont la gestion est dévolue au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en vertu d'une convention dénommée « PROGRAMME D'URGENCE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE », signée le 05 février 2015 entre l'Etat du Sénégal et le PNUD ;

Considérant que le PROGRAMME D'URGENCE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE » stipule en sa Partie VII que le présent document constitue l'instrument visé à l'article I^{er} de l'Accord type d'assistance de base conclu entre le Gouvernement du Sénégal et le PNUD, signé le 4 juillet 1987 à Dakar

Qu'il ressort de l'examen de cet instrument juridique que « Les documents d'appel d'offres devront être validés par la contrepartie nationale en ce qui concerne les spécifications techniques, les implantations, localisations, et nature/quantité des ouvrages à réaliser avant que les consultations ne soient lancées par le PNUD selon les procédures spécifiques du PNUD.

Procédures de recrutement et d'acquisition des biens et services : « ...L'ensemble des acquisitions des biens et services devront bénéficier du mécanisme de procédures accélérées du PNUD... L'acquisition sera réalisée en accord avec les règles et règlements du PNUD.... » ;

Qu'au regard de ces clauses, il apparaît que le marché litigieux a été lancé selon les règles de procédures spécifiques du PNUD, et non selon les règles de procédures du Code des Marchés publics du Sénégal ;

Considérant, ainsi, que le Comité de Règlement des Différends n'est pas l'organe compétent pour arbitrer le différend né lors de la passation de ce marché ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de se déclarer incompétent et d'ordonner la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que le document intitulé « PROGRAMME D'URGENCE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE » stipule que l'ensemble des acquisitions des biens et services à réaliser dans le cadre du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) devront bénéficier des mécanismes de procédures accélérées du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ;
- 2) Constate que le marché litigieux a été lancé selon les règles de procédures spécifiques du PNUD ;
- 3) Dit que le Comité de Règlement des Différends n'est pas l'organe compétent pour arbitrer le différend né lors de la passation de ce marché ;
- 4) Se déclare incompétent ;
- 5) Ordonne la restitution de la consignation ;
- 6) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à l'entreprise I.D.I.L.L GLOBAL SERVICES GROUP, au Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) et au

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général,

Rapporteur

Saer NIANG

8

LES RECOURS DECLARÉS IRRECEVABLES PAR LE CRD

De 2008 à 2016, le CRD a déclaré irrecevables 345 recours initiés devant lui, soient 22,73% du total des recours tranchés (1518 recours), donc plus du cinquième.

En 2016, le nombre de recours irrecevables est de 50 en valeur absolue et 18,31 % en valeur relative.

Ces 50 décisions d'irrecevabilité se répartissent en causes ainsi qu'il suit :

n° d'ordre	Causes d'irrecevabilité	Nombre de décisions
1	Irrecevabilité pour forclusion (saisine hors délai)	33
2	Irrecevabilité pour absence de recours gracieux préalable	6
3	Irrecevabilité pour absence de consignation	4
4	Irrecevabilité pour inobservation du délai d'attente du recours gracieux	
5	Irrecevabilité pour saisine avant notification de l'avis d'attribution provisoire	1
6	Irrecevabilité pour absence de grief	1
	Total	50

57

Même si le nombre Total de décisions d'irrecevabilité (50) a augmenté par rapport aux deux années précédentes (49 en 2014 et 39 en 2015), on note qu'en 2016, il y a six (6) causes d'irrecevabilité alors qu'il y en avait plus pendant les deux années passées ; ainsi, trois causes d'irrecevabilité qui avaient été notées pendant la période 2014 à 2015 n'ont pas été enregistrées en 2016, à savoir :

- Irrecevabilité pour avoir effectué deux recours gracieux ;
- Irrecevabilité pour contestation de l'avis d'appel d'offres soulevée après publication de l'attribution provisoire ;
- Irrecevabilité pour non production de document prouvant l'allégation.

Cette diminution des causes d'irrecevabilité serait, peut-être, un signe de la maîtrise progressive des procédures par les acteurs de la commande publique.

Mais en la matière, des lacunes demeurent toujours comme en témoigne ce qui suit.

8-1 Irrecevabilité pour forclusion

Il résulte des articles 89 et 90 du code de 2014 que tout candidat à une procédure d'attribution d'un marché peut, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux, auquel celle-ci est tenue de répondre dans un délai de 3 jours ouvrables; qu'en l'absence d'une suite favorable à son recours, le requérant

dispose de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai, susvisé imparti à ladite autorité, pour présenter un recours au CRD.

S'appuyant sur ces dispositions, le CRD pendant l'année 2016 a rendu 50 décisions d'irrecevabilité, dont les 33 (soient 66%) ont pour cause la forclusion du requérant, c'est-à-dire que celui-ci a attendu l'expiration du délai de trois jours qui lui est réservé pour saisir tardivement le CRD.

Dans la plupart des cas, le CRD a bien computed les délais et s'est rendu compte que le requérant a effectivement attendu plus de trois (3) jours francs pour initier son recours.

En effet, les délais sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans les délais le jour de son point de départ, ni le dernier jour. Il faut également ajouter que les jours non ouvrés, non plus, ne sont pas comptés, notamment les samedis et les dimanches.

L'importance relative de cette cause d'irrecevabilité montre que la computation des délais n'est pas encore maîtrisée ; d'où la nécessité d'une action de formation.

**DECISION N O 022/16/ARMPICRD DU 20 JANVIER 2016 DU COMITE DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES
SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ANGELIQUE INTERNATIONAL LIMITED
CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISoire DU LOT 2 DU MARCHE
RELATIF A L'ACQUISITION DE MATERIELS AGRICOLES ET D'ENGINS DE
TERRASSEMENT, LANCE PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'EQUIPEMENT RURAL.**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSIONLITIGES,**

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi no 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Angélique International Limited du 11 janvier 2016 ;

Vu la quittance de consignation du 13 janvier 2016 ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saêr NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci-après

Par lettre reçue le 13 janvier 2016 au service courrier de l'ARMP et enregistrée au secrétariat du CRD sous le numéro 010/16, la société Angélique International Limited a saisi le CRD pour contester l'attribution provisoire du lot 2 du marché relatif l'acquisition de matériels agricoles et d'engins de terrassement, lancé par le Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural,

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel à la concurrence, puis le CRD. dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de trois (3) jours qui lui est imparti pour répondre ;

Considérant qu'il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l'attribution provisoire du marché précité dans le quotidien « Le Soleil » du 05 janvier 2016, la société Angélique International Limited a adressé un recours gracieux au Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural par lettre du 06 janvier 2016, reçue le même jour pour contester le rejet de son offre pour le lot 2 ;

Que non satisfait de la réponse reçue le 08 janvier 2016 de l'autorité contractante, le requérant a introduit un recours contentieux par lettre reçue le 13 janvier 2016 au service courrier de l'ARMP ;

Qu'au regard des articles 89 et 90 susvisés, le recours contentieux aurait dû parvenir au CRD au plus tard le 12 janvier 2016, soit trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante au recours gracieux ;

Que dès lors, le recours reçu le 13 janvier 2016 à l'ARMP doit être déclaré irrecevable, pour tardiveté ;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation ;

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que la société Angélique International Limited a introduit un recours auprès du Comité de Règlement des Différends au-delà du délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ;
- 2) Dit que le recours contentieux a été introduit tardivement au regard de l'article 90 du Code des Marchés publics ;
- 3) Déclare, en conséquence, irrecevable ledit recours ;
- 4) Ordonne la confiscation de la consignation ;
- 5) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la société Angélique International Limited, au Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics ;

Le président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général,

Rapporteur

Saer NIANG

8-2 Irrecevabilité pour absence de recours gracieux préalable

L'article 88 du code de 2011 stipule que : « Tout candidat à une procédure d'attribution d'un marché est habilité à saisir la personne responsable du marché d'un recours gracieux ».

Par contre, l'article 89 du code de 2014 est ainsi libellé : « Tout candidat à une procédure d'un marché doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir la personne responsable du marché d'un recours gracieux ».

Ainsi, alors que le recours gracieux auprès de l'autorité contractante n'était qu'une simple faculté donnée au candidat à la commande publique sous l'empire du code de 2011, comme du code de 2007, par contre il est devenu maintenant une obligation avec le code de 2014.

Donc actuellement tout soumissionnaire qui a des contestations à faire à l'égard d'un marché, doit, avant de saisir le CRD, adresser un recours gracieux à la personne responsable du marché, sinon le CRD déclare son action irrecevable.

Cette innovation du code est venue à l'heure parce que si le contentieux peut être réglé au niveau de l'autorité contractante, il vaut mieux s'en arrêter là ; mais il est exceptionnel de voir une autorité contractante donner une suite favorable à un recours gracieux.

Cependant le nombre total de décisions d'irrecevabilité enregistrées pour défaut de recours gracieux préalable étant relativement faible (6 soit 12% du total des décisions d'irrecevabilité), on peut penser que cette nouveauté du code est maîtrisée par la plupart des acteurs de la commande publique.

61

**DECISION NO 001/16/ARMP/CRD DU 6 JANVIER 2016 DU COMITE DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE
RECOURS DE LA SOCIETE GANDIOL PORTANT SUR L'APPEL D'OFFRES POUR
LA CONSTRUCTION DE MAGASINS DE STOCKAGE DU RIZ DANS LA VALLEE
DU FLEUVE SENEGAL, LANCE PAR LA SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT
ET D'EXPLOITATION DES TERRES DU DELTA DU FLEUVE SENEGAL ET DES
VALLEES DU FLEUVE SENEGAL ET DE LA FALEME (SAED)**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 02014-1212 du 22 septembre juillet 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la SOCIETE GANDIOL en date du 28 décembre 2015 ;

Vu la quittance de consignation du 29 décembre 2015 ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Moustapha NGAIDO, Commissaire à la cellule d'instruction des recours, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD)) ;

De M. Saër NIANG€ Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après

Par lettre du 28 décembre 2015, enregistrée le lendemain au service courrier de l'ARMP et au Secrétariat du CRD sous le numéro 359/CRD, la société GANDIOL a saisi le Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) pour contester l'avis d'attribution provisoire du marché relatif à la construction de magasins de stockage du riz dans la Vallée du Fleuve Sénégal, lancé par la Société nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu'aux termes de l'article 89 du Code des Marchés publics, tout candidat à une procédure d'attribution d'un marché doit préalablement à tout recours contentieux, saisir la personne responsable du marché d'un recours gracieux, par une notification écrite indiquant les références de la procédure de passation et exposant les motifs de sa réclamation par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé ;

Considérant que la personne responsable est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de trois (3) jours ouvrables, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d'un rejet implicite du recours gracieux ;

Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 90 du Code des Marchés publics, c'est seulement en l'absence de suite favorable de son recours gracieux que le requérant dispose de trois (03) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou du rejet implicite de son recours gracieux pour présenter un recours au Comité de Règlement des Différends ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu'il apparaît de l'instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que la séance d'ouverture des plis s'est déroulée le 12 octobre 2015 et que le requérant a ainsi obtenu le procès-verbal et que l'avis d'attribution provisoire du marché susvisé a été publié dans le Journal « Le Soleil » du mercredi 23 au vendredi 25 décembre 2015 conformément à l'article 84 du Code des Marchés publics ;

Considérant que, suite à cette publication, le requérant n'a pas porté sa réclamation auprès de l'Autorité contractante par un recours gracieux pour contester les motifs du rejet de son offre ;

Considérant, par ailleurs, que le recours gracieux est un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du CRD, conformément à l'article 89 du Code des Marchés publics ;

Considérant que le requérant a introduit directement auprès du CRD un recours, par la correspondance en date du 28 décembre 2015 et enregistrée le lendemain pour contester l'attribution provisoire du marché au Consortium d'Entreprises Multiprest Afrique SARL ;

Qu'en conséquence, l'entreprise GANDIOL n'ayant pas observé la formalité de saisine obligatoire de l'autorité contractante, son recours doit être déclaré irrecevable ;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu d'ordonner la confiscation de la consignation.

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que l'avis d'attribution du marché susvisé a été publié dans le journal « Le Soleil » du 23 au 25 décembre 2015 ;
- 2) Constate que la société GANDIOL a introduit un recours auprès du CRD, en omettant la procédure du recours gracieux auprès de la SAED ;
- 3) Déclare irrecevable ledit recours ;
- 4) Ordonne la confiscation de la consignation ;
- 5) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à la société GANDIOL, à la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Valléesdu Fleuve

Sénégal et de la Falémé (SAED) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général,

Rapporteur

Saer NIANG

8-3 Irrecevabilité pour absence de consignation

En vertu de l'article 90, deuxième alinéa, « le recours du candidat à une procédure d'attribution n'est recevable que s'il invoque une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et est accompagné de la pièce attestant du paiement d'une consignation dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances » .

Le non-paiement d'une consignation entraîne donc l'irrecevabilité du recours.

Le paiement d'une consignation est une nouveauté du code de 2014, permettant, entre autres, de décourager les recours fantaisistes.

Néanmoins, il faut signaler que les cas d'irrecevabilité pour absence de consignation ont doublé entre 2015 et 2016, en effet alors qu'il n'y avait que deux cas en 2015, (décisions du CRD numéros 10 et 347) on en dénombre 4 en 2016.

DECISION NO 039/16/ ARMP/CRD DU 10 FEVRIER 2016 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE MEUBLES DE CARTHAGE CONTESTANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DES PRIX A COMPETITION OUVERTE LANCEE PAR L'OFFICE NATIONAL D'ASSAINISSEMENT DU SENEGAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi no 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu le décret n° 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la résolution n° 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends ;

Vu le recours de Meubles de Carthage ;

Après avoir entendu le rapport de Madame Henriette Diop TALL présentant les moyens et conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Mr Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération :

Par correspondance non datée, reçue au service courrier de l'ARMP le 4 février 2016, Meubles de Carthage a saisi le CRD pour contester les spécifications techniques de la Demande de Renseignements et de Prix à Compétition ouverte publiée par l'Office national de l'Assainissement du Sénégal.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 90 alinéa 2 du Code des Marchés publics que la saisine du Comité de Règlement des Différends se fait par notification écrite, que le recours n'est recevable que s'il invoque une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et est accompagnée de la pièce attestant du paiement d'une consignation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances ;

Considérant que postérieurement à la publication dans le journal « le Soleil » du 1er février 2016 de la Demande de Renseignements et de Prix à Compétition ouverte (DRPCO) par l'Office national de l'Assainissement du Sénégal. le requérant a saisi le CRD pour contester les spécifications techniques de la DRPCO sans satisfaire à la formalité préalable de la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations ;

Que son recours est dès lors irrecevable en application de l'article 90 précité.

PAR CES MOTIFS

1) Constate que Meubles de Carthage a saisi le CRD sans satisfaire à la formalité préalable de la consignation ;

2) Déclare son recours irrecevable ;

3) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à Meubles de Carthage, à l'Office national de «Assainissement du Sénégal, ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général,

Rapporteur

Saer NIANG

66

8-4 Irrecevabilité pour inobservation du délai d'attente du recours gracieux

Il résulte des articles 89 et 90 du code de 2014 que si le candidat à une procédure d'attribution d'un marché saisit la personne responsable du marché d'un recours gracieux, celle-ci a un délai de trois jours ouvrables pour y répondre et qu'au-delà de ce délai le défaut de réponse sera constitutif d'un rejet implicite dudit recours ; qu'en l'absence de suite favorable à son recours gracieux le requérant dispose de trois(3) jours ouvrables, à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai imparti à cette dernière pour répondre, pour saisir le CRD.

Donc le candidat ne peut ni saisir l'autorité contractante et le CRD en même temps, ni saisir le CRD sans avoir reçu la réponse défavorable de l'autorité contractante ou avant l'expiration du délai imparti à cette dernière pour répondre.

Le CRD applique cela avec pertinence en affirmant que :

- « Le requérant qui saisit l'autorité contractante d'un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l'expiration du délai imparti à l'autorité contractante, constitutif d'un rejet implicite du recours gracieux » ;
- « Le recours devant le CRD ayant été introduit avant l'expiration du délai de réponse imparti à la personne responsable du marché, il doit être déclaré irrecevable » ;

- « Le recours contentieux étant parvenu au CRD avant l'expiration du délai accordé à l'autorité contractante pour répondre au recours gracieux, il est donc prématuré et doit être déclaré irrecevable » ;
- « Le requérant ayant saisi l'autorité contractante et le CRD de manière concomitante, il s'ensuit que le recours est prématuré ».

Le nombre de décisions d'irrecevabilité pour inobservation du délai d'attente du recours gracieux, qui est de cinq (5) en 2016 est le même qu'en 2015 et a très fortement baissé par rapport à 2014 où il y avait 16 cas d'irrecevabilité pour inobservation du délai d'attente du recours gracieux.

DECISION N O 200/16/ARMP/CRD DU 13 JUILLET 2016 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DES ETS ALGA Sari RELATIF A L'APPEL D'OFFRES LANCE PAR LA SENELEC POUR L'AMELIORATION DE LA QUALITE DESERVICE AVEC LA CONSTRUCTION DE POSTES DE MANŒUVRES PROTEGES, LA CREATION DE SYSTÈME DE PROTECTION DE DEPARTS SECOURS A LA DELEGATION REGIONALE DU SUD.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSIONLITIGES,

VU la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

VU le décret n° 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation ;

VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU la décision n° 005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

VU la résolution 09/12 du 13 décembre 2012 du Conseil de Régulation instituant le versement d'une consignation pour la saisine du CRD ;

VU la résolution n° 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP ;

VU le recours de la société ETS ALGA Sarl, enregistré le 05 juillet 2016 ;

Monsieur Ousseynou CISSE, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRC), assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

ADOpte LA PRÉSENTE DÉCISION

Par lettre reçue le 05 juillet 2016 à l'ARMP, la société ETS ALGA Sarl a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester le rejet de son offre dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la SENELEC pour l'amélioration de la qualité de service avec la construction de postes de manœuvres protégés, la création de système de protection de départs secours à la Délégation régionale du Sud.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, que tout candidat à un marché public doit préalablement à tout recours contentieux, saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel à la concurrence, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de trois (3) jours ouvrables, imparti à l'autorité contractante pour répondre ;

68

Considérant qu'après la parution dans le journal « Le Soleil » du 1^{er} juillet 2016 de l'avis d'attribution provisoire du marché relatif à l'amélioration de la qualité de service avec la construction de postes de manœuvres protégés, la création de système de protection de départs secours à la Délégation régionale du Sud, la société Ets ALGA Sarl a saisi la SENELEC d'un recours gracieux, par lettre reçue le même jour, pour contester les résultats de l'attribution ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le requérant a accusé réception, le jeudi 07 juillet 2016, du courrier transmis par voie électronique par SENELEC auquel l'autorité contractante a joint sa réponse par lettre datée du 05 juillet 2016 ;

Considérant que le requérant a saisi le CRD par lettre reçue le 05 juillet 2016 ;

Qu'ainsi, le recours d'Ets ALGA Sarl au CRD, intervenu le 05 juillet 2016, a été exercé avant la réception de la réponse de SENELEC au recours gracieux et avant l'expiration du délai de trois (03) jours accordé à ce dernier, conformément à la réglementation ;

Que dès lors, le recours d'Ets ALGA Sarl est prématuré et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu d'ordonner la confiscation de la consignation.

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que la société ETS ALGA Sarl a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux puis le CRD sans attendre l'expiration du délai accordé à SENELEC pour répondre ;
- 2) Dit que le recours au CRD est prématuré ;
- 3) Le déclare, en conséquence, irrecevable ;
- 4) Ordonne la confiscation de la consignation ;
- 5) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à ETS ALGA Sarl, à SENELEC ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général,

Rapporteur

Saer NIANG

69

8-5 Irrecevabilité pour saisine avant notification de l'avis d'attribution provisoire

Il résulte des dispositions des articles 89 et 90 du Code de 2014 que les contestations relatives à l'évaluation des candidats et au rejet des offres doivent être faites après la publication de l'avis d'attribution provisoire ou de la notification de la décision d'attribution.

Se fondant sur lesdites dispositions le CRD déclare irrecevables tous les recours faits avant la publication de l'avis d'attribution provisoire et relatifs auxdites contestations.

Telle a été la position du CRD dans l'affaire opposant l'EBGET et la Commune de Golf Sud (décision n°381 du 7 décembre 2016) où la requérante avait fondé son recours sur le procès-verbal d'ouverture des plis au lieu d'attendre la notification de l'avis d'attribution provisoire du marché.

DECISION N° 381/16/ARMP/CRD DU 07 DECEMBRE 2016

**DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE DE BATIMENT GENIE CIVIL
ELECTRICITE TELECOM ET FOURNITURES DE MATERIELS (EBGET) PORTANT**

**SUR LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION
OUVERTE RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE
LA FEMME, LANCEE PAR LA COMMUNE DE GOLF SUD**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

VU la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

VU le décret no 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre juillet 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics

VU la résolution n° 09-12 du 13 décembre 2012 instituant le versement d'une consignation pour la saisine du Comité de Règlement des Différends ;

VU la résolution no 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends ;

VU le recours de l'entreprise EBGET du 17 novembre 2016, reçu le 21 novembre 2016 ;

VU le certificat de dépôt chèque/virement n° 000480 du 22 novembre 2016, faisant office de quittance de consignation ;

Après avoir entendu le rapport de Mr Moustapha NGAIDO, rapporteur présentant les moyens et conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre enregistrée le 21 novembre 2016 au Secrétariat du CRD sous le numéro 345/CRD, l'entreprise EBGET a saisi le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) pour contester la Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRP-CO) relative à la construction de la maison de la femme, lancée par la Commune de Golf Sud.

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 6 de l'arrêté no 107 du 7 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de Demande de Renseignements et de Prix en application de l'article 78 du Code des Marchés publics, tout candidat à une procédure d'attribution d'une DRP à compétition ouverte doit préalablement à tout recours contentieux, saisir la personne responsable du marché d'un recours gracieux, par une notification écrite indiquant les références de la procédure de passation et exposant les motifs de sa réclamation par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé ;

Considérant que le recours doit être exercé dans un délai de trois (3) jours francs et ouvrés, à compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel d'offres ;

Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de deux (2) jours ouvrables, au-delà duquel, le défaut de réponse sera constitutif d'un rejet implicite du recours gracieux ;

Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 7 dudit arrêté, c'est seulement en l'absence de suite favorable de son recours gracieux que le requérant dispose de deux (02) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou du rejet implicite de son recours gracieux pour présenter un recours contentieux au Comité de Règlement des Différends ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 8 du de l'arrêté no 107 du 7 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de Demande de Renseignements et de Prix en application de l'article 78 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que suite à la notification du procès-verbal d'ouverture des plis de la DRP-CO susvisée en date du 4 novembre 2016, la société EBGET a, par un courrier du 17 novembre 2016, saisi l'autorité contractante pour contester le fait de ne pas avoir mentionné dans le procès-verbal d'ouverture des plis ses états financiers, ainsi que le CV de l'ingénieur exigé par la DRP-CO ;

Considérant que l'autorité contractante lui a répondu par un courriel envoyé à 15h 16 minutes le même jour en lui renvoyant le procès-verbal d'ouverture des plis dans lequel aucune mention relative à l'absence des documents contestés n'apparaît ;

Considérant que l'autorité contractante a envoyé un courrier le même jour à 15h 46 mn notifiant à l'entreprise EBGET le rejet de son offre ;

Considérant qu'il apparait de l'instruction que le recours de l'entreprise EBGET porte sur le procès-verbal d'ouverture des plis ;

Considérant que le recours a été introduit avant la notification de l'avis d'attribution provisoire de la DRP-CO ;

Considérant que le PV d'ouverture des plis, qui n'est pas un acte faisant grief, ne constitue qu'une étape dans le processus d'attribution de la DRP-CO ;

Qu'en conséquence, le recours gracieux, introduit avant la notification du rejet de l'offre du requérant, est prématuré ;

Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable et d'ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que l'entreprise EBGET a introduit un recours gracieux auprès de l'autorité contractante, avant la notification du rejet de son offre ;
- 2) Constate que le recours porte sur le procès-verbal d'ouverture des plis ;
- 3) Déclare que le recours gracieux ne peut être introduit que contre la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer la DRP-CO ;
- 4) Déclare, en conséquence, le recours contentieux de l'entreprise EBGET irrecevable, car le recours gracieux n'a pas été introduit contre la décision d'attribution de la DRP-CO ;
- 5) Ordonne la confiscation de la consignation ;
- 6) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à l'Entreprise de Bâtiment Génie-civil Electricité Telecom (EBGET), à la Commune de Golf Sud, ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général,

Rapporteur

Saër NIANG

8-6 Irrecevabilité pour absence de grief

Suite au marché lancé par la Commune de Diamgnadio, l'entreprise LampFall Bâtiment a saisi le CRD d'un recours avant la date de l'attribution provisoire du marché à l'entreprise ECOTRA.

Ainsi, la requérante ne pouvait exciper d'un acte de l'autorité contractante lui faisant grief ; donc par décision n° 57 du 24 février 2016, le CRD a déclaré son recours irrecevable.

Cette décision du CRD se fonde sur les dispositions des articles 89 et 90 du code de 2014 en vertu desquelles le recours n'est recevable que si, entre autres, le candidat invoque une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics.

DECISION N O 057/16/ARMP/CRD DU 24 FEVRIER 2016

DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSIONLITIGES SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE LAMP FALL BATIMENT RELATIF AU MARCHE POUR LA CONSTRUCTION ET LA CLOTURE DES CENTRES DE DEVELOPPEMENT FILIERE MIL ET MAIS LANCE PAR LA COMMUNE DE DIAMAGADIO

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSIONLITIGES,

73

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu le décret n° 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la résolution n° 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends ;

Vu le recours de l'entreprise LampFall Bâtiment ;

Vu la quittance de consignation du 11 février 2016 ;

Après avoir entendu le rapport de Madame Henriette Diop TALL présentant les moyens et conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP

Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération;

Par correspondance du 10 février 2016. Reçue le lendemain au service courrier de l'ARMP, l'entreprise LampFall Bâtiment a saisi le CRD d'un recours relatif au marché, référencé DRP-CO no 01/2015/COM-DIAMA/PAFA, lancé par la Commune de Diamagadio, suite à une demande de renseignements et de prix à compétition ouverte, pour la construction et la clôture des centres de développement filière mil et maïs au niveau des villages de Gouye MadiBouri et Wintinkou.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte des articles 6 et 7 de l'arrêté n 0 00107 du 7 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix que tout candidat à une procédure d'attribution d'une demande de renseignements et des prix à compétition ouverte doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir la personne responsable du marché d'un recours gracieux par une notification écrite indiquant les références de la procédure de passation et exposant les motifs de sa réclamation par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé ;

Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de deux (02) jours ouvrables, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d'un rejet implicite du recours gracieux ;

Considérant qu'en l'absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose d'un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou du rejet implicite de son recours gracieux pour présenter un recours au Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Considérant que l'application de ces dispositions suppose que le candidat évincé ait eu de l'autorité contractante une notification, portant sur le rejet de son offre et les résultats de l'attribution provisoire du marché par écrit ou par tout autre moyen, et ce, pour l'exercice des recours gracieux et contentieux auprès, respectivement, de l'autorité contractante et du CRD ;

Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ressort de l'instruction du dossier qu'au moment de la saisine du CRD soit le 11 février 2016, l'attribution provisoire du marché à ECOTRA, pour les deux lots, n'était pas encore intervenue,

que cette attribution provisoire n'a eu lieu que le 16 février 2016 et a été publiée par voie d'affichage à la sous-préfecture de Diamagadio le même jour conformément à la réglementation pour les collectivités locales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au moment de la saisine du CRD, le requérant ne pouvait exciper d'un acte administratif de l'autorité contractante lui faisant grief pour justifier l'exercice de son droit de recours au CRD qui doit être précédé d'un recours administratif préalable dit gracieux ;

Qu'il s'ensuit que ce recours contentieux est prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

Qu'il y a lieu ainsi de le déclarer irrecevable parce que prématuré ;

Considérant que le recours n'a pas prospéré, il y a lieu d'ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que l'attribution provisoire du marché à la SARL ECOTRA, pour les deux lots, a eu lieu le 16 février 2016 ;
- 2) Constate qu'au moment de la saisine du CRD, soit le 11 février 2016, l'entreprise LampFall Bâtiment n'a pu exciper d'un acte de l'autorité contractante lui faisant grief ;
- 3) Dit, en conséquence, que le recours porté devant le CRD est prématuré ;
- 4) Le déclare, en conséquence, irrecevable ;
- 5) Ordonne la confiscation de la consignation ;
- 7) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l'entreprise LampFall Bâtiment, à la mairie de Diamagadio ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le président
Mademba GUEYE

Les membres du CRD		
Samba DIOP	Boubacar MAR	Cheikhou Issa SYLLA
	Le Directeur Général,	
	Rapporteur	
	Saer NIANG	

9

**LA COMMISSION DES MARCHÉS
QUI REJETTE PAR DÉCISION
MOTIVÉE UNE OFFRE
ANORMALEMENT BASSE NE
VIOLE PAS LA LOI**

(ARTICLE 59-4 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS)

Il résulte de l'article 59-4 du code des marchés publics de 2014 qu'il appartient à la commission des marchés de rejeter par décision motivée une offre qu'elle juge anormalement basse et après avoir demandé des informations et explications de nature à permettre de juger du caractère anormalement faible ou élevé de l'offre financière en tenant compte, en particulier, des sous-détails des prix, de l'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés.

Ainsi, même si une offre manifestement basse par rapport aux prix fixés par les autres soumissionnaires pourrait être suspecte, parce que pouvant traduire la volonté d'un candidat de gagner à tout prix le marché, l'autorité contractante, même si elle a un pouvoir d'appréciation, en la matière, le code lui fait obligation, avant de rejeter une offre qu'elle juge anormalement basse, de motiver sa décision.

Donc la commission des marchés peut demander aux candidats des précisions utiles concernant les sous-détails des prix proposés afin d'en apprécier la réalité économique et rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge anormalement basse si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique.

En conséquence, une offre ne peut être rejetée par la commission des marchés sans qu'il ne soit demandé, au préalable et par écrit, au candidat de fournir des précisions ou justificatifs sur la composition de l'offre financière afin d'en vérifier la réalité économique.

C'est pourquoi dans l'affaire opposant la société Computer Land et le Ministère de l'Education nationale, le DAGE dudit ministère a demandé à ladite société de justifier les sous-détails du prix, entre autres, du duplicopieur RISO objet de son offre avec un prix unitaire de 780 000frs CFA, alors que les attestations émanant du fabricant RISO établissent que ledit prix unitaire était de 1.351.271frs CFA, soit une différence substantielle de 571.271 frs CFA.

Pour se justifier, la société Computer Land faisait état du bénéfice de conditions exceptionnellement favorables pour fournir les produits et l'économie résultante des solutions techniques adoptées.

Ne pouvant pas rapporter la preuve de ces faits, et ne faisant pas partie des partenaires habilités à représenter la marque RISO au Sénégal, son offre a été écartée par la commission parce qu'anormalement basse.

Son recours, fondé sur la violation de l'article 59 du code des marchés publics et du principe de libre accès à la concurrence, a été rejeté par le Comité de Règlement des Différends (décision du CRD n°002 du 6 janvier 2016).

**DECISION NO 002/16/ARMP/CRD DU 06 JANVIER 2016 DU COMITE DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION**

**LITIGES STATUANT SUR LE RECOURS DE COMPUTER LAND
CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISoire DU MARCHE RELATIF A
L'EQUIPEMENT DES IA et IEF DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
EN MATERIELS INFORMATIQUES ET DE REPROGRAPHIE**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES**

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Computer Land du 17 décembre 2015

Vu la quittance de consignation du 17 décembre 2015 ;

Après avoir entendu le rapport de Madame Henriette Diop TALL, de la Cellule d'Enquêtes et Inspections, présentant les moyens et conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlements des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens ci-après développés :

Par courrier du 17 décembre 2015, reçu le même jour au service courrier de l'ARMP, Computer Land a saisi le CRD pour contester l'attribution provisoire du marché, relatif à l'équipement en matériels informatiques et de reprographie pour les Inspections d'Académie (IA) et les Inspections de l'Education et de la Formation (IEF), lancé par la Direction de l'Administration générale et de l'Equipeement (DAGE) du Ministère de l'Education nationale.

SUR LES FAITS

Le Ministère de l'Education nationale a obtenu des crédits du Budget Consolidé d'Investissement, soit 480.000.000 FCFA, destinés à l'acquisition de matériels informatiques et de reprographie (ordinateur, portable, ordinateur de bureau, onduleur, imprimante et duplicateur) pour les IA et les IEE.

C'est à cet effet qu'il a fait publier un Avis Général de Passation des Marchés dans le quotidien « Le Soleil » n° 13353 du 28 novembre 2014 puis un avis d'appel d'offres pour le marché AO n° 14/15 BCI dans le même quotidien du 28 juin 2015.

A l'ouverture des plis, 13 offres ont été reçues et s'établissent comme suit :

- Bureautic -Diffusion : 939.752.000 FCFA TTC

- Baye Computer : 368.543.500 FCFA TTC

- Office Informatique : 660.466.237 FCFA TTC
- Computer Land : 385.340.800 FCFA TTC
- Tewa System Service : 580.560.000 FCFA TTC
- Général Logistic : 352.067.750 FCFA TTC
- Pico Mega : 456.990.400 FCFA TTC
- Eccorel : 895.000.000 FCFA TTC
- Sesa Technologie : 707.681.400 FCFA TTC
- Oumou Informatique : 468.693.050 FCFA TTC
- Touré Equipement : 719.953.235 FCFA TTC
- Plateforme Technologie : 950.944.555 FCFA TTC
- TCS : 490.555.500 FCFA TTC.

Après évaluation des offres et notification aux candidats de l'avis d'attribution provisoire du marché au profit de Oumou Informatique pour un montant de 479.985.296 FCFA TTC, Computer Land a saisi l'autorité contractante, le 14 décembre 2015, pour s'enquérir des motifs du rejet de son offre.

Par lettre du 16 décembre 2015, cette dernière lui a donné ses raisons et non satisfaite, Computer Land a introduit un recours au CRD, par lettre du 17 décembre 2015, pour contester les arguments avancés par cette dernière.

Considérant que, par décision n° 361/15/ARMP/CRD du 22 décembre 2015, le CRD a déclaré le recours recevable, ordonné la suspension de la procédure d'attribution et requis de l'autorité contractante la transmission des pièces nécessaires à l'instruction du recours.

Par courrier du 04 janvier 2016, l'autorité contractante a transmis les pièces demandées ainsi que ses observations sur le recours.

LES MOYENS DU REQUERANT

Computer Land reproche à la commission des marchés d'avoir rejeté son offre aux motifs qu'elle semble anormalement basse et ce, en violation flagrante du principe de libre accès à la concurrence et des dispositions de l'article 59 du Code des Marchés publics.

Le requérant ajoute que dans le cadre d'un marché libéralisé, caractérisé par une variété des sources d'approvisionnement, l'autorité contractante ne peut faire état de vérifications faites auprès des fabricants des marques proposées. L'article 59 du

code précité lui impose de motiver sa décision mais pas de la fonder sur un doute en invoquant les fabricants.

Computer Land précise qu'en participant à cet appel d'offres, il a bien analysé la structure des coûts, compte tenu de ses contrats de partenariat avec les fournisseurs étrangers, et n'a pas voulu prendre de marges bénéficiaires injustifiées. Son offre, étant techniquement conforme et correspondant à la réalité économique, lui permet d'assurer la prestation et d'avoir des bénéfices.

LES MOYENS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

L'autorité contractante précise qu'au regard des dispositions du cahier des charges, quant à la précision des prix des logiciels Microsoft Office professionnel et duplicopieur, la commission des marchés, conformément à l'article 59 du code des Marchés publics, avait saisi les soumissionnaires pour leur demander de justifier les prix des articles proposés. En guise de réponse, seule la structure Oumou Distribution a apporté des éléments de preuve sur les prix (factures de MC3 TRADE et de RISO). Les autres se sont contentés de faire état du bénéfice de conditions exceptionnellement favorables auprès de leurs fournisseurs sans en rapporter la preuve,

Elle ajoute qu'en ce qui concerne le logiciel Microsoft Office professionnel, la société Computer Land a proposé un prix de 18.000 FCFA hors taxes et General Logistic 22.000 FCFA hors taxes alors que ce produit est proposé sur le marché libre à 193.000 FCFA TTC (Source Microsoft Sénégal),

L'autorité contractante fait valoir, en outre, qu'en ce qui concerne les duplicopieurs, elle a consulté le fabricant sur le prix le plus bas en deçà duquel l'on ne peut acquérir le matériel et sa réponse a été la suivante

- CZ 100 : 1250 Euros ;
- ZI 80 : modèle obsolète ;
- EZ 201 : 2070 Euros ;
- EZ 231 : 2060 Euros ;
- CV 3030 : 1250 Euros.

La comparaison des prix pour un duplicopieur EZ 231, proposé par le requérant à 797.000 FCFA HTVA et par rapport au prix du fabricant qui est de 2 060 euros, soit 1,351271 FCFA hors taxes, montre que le prix proposé par le candidat est inférieur au prix du fabricant pour le même modèle. C'est ainsi que la commission des marchés a jugé cette offre basse, étant précisé que le fabricant atteste que seule Oumou Informatique a son autorisation et peut bénéficier du certificat d'authenticité à la livraison.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et des moyens que l'objet du litige est relatif au caractère anormalement bas de l'offre de Computer Land.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu'il résulte de l'article 59.4 du Code des Marchés publics que la commission des marchés peut demander aux candidats des précisions utiles concernant les sous détails des prix proposés afin d'en apprécier la réalité économique et rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge anormalement basse si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique ;

Considérant qu'il s'infère de cette disposition qu'une offre ne peut être rejetée par la commission des marchés sans qu'il ne soit demandé, au préalable et par écrit, au candidat de fournir des précisions ou justificatifs sur la composition de l'offre financière afin d'en vérifier la réalité économique ;

Considérant qu'en application de cette disposition, le DAGE du Ministère de l'Education nationale a demandé au requérant, par lettre du 19 août 2015, de justifier les sous détails du prix notamment ceux des licences Microsoft Office 2013 professionnelle et des duplicopieurs numériques RISO EZ 231, proposés par ce dernier dans son offre technique ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction du recours que Computer Land a répondu à cette demande, par lettre du 26 août 2015, en faisant état du bénéfice de conditions exceptionnellement favorables pour fournir les produits et de l'économie résultant des solutions techniques adoptées ;

Considérant cependant que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ces faits ;

Que par conséquent, cette dernière n'a pu justifier de la variété de ses sources d'approvisionnement, ni de l'existence de contrats de partenariat qu'elle invoque à l'appui de son recours de nature à lui conférer ces conditions favorables pour exécuter le marché.

Considérant qu'en outre, l'autorité contractante a produit des attestations émanant de Riso qui établissent les faits suivants

- RISO Kagaku Corporation est le fabricant réputé des duplicopieurs Riso et de leurs accessoires
- RISO France est la filiale française de RISO Kagaku et est la seule structure habilitée à vendre la marque au Sénégal
- le duplicopieur Riso EZ 231, objet de l'offre technique du requérant avec un prix unitaire de 780.000 FCFA, est vendu à 2060 Euros soit 1.351271 FCFA, d'où une différence substantielle de 571271 FCFA sur le prix ;
- Oumou Distribution, attributaire provisoire du marché, fait partie des partenaires commerciaux de Riso France et non Computer Land, ce fait ayant justifié que Oumou Distribution ait pu produire, dans son offre, l'autorisation du fabricant et fourni un certificat d'authenticité conformément à la clause 18.1 A des données particulières de l'appel d'offre (DPAO) qui précise que l'autorisation du fabricant ou le certificat d'authenticité sont requis pour le matériel informatique et de reprographie ;

Considérant, de surcroît, qu'il ressort des pièces produites une facture MC3 TRADE et RISO qui atteste que Oumou Distribution a apporté des éléments de preuve sur les prix offerts ;

Que dans ces conditions, la commission des marchés du Ministère de l'Education nationale a bien justifié sa décision, en la motivant, sur le caractère anormalement bas de l'offre de Computer Land et a attribué provisoirement le marché à Oumou Distribution ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le recours de Computer Land n'est pas fondé, qu'il y a lieu de le rejeter et d'ordonner la continuation de la procédure de passation du marché litigieux

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner, par conséquent, la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que Computer Land fait état de conditions exceptionnellement favorables pour fournir les produits et de l'économie résultant de solutions techniques adoptées
- 2) Constate que Computer Land n'a pas prouvé ces faits, ni la variété de ses sources d'approvisionnement alléguée dans son recours
- 3) Constate que ce dernier a proposé dans son offre technique un duplicopieur Riso EZ231 au prix unitaire de 780.000 FCFA
- 4) Constate que le prix unitaire de ce duplicopieur, selon le distributeur Riso France, est de 2 060 Euros soit 1.351271 FCFA d'où une différence substantielle de 571.271 FCFA sur ledit prix ;
- 5) Constate, en outre, que Computer Land, contrairement à Oumou Distribution, ne fait pas partie des partenaires habilités à représenter la marque Riso au Sénégal ;
- 6) Constate que Oumou Distribution a apporté des éléments de preuve sur les prix offerts ;
- 7) Dit, en conséquence, que la commission des marchés du Ministère de l'Education nationale a justifié sa décision sur le caractère anormalement bas de l'offre de Computer Land et a attribué provisoirement, à bon droit, le marché à Oumou Distribution ;
- 8) Déclare, en conséquence, le recours mal fondé ;
- 9) Le rejette et ordonne la confiscation de la consignation ;
- 10) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché litigieux ;
- 11) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à Computer Land, au Ministère de l'Education nationale

ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général,

Rapporteur

Saer NIANG

La Cour Suprême a également rejeté la requête en annulation de la société Computer Land, en estimant, entre autres, que : « en retenant que la commission des marchés a bien motivé sa décision sur le caractère anormalement bas de l'offre de la société Computer Land, le CRD a légalement justifié sa décision ».

La décision du CRD va dans le même sens que la jurisprudence française.

Cet article 59-4 du code sénégalais des marchés publics est le pendant de l'article 55 du code français des marchés publics.

La doctrine française estime que : « l'appréciation de la situation se réalise au cas par cas. La collectivité ne peut pas écarter systématiquement cette offre, sous peine de se priver d'économies et de décourager les initiatives des entreprises. Elle vérifie donc sa validité en demandant, par écrit au candidat, des explications relatives à la teneur exacte de son offre (solutions techniques, approvisionnements, organisation du travail, ...) afin de déterminer s'il peut dégager des bénéfices normaux de la réalisation de cette prestation. Si tel n'est pas le cas, l'acheteur se trouve en présence d'une offre anormalement basse de nature à fausser la concurrence et elle doit être écartée ».

La jurisprudence est abondante en Europe et en France :

1. COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE

CJCE, 15 mai 2008, SECAP SPA contre Commune di Torino, affaires jointes C- 147/06 et C-148/06 (modalités d'exclusion des offres anormalement basses – obligations du pouvoir adjudicateur résultant des principes fondamentaux du droit communautaire.

2. CONSEIL D'ETAT

- CE, 28 juillet 1999, Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération (ORSTOM) réq. N° 186219 (notion de variante) ;

- CE Ass. 5 mars 1999, Président de l'Assemblée Nationale, réq. n° 163328 (Distinction entre les marchés publics et les actes parlementaires – offres anormalement basses – Notion d'urgence).

3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)

CAA Bordeaux, 17 novembre 2009, SICTOM Nord, réq. n° 08BX01571 (validité de la décision de la CAO considérant une offre anormalement basse en l'absence de réponse à sa demande de précisions).

10

**PEUT ETRE CLASSÉ SANS
SUITE UN APPEL D'OFFRES
DONT LES MONTANTS DES
OFFRES DEPASSENT LE BUDGET
PRÉVISIONNEL**

(ARTICLE 65 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

En vertu de l'article 65 du Code des marchés publics : « l'autorité contractante peut, après consultation de la Direction chargée du contrôle des marchés publics, ne pas donner suite à un appel d'offres pour des motifs d'intérêt général, tels que la disparition du besoin qui était à l'origine de la procédure ou des montants d'offres trop élevés par rapport à la valeur estimée du marché ».

S'appuyant sur cette disposition, suite au recours du groupe MATFIS, seul soumissionnaire ayant présenté une offre conforme à l'issue d'une seconde évaluation, le CRD a annulé l'attribution provisoire du marché et a donné acte à l'autorité contractante de son intention de saisir la DCMP d'une requête de classement sans suite du marché ; car le groupe MATFIS avait fait une proposition financière de plus de 81 000 000 frs CFA alors que le budget prévisionnel du marché n'était que de 49 000 000 frs CFA (décision CRD n°103 du 13 avril 2016).

**DECISION NO 103/16/ARMP/CRD DU 13 AVRIL 2016 DU COMITE DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE
RECOURS DU GROUPE MATFIS CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISoire
DU MARCHE RELATIF AU NETTOIEMENT ET A L'ENTRETIEN DES LOCAUX
DU PALAIS DE JUSTICE LAT-DIOR ET DE LA CHANCELLERIE LANCE PAR LE
MINISTERE DE LA JUSTICE.**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSIONLITIGES,**

86

VU la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi no 2006-16 du 30 juin 2006 ;

VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

VU le décret n° 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation ;

VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU la décision n° 005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

VU la résolution n° 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends ;

VU le recours du Groupe MATFIS reçu le 17 mars 2016 ;

VU la consignation faite par le Groupe MATFIS le 18 mars 2016 ;

Monsieur Alioune DIALLO, Commissaire à la Cellule d'instruction des Recours, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Khadijetou Dia LY, Contrôleur de Gestion, assurant l'intérim de Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assistée par ses collaborateurs, observateurs ;

Adopte la présente délibération fondée sur la loi et les principes généraux de la régulation

Par courrier reçu le 18 mars 2016 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 085/CRD, le Groupe MAT FIS a saisi le CRD pour contester l'attribution provisoire du marché relatif au nettoyage et à l'entretien des locaux du Palais de Justice Lat Dior et de la Chancellerie lancé par le Ministère de la Justice.

LES FAITS

Le Ministère de la Justice a, dans le quotidien « Le Soleil » du 17 février 2016, fait publier la Demande de Renseignements et de Prix à Compétition ouverte (DRPCO) n° 02/DAGE_OII relative au marché de nettoyage et d'entretien des locaux réparti en deux (02) lots

- lot 1 : Entretien et nettoyage du Palais de Justice Lat Dior et
- lot 2 : Entretien et nettoyage de la Chancellerie du Ministère de la Justice.

A l'ouverture des plis, le 04 mars 2016, la liste des candidatures reçues s'établit comme suit:

Pli	Nom des soumissionnaires	Montant des offres en FCFA TTC	
		Lot 1	Lot 2
01	KEUR SERIGNE FALLOU	29 360 760	9 147 362
02	NICKEL	3 304 000/mois	944 000/mois
03	MULTISERVICE NETTOIEMENT	Pas de soumission	1 858 458/mois
04	ESEF	2 688 000/mois	1 156 400/mois
05	SENEGALAISE DE TVX PUBLICS	60 903 572	
06	OULOUSE PROMO	30 414 175	9 404 610
07	GROUPE MATHS	60 927 364	21 367 057
08	SENETT	36 334 560	12 366 636
09	LNF SUARL	Pas de soumission	13 275 458

Au terme de l'évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d'attribuer provisoirement le lot à ESEF pour un montant de trente deux millions deux cent cinquante six mille francs (32 256 000) CFA TTC et le lot 2 à SENNET pour un montant de douze millions trois cent soixante six mille six cent trente six francs (12 366 636) CFA TTC.

Dès qu'il a pris connaissance du rejet de son offre par correspondance en date du 14 mars 2016, le Groupe MATHS a saisi l'autorité contractante, par lettre reçue le 15 mars 2016, pour en demander les motifs

Non satisfait de la réponse de l'autorité contractante en date du 17 mars 2016, le requérant a introduit, le même jour, un recours contentieux auprès du CRD par courrier reçu le lendemain.

Par décision n° 083/16/ARMP/CRD du 21 mars 2016, le CRD a jugé le recours du Groupe MATFIS recevable, ordonné la suspension de la procédure de passation et saisi l'autorité contractante pour disposer des documents nécessaires à l'instruction.

Suivant courrier du 05 avril 2016 reçu le lendemain, l'autorité contractante a transmis à l'ARMP les pièces demandées.

LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS

88

A l'appui de son recours, MATFIS soutient avoir satisfait aux exigences du cahier des charges tant pour le personnel qu'il a proposé dans son offre qu'en ce qui concerne les montants de leurs rémunérations.

Il déclare que, l'autorité contractante, en réponse au recours gracieux, a porté à sa connaissance les deux (02) motifs de rejet de son offre que sont :

1. le statut de non-salariés des trois (03) chefs d'équipe qu'il a proposés pour le lot 1
2. l'omission, dans le calcul des salaires du personnel proposé pour le lot de la prise en compte du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) de la convention collective du secteur du commerce.

Sur le statut de non-salarié des deux chefs d'équipe invoqué par l'autorité contractante, le requérant signale, qu'en dehors des marchés qui leur sont déjà attribués et pour lesquels elles perçoivent des paiements, les sociétés du secteur du nettoyage ne peuvent se permettre de recruter de la main-d'œuvre permanente et salariée. Selon lui, le poids de la masse salariale et des charges sociales y afférentes en seraient économiquement insupportables. C'est pourquoi, il conclut à l'impossibilité de satisfaire une telle exigence.

Concernant les salaires, il argue que l'autorité contractante devait se renseigner davantage avant de lancer la DRPCO. En effet, il informe que le secteur du nettoyage s'est battu pour obtenir, depuis l'an 2014, sa propre convention collective dont il a joint une copie à sa requête. Dès lors, il est, pour lui, hors de question d'appliquer le SMIG d'une autre convention collective pour calculer le montant des salaires pour le personnel qu'il a proposé. C'est pourquoi, il juge trop léger l'argument avancé par

l'autorité contractante qui prétend avoir appliqué le SMIG de la convention collective du secteur du commerce dans le seul but de ne pas dépasser son budget prévisionnel.

MATFIS souligne qu'il lui a été donné de constater, à la lecture du procès-verbal d'ouverture des plis, que la plupart des candidats ont proposé des salaires inférieurs au SMIG en vigueur dans le secteur du nettoyage. Il estime, qu'en conséquence, leur offre devrait être rejetée au regard des dispositions figurant dans la section IV du Dossier d'Appel d'Offres (DAO).

Au regard de ce qui précède, le requérant demande au CRD d'annuler l'attribution provisoire du présent marché.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Par lettre reçue le 06 avril 2016, l'autorité contractante a transmis les éléments demandés et formulé des observations sur le recours de MATFIS.

Elle déclare que, la commission des marchés, par correspondance no 00274/MJ/CM en date du 17 mars 2016, a notifié au requérant les motifs de rejet de son offre qui sont, entre autres la non déclaration à l'IPRES et à la Caisse de Sécurité Sociale. des trois (03) chefs d'équipe qu'il a proposés pour le lot 1 : et l'application d'un SMIG ayant abouti au dépassement de l'enveloppe budgétaire prévue pour le lot 2.

Toutefois, l'autorité contractante déclare que suite au recours gracieux de MATFIS, la commission des marchés a repris l'évaluation des offres en appliquant le SMIG de la convention collective du secteur du nettoyage dont elle n'avait pas eu connaissance auparavant. Elle signale qu'à l'issue de cette seconde évaluation, le requérant est sorti comme étant le seul soumissionnaire ayant présenté une offre conforme. Cependant, fait-elle remarquer, l'offre financière de MATFIS, à savoir. soixante millions neuf cent vingt sept mille trois cent soixante quatre francs (60 927 364) CFA TTC pour le lot 1 et vingt un millions trois cent soixante sept mille cinquante sept francs (21 367 057) CFA TT pour le lot 2, dépasse, de loin, le montant prévisionnel du marché qui est de quarante neuf millions de francs (49 000 000) CFA ; soit trente six millions de francs (36 000 000) CFA pour le lot et treize millions de francs (13 000 000) CFA pour le lot 2.

Compte tenu de cet état de fait, l'autorité contractante dit avoir décidé de saisir la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) pour déclarer la procédure sans suite. Elle argue que ladite saisine n'a pu être effectuée suite au recours contentieux de MATFIS ayant abouti à la décision de suspension du marché par le CRD

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que le litige porte sur le rejet de l'offre de MATFIS pour, d'une part, défaut de qualification relativement au statut des chefs d'équipe qu'il a proposés dans son offre et, d'autre part, la non-conformité de son offre relativement au montant du SMIG qu'il a appliqué pour calculer les salaires du personnel au titre du présent marché.

EXAMEN DU LITIGE

1. Sur le statut des chefs d'équipe

Considérant que l'IC 5.4.c des Données Particulières (DP) du dossier de DRPCO exige de chaque soumissionnaire au présent marché de disposer d'un personnel qualifié dont trois (03) chefs d'équipe pour le lot 1 et un (01) chef d'équipe pour le lot 2 avec, au moins, cinq (05) ans d'expérience dans le domaine du nettoyage ;

Considérant que la commission des marchés du Ministère de la Justice a rejeté l'offre du requérant au motif, entre autres, que les trois (03) chefs d'équipe qu'il a proposés pour le lot 1 ne sont pas des salariés ;

Qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le requérant n'a pas fourni dans son offre les preuves, notamment des contrats de travail, qu'il dispose du personnel requis ;

Que le requérant n'a donc pas satisfait au critère exigé dans le DAO relativement au nombre et au statut des trois (03) chefs d'équipe requis pour le lot 1 ;

Que le poids des charges salariales invoqué par le requérant pour justifier son déficit en personnel permanent ne peut faire grief ;

Qu'il y a donc lieu de conclure que la commission des marchés de l'autorité contractante est fondée à rejeter l'offre de MATFIS pour défaut de qualification pour le lot 1.

2. Sur le SMIG applicable pour le calcul des salaires du personnel de nettoyage

Considérant que la section IV du dossier d'appel d'offres dispose que le salaire des techniciens de surface doit être mentionné par les candidats dans leur offre, que ce salaire doit être au moins égal au SMIG et que toute offre qui propose des salaires inférieurs au SMIG sera rejetée ;

Considérant, qu'en application de la disposition susvisée, le requérant a présenté la grille des salaires proposée pour son personnel en utilisant le SMIG figurant dans la convention collective du secteur du nettoyage en vigueur depuis le mois de juin 2014 ;

Considérant que l'autorité contractante a estimé ne pas être au courant de l'existence d'une convention collective du secteur du nettoyage au moment de lancer la DRPCO ;

Qu'elle a jugé que c'est le SMIG de la Convention collective du Commerce qui doit être appliqué pour ne pas dépasser le budget prévisionnel du présent marché ;

Considérant, en outre, que le dossier d'appel à la concurrence, en exigeant des candidats au présent marché d'appliquer le SMIG dans le calcul des salaires du personnel proposé, n'a pas précisé la convention collective de référence ;

Qu'il peut être compréhensible pour MATAS le fait d'appliquer, automatiquement, le SMIG du secteur du nettoyage dans le calcul des salaires au titre du présent marché portant sur l'entretien et le nettoyage de locaux;

Qu'il y a lieu de signaler, qu'en matière salariale. c'est le secteur d'activité qui détermine la convention collective à appliquer ;

Que, comme du reste le requérant l'a souligné, concernant le calcul des salaires du personnel, le fait d'appliquer, pour un secteur d'activité donné, disposant de sa propre convention collectives le barème des salaires régissant un autre secteur, serait contraire à la réglementation ;

Que l'autorité contractante ne peut exciper de son ignorance de l'existence d'une convention collective pour le secteur du nettoyage ;

Qu'il y a lieu de conclure, que la décision de l'autorité contractante de rejeter l'offre de MATFIS pour avoir appliqué, dans le calcul des salaires contenus dans son offre pour le présent marché, la convention collective du secteur du nettoyage, n'est pas justifiée ;

Considérant, toutefois, que suite au recours gracieux de MATFIS, la commission a repris l'évaluation des offres en appliquant le SMIG de la convention collective du secteur du nettoyage dont elle estime n'avoir pas eu connaissance lors de la première évaluation ;

Qu'à l'issue de cette seconde évaluation, MATFIS a été évalué comme étant le seul soumissionnaire ayant présenté une offre conforme ;

Considérant, cependant, que l'offre financière de MATFIS, à savoir, soixante millions neuf cent vingt sept mille trois cent soixante quatre francs (60 927 364) CFA TTC pour le lot 1 et vingt un millions trois cent soixante sept mille cinquante sept francs (21 367 057) CFA TT pour le lot 2, est supérieur au montant prévisionnel du marché qui est de quarante neuf millions de francs (49 000 000) CFA ; soit trente six millions de francs (36 000 000) CFA pour le lot et treize millions de francs (13 000 000) CFA pour le lot 2 ;

Considérant que l'article 65 du Code des Marchés publics dispose que l'autorité contractante peut, après consultation de la DCMP, ne pas donner suite à un appel d'offre pour des motifs d'intérêt général, tels que, entre autres, des montants d'offres trop élevés par rapport à la valeur estimée du marché ;

Qu'en application de la disposition susvisée, l'autorité contractante compte saisir la DCMP d'une requête de classement sans suite du présent marché ;

Qu'il échet de lui en donner acte et d'ordonner l'annulation de l'attribution provisoire du marché ;

Considérant que le recours de MATFIS n'a prospéré qu'en partie ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation de la consignation.

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que l'IC 5.4.c du dossier de DRPCO exige de chaque soumissionnaire au présent marché de disposer d'un personnel qualifié dont trois (03) chefs

d'équipe pour le lot 1 et un (01) chef d'équipe pour le lot 2 avec, au moins, cinq (05) ans d'expérience dans le domaine du nettoyage ;

2) Constate que MATFIS n'a pas fourni dans son offre les justificatifs qu'il dispose du personnel requis, notamment, des contrats de travail ;

3) Dit que le requérant n'a donc pas satisfait au critère exigé dans le DAO relativement au nombre et au statut des trois (03) chefs d'équipe requis pour le lot 1 ;

4) Dit que l'autorité contractante est fondée à rejeter l'offre de MATFIS pour défaut de qualification pour le lot 1 ;

5) Constate que la section IV du dossier d'appel d'offres exige que le salaire des techniciens de surface soit mentionné par les candidats dans leur offre et que ce salaire doit être au moins égal au SMIG sous peine de rejet de leur offre ;

6) Constate que le dossier d'appel à la concurrence ne précise pas aux candidats la convention collective de référence pour le calcul des salaires au titre du présent marché ;

7) Constate que le requérant, en référence à l'intitulé du marché, a appliqué le SMIG de la convention collective du secteur du nettoyage en vigueur depuis le mois de juin 2014 ;

8) Déclare, qu'au titre du présent marché portant sur « l'entretien et le nettoyage des locaux du palais de justice Lat Dior et de la Chancellerie du Ministère de la Justice », la convention collective du secteur du nettoyage doit être le barème salarial de référence ;

9) Dit, en conséquence, que la décision de la commission, de rejeter l'offre de MATFIS pour non application de la convention collective du commerce pour le calcul des salaires du personnel qu'il a proposé, n'est pas justifiée ;

10) Annule, en conséquence, l'attribution provisoire des deux (02) lots du marché ;

11) Constate, toutefois, que suite au recours gracieux de MATFIS, la commission a repris l'évaluation des offres en appliquant le SMIG de la convention collective du secteur du nettoyage ;

12) Constate que l'offre financière de MATFIS est supérieure au budget prévisionnel du marché ;

13) Donne acte à l'autorité contractante sur sa proposition de classer sans suite le présent marché conformément aux dispositions de l'article 65 du Code des Marchés publics ;

14) Ordonne, en conséquence, la confiscation de la consignation ;

15) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à MATHS, au Ministère de la Justice ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général,

Rapporteur

Saer NIANG

En France, l'article 233 du code permet au pouvoir adjudicateur de classer sans suite la procédure pour un motif d'intérêt général, dans le cadre des marchés de défense ou de sécurité.

11

LA NON PUBLICATION D'UN MARCHE DANS LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES AVANT SON LANCEMENT ENTRAINE SON ANNULATION

**(ARTICLE 76-2 DU CODE DES MARCHES PUBLICS
ET ARTICLE 24 NOUVEAU DU COA)**

L'article 6 du Code des marchés publics dispose : « à l'exception des marchés prévus à l'article 76.2, les marchés passés par les autorités contractantes sont inscrits dans les plans de passation des marchés, à peine de nullité. »

De même qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 24 nouveau du Code des Obligations de l'Administration : « le non-respect des formalités de publicité prescrites et la violation du principe d'égalité de traitement des candidats aux commandes publiques par les acheteurs publics entraîne la nullité de la procédure de passation ou du marché passé, à la requête de toute personne intéressée au déroulement normal de la procédure. »

Se fondant sur ces dispositions pertinentes, les services régionaux des marchés publics (SRMP) rejettent les demandes d'immatriculation des marchés n'ayant pas fait l'objet de publication dans le plan de passation des marchés (PPM), de même que le CRD, sur saisine des autorités contractantes fautives, annule les procédures concernées du fait que les règles de publicité, qui sont d'ordre public, ne sont pas respectées (ex : décision du CRD n°382 du 7 décembre 2016).

Ainsi, un marché ne peut être conclu s'il n'est pas prévu dans le plan de passation des marchés, sauf pour les marchés secrets, ceux dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ceux relatifs à la protection des intérêts essentiels de l'Etat, ceux résultant de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l'autorité contractante et ceux passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde (article 76.2 du Code des marchés publics).

Le plan de passation des marchés publics, qui est établi suivant un modèle-type fixé par l'ARMP, doit être validé par la DCMP qui le publie dans un délai de trois jours, après vérification de sa conformité.

DECISION N° 382/161ARMP/CRD DU 07 DECEMBRE 2016

DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT

EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DE L'INSPECTION

DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION DE KANEL VISANT A OBTENIR L'AUTORISATION DE FAIRE IMMATICULER UN MARCHÉ N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'INSCRIPTION DANS LE PLAN DE PASSATION DE MARCHES AVANT SON LANCEMENT

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

VU la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration, modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

VU le décret n° 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;

VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

VU la résolution n° 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends ;

VU la demande de l'Inspection de l'Education et de la Formation de Kanel, suivant lettre numéro 009674/1EF/KNL du 19 novembre 2016, reçue le 22 novembre 2016 à l'ARMP, enregistrée sous le no 3360 au service courrier de l'ARMP ;

Madame Aïssatou Dieng TRAORE, Chef de Division des Appuis techniques, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, assisté de ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la Régulation ;

ADOpte LA PRÉSENTE DÉCISION

Par lettre en date du 19 novembre 2016, enregistrée à l'ARMP le 22 novembre 2016, l'inspecteur de l'Education et de la Formation de Kanel, a saisi le CRD d'une demande visant à faire immatriculer, par le Service Régional des Marchés publics, Pôle de Saint Louis (SRMPPSL) un marché dont le projet n'a pas fait l'objet de publication dans le Plan de passation des Marchés (PPM) de l'inspection. Le marché, passé par Demande de Renseignements et de Prix à compétition ouverte (DRPCO), porte sur la fourniture de matériels pédagogiques et didactiques.

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

Considérant que le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que la saisine du Comité de Règlement des Différends (CRD) par l'Inspection de l'Education et de la Formation de Kanel fait suite au refus du Service Régional des Marchés publics, Pôle de Saint-Louis (SRMPPSL) de procéder à l'immatriculation du marché relatif à la fourniture de matériels pédagogiques et didactiques ;

Considérant que le Code des Marchés publics ne fixe pas, dans ce cas de figure, un délai ;

Qu'il y a lieu de déclarer la saisine de l'Inspection de l'Education et de la Formation de Kanel recevable.

LES MOYENS A L'APPUI DE LA DEMANDE

L'inspecteur a joint à sa requête les copies de la lettre du Service Régional des Marchés publics, Pôle de Saint-Louis (SRMPPSL) portant rejet de la demande d'immatriculation ainsi que la version ne 01/1EF/KNL/Gest du 14 janvier 2016 du PPM. Dans celle-ci, l'inspecteur atténue quelque peu l'argument du défaut de publication dans le PPM en faisant remarquer avoir préparé le projet mais que le courrier y afférent adressé au SRMPPSL remis à un tiers n'est jamais parvenu au destinataire. En mettant en exergue les conséquences sur l'amélioration de l'environnement pédagogique que le maintien de la décision du SRMPPSL pourrait causer, le requérant sollicite la poursuite de la procédure en promettant de prendre les mesures adéquates pour éviter, à l'avenir, la répétition du manquement qu'il justifie par son inexpérience.

LES MOTIFS DONNES PAR LE SERVICE REGIONAL DES MARCHES PUBLICS

Le SRMPPSL motive son rejet par la violation de l'article 6.2 du Code des Marchés publics qui pose le principe de la publication dans le PPM de tout marché avant son lancement.

97

OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que l'Inspection de l'Education et de la Formation de Kanel sollicite l'autorisation de faire immatriculer le marché relatif à la fourniture de matériels pédagogiques et didactiques, suite à la décision de rejet du Service régional des Marchés publics Pôle de Saint-Louis (SRMPPSL) pour défaut de publication du marché dans le PPM

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que les dispositions de l'article 6.2 du Code des Marchés publics prévoient qu' « à l'exception des marchés prévus à l'article 762, les marchés passés par les autorités contractantes sont inscrits dans les plans de passation des marchés, à peine de nullité » ;

Considérant que l'article 24 nouveau de la loi no 65 -51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi 06-16 du 30 juin 2016 dispose que « le non-respect des formalités de publicité prescrites et la violation du principe d'égalité de traitement des candidats aux commandes publiques par les acheteurs publics entraîne la nullité de la procédure de passation du marché passé, à la requête de toute personne intéressée au déroulement normal de la procédure » ;

Qu'au demeurant, même si les procédures de passation des marchés doivent permettre aux acheteurs publics d'acquérir des biens et services et de réaliser des travaux avec célérité afin d'atteindre les objectifs de performance qui leur sont assignés, celles-ci doivent être conduites tout en veillant à préserver la transparence et l'équité qui s'y attachent ;

Qu'à cet égard, l'Inspection de Kanel a violé les principes de transparence et d'équité du marché parce que les règles de publicité dans le PPM ne sont pas respectées.

Qu'il S'ensuit que le SRMPPSL, qui exerce un contrôle de conformité, est fondé à rejeter la demande d'immatriculation introduite par l'Inspection d'éducation et de la formation de Kanel ;

Qu'il y a lieu d'annuler la procédure susvisée du fait que les règles de publicité qui sont d'ordre public ne sont pas respectées par l'Inspection de l'Education et de la Formation de Kanel ;

Considérant, toutefois, l'urgence à acquérir les matériels didactiques et pédagogiques pour donner un sens au concept «ubbitey, jangtey» (démarrage effectif des enseignements et apprentissages dès le premier jour de la rentrée) dans toute l'étendue du territoire sénégalais ;

Que ces fournitures composées de cartes murales, livres, unités de mesures, règles du maître etc. sont attendues avec beaucoup d'impatience pour compléter l'outillage pédagogique afin de réaliser les objectifs éducatifs assignés à l'inspection de Kanel ;

Qu'en effet, la livraison, au-delà du premier trimestre de l'année de ce matériel qui devait normalement être disponible depuis le début de l'année scolaire, si «on s'inscrit dans la logique du concept « ubbitey, jangtey », a pour conséquence d'obérer la qualité des enseignements, au préjudice des trente mille (30 000) élèves bénéficiaires par rapport à leurs condisciples des écoles relevant d'autres inspections ;

Qu'il n'est pas judicieux de faire subir un tel préjudice aux enfants par la relance d'une nouvelle procédure dictée par un manquement dont l'entière responsabilité doit être endossée par l'autorité contractante ;

Considérant, par ailleurs, que l'on est à quelques jours de la clôture de l'exercice budgétaire 2016, la relance du marché n'est pas compatible avec les délais et règles de forme exigés par une procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint ;

Qu'en effet les crédits non engagés jusqu'à la clôture du budget, surtout ceux relatifs au fonctionnement, ne peuvent pas faire, a priori, l'Objet de report sur l'exercice suivant ; ce qui fait peser un risque de perte des crédits destinés au paiement du marché ;

Qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu d'autoriser, à titre exceptionnel, la reprise de la procédure susvisée sous forme d'entente directe avec l'Entreprise Cheikh Oumar TALL pour un montant de vingt-neuf millions cinq cent vingt mille six cent cinquante (29 520 650) F CFA TTC

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que l'Inspection de l'Education et de la Formation de Kanel a lancé une procédure de marché pour l'acquisition de matériels pédagogiques et didactiques sans l'avoir inscrit, au préalable, dans le Plan de Passation des Marchés ;
- 2) Dit que ladite Inspection n'a pas respecté les dispositions de l'article 6.2 du Code des Marchés publics ;
- 3) Dit que le refus du SRMPPSL de procéder à l'immatriculation du marché susvisé est fondé ;
- 4) Annule, en conséquence, la procédure de passation du projet de marché d'acquisition de matériels pédagogiques et didactiques ;
- 5) Dit, que la mise à disposition de ces acquisitions, au-delà du premier trimestre, risque d'engendrer des dysfonctionnements préjudiciables aux élèves des écoles bénéficiaires ;
- 6) Dit, que la relance du marché n'est pas compatible avec les délais et règles de forme exigés par une procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint, au regard de la clôture imminente du budget 2016 ; en conséquence ;
- 7) Annule le projet de marché en cours pour défaut d'inscription dans un Plan de Passation de Marchés (PPM) ;
- 8) Autorise, à titre exceptionnel, la reprise de la procédure, objet de la saisine, sous forme de marché par entente directe avec le même fournisseur attributaire ;
- 9) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à l'Inspection de l'Education et de la Formation de Kanel, ainsi qu'au Service régional des Marchés publics Pôle de Saint-Louis (SRMPPSL), la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés PUBLICS.

Le président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général,

Rapporteur

Saer NIANG

12

**L'IRRESPECT DES CONDITIONS
ET SPECIFICATIONS DU CAHIER
DES CHARGES ENTRAINE LE
REJET DE L'OFFRE**

(ARTICLE 68 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

En vertu de l'article 68 du Code des marchés publics, après examen de la recevabilité de chaque offre, la commission doit ensuite déterminer si celle-ci est conforme aux conditions et spécifications du cahier des charges.

Se fondant sur cette disposition, la commission des marchés de l'Unité de Coordination de la Gestion des Déchets Solides a rejeté l'offre de l'entreprise Distribution de Matériels (DISMAT) au motif, entre autres, que cette dernière n'a pas fourni les spécifications techniques du matériel qu'elle a proposé, comme exigé dans le dossier d'appel d'offres.

Suite à sa saisine, le CRD, après avoir analysé les documents fournis par DISMAT, s'est appuyé sur l'article susvisé pour déclarer son recours non fondé parce que son offre n'est pas conforme (décision n°009 du 13 janvier 2016).

Cette position du CRD est constante (décision n°14 du 30 janvier 2013 relative au recours de la société de diffusion Médicodentaire) et conforme à la loi, car la commission des marchés doit vérifier, entre autres, que les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges et rejeter les offres non conformes.

La notion de spécification technique est définie comme étant : « l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. »

**DECISION n° 009/16/ARMP/CRD DU 13 JANVIER 2016 DU COMITE DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE
RECOURS DE L'ENTREPRISE DISTRIBUTION DE MATERIELS CONTESTANT
L'ATTRIBUTION PROVISoire DU MARCHE RELATIF A L'ACQUISITION
DE PETITS MATERIELS DE NETTOIEMENT LANCE PAR L'UNITE DE
COORDINATION DE LA GESTION DES DECHETSSOLIDES DU MINISTERE DE
LA GOUVERNANCE LOCALE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l'entreprise Distribution de Matériels par courrier du 18 décembre 2015 ;

Vu la consignation faite par l'entreprise Distribution de Matériels le 18 décembre 2015 ;

Monsieur Alioune DIALLO, Commissaire à la Cellule d'instruction des recours, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci-après

Par courrier reçu le 18 décembre 2015 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRC)) sous le numéro 353/15, l'entreprise Distribution de Matériels (DISMAT) a saisi le CRD pour contester l'attribution provisoire du marché relatif à l'acquisition de petits matériels de nettoyage lancé par l'Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides (UCC) du Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire.

LES FAITS

Dans le quotidien « Le Soleil » du 14 décembre 2015, l'Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides (UCG) du Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire a lancé un appel d'offres ouvert relatif à l'acquisition de petits matériels de nettoyage.

A l'ouverture des plis, le 26 novembre 2015, huit (08) offres ont été reçues et les montants ci-après lus publiquement.

	Noms des soumissionnaires	Montants FCFA TTC
01	OZE SUARL	114 271 938
02	TOUBA NEGOCE INTERNATIONAL	115 701 950
03	ABSO TRADING	116 119 375
04	GROUPE DELTA	97 807 500
05	W T COMPANY	114 961 500
06	PAPETERIE BUREAUTIQUE SERVICE	132 744 100
07	LNF SUARL	135 614 450
08	DISMAT	76 458 100

Au terme de l'évaluation des offres, l'autorité contractante a proposé d'attribuer provisoirement le marché à WADE TRADING COMPANY ayant présenté l'offre évaluée troisième moins-disante d'un montant de cent quatorze millions neuf cent soixante un mille cinq cent francs (114 961 500) CFA, TTC.

Dès qu'elle a pris connaissance des résultats de l'attribution provisoire publiée dans le journal Le Soleil » du 14 décembre 2015, l'entreprise DISMAT a saisi l'autorité contractante, par lettre reçue le lendemain, pour demander les motifs de rejet de son offre.

N'ayant pas reçu de réponse dans le délai de trois (03) jours imparti à l'autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d'un recours contentieux par lettre reçue le 18 décembre 2015.

Par décision n° 362/15/ARMP/CRD du 23 décembre 2015, le CRD a jugé le recours de l'entreprise DISMAT recevable, ordonné la suspension de la procédure de passation et saisi l'autorité contractante pour disposer des documents nécessaires à l'instruction.

Par courrier du 30 décembre 2015, reçu le même jour, l'autorité contractante a transmis à l'ARMP les pièces demandées et formulé des observations sur le recours de l'entreprise DISMAT.

LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de son recours, l'entreprise DISMAT fait remarquer qu'à l'issue de la séance d'ouverture des plis, son offre a été jugée moins-disante, comme l'atteste le procès-verbal de dépouillement joint à sa requête. Elle déclare que, par lettre en date du 14 décembre 2015, l'autorité contractante lui a notifié le rejet de son offre.

Elle dit avoir saisi l'UCG d'un recours gracieux pour connaître les motifs de rejet de son offre.

Elle informe que sa requête étant restée sans suite, elle a saisi le CRD.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

L'autorité contractante a transmis les éléments demandés et fourni les observations ci-après relativement au recours de l'entreprise DISMAT.

Elle fait remarquer que, contrairement à ce que soutient le requérant dans sa saisine, son recours gracieux n'est pas resté sans suite. Elle soutient avoir fourni au requérant, par lettre n° 1133/MGLDAT/UCG/Coord/RAF/SPM du 18 décembre 2015, les motifs du rejet de son offre, à savoir :

- La non-exécution de deux marchés de fournitures de petits matériels de nettoyage durant les cinq dernières années, comme exigé dans le cahier des charges ;
- L'absence de spécifications techniques relatives au matériel qu'elle a proposé.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que le litige porte, d'une part, sur la conformité de l'offre de l'entreprise DISMAT relativement aux spécifications techniques du matériel qu'elle a proposé et, d'autre part, sur sa qualification relativement aux critères définis dans le DAO.

EXAMEN DU LITIGE

Sur la conformité de l'offre de l'entreprise DISMAT relativement aux spécifications techniques du DAO

Considérant que l'article 68 du Code des Marchés publics dispose qu'après l'examen de la recevabilité de chaque offre la commission doit ensuite déterminer si celle-ci est conforme aux conditions et spécifications du cahier des charges ;

Considérant que le cahier des clauses techniques du DAO a énuméré les spécifications techniques minimales obligatoires pour les fournitures et services connexes faisant l'objet du présent marché, notamment

- Pelle ronde en acier avec manche en bois massif de 110 cm ;
- Râteau en acier avec manche en bois massif de 130 cm ;
- Brouette en acier, capacité 90 l, d'usage général avec des roues en bandage plein ou gonflable, livrée en kit ;

Considérant que l'autorité contractante a rejeté l'offre du requérant au motif, entre autres, qu'il n'a pas fourni les spécifications techniques du matériel qu'elle a proposé, comme exigé dans le DAO ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, que l'offre de l'entreprise DISMAT est composée de deux (02) documents intitulés respectivement « Pièces Administratives » et « Offre Financière » ;

Qu'à l'analyse desdits documents, les spécifications techniques exigées dans le DAO concernant le matériel demandé n'y figurent pas ;

Que le requérant n'a donc pas satisfait au critère relatif aux spécifications techniques telles qu'exigées dans le cahier des charges ;

Qu'il résulte de ce qui précède, que la décision de la commission des marchés de rejeter l'offre de DISMAT pour absence de spécifications techniques est justifiée ;

Qu'en conséquence, sans qu'il ne soit besoin d'examiner le grief relatif à la qualification du requérant, son offre n'étant pas conforme, il y a lieu de considérer la décision de la commission des marchés de ne pas attribuer le marché à l'entreprise DISMAT comme justifiée ;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation.

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que l'offre de l'entreprise DISMAT ne contient pas de spécifications techniques comme exigé dans le DAO ;
- 2) Dit que l'offre de l'entreprise DISMAT n'est pas conforme ;
- 3) Dit, en conséquence, que le recours n'est pas fondé ;
- 4) Ordonne la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation ;
- 5) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à l'entreprise DISMAT, à l'Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides (UCC) et à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail

Le président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

105

Le Directeur Général,

Rapporteur

Saer NIANG

La position du CRD est conforme à la jurisprudence française et européenne pour lesquelles les spécifications techniques doivent permettre l'égal accès des candidats.

13

**LA NON VALIDITE DE LA
GARANTIE DE SOUMISSION
ENTRAINE LE REJET DE L'OFFRE**

**(ARTICLES 44 ET 114 DU CODE DES MARCHES
PUBLICS)**

Il résulte de l'article 114 du code de 2014 que pour être admis aux appels d'offres les candidats doivent fournir une garantie de soumission et que ladite garantie reste valable pendant 28 jours à compter de l'expiration de la date de validité des offres.

L'article 44 du même code précise que le défaut de fournir la garantie de soumission à l'ouverture des plis entraîne le rejet de l'offre.

Se fondant sur ces dispositions, la commission des marchés de la commune de Ndiago, qui a procédé au 24 juillet 2015 au dépouillement des offres de son marché de relance, a rejeté, entre autres, pour non-conformité de sa caution l'offre de la société Horizon Plus.

Suite au recours de ladite société, le CRD a décidé que ce rejet est fondé parce que le requérant n'a pas produit une garantie de soumission à l'ouverture des plis, en ce sens que la garantie qu'il a déposée, avec une durée de validité de 148 jours, expire le 6 octobre 2015, alors que la garantie afférente à l'offre déposée le 24 juillet 2015 expire normalement le 22 décembre 2015.

DECISION N° 010/16/ARMP/CRD DU 13 JANVIER 2016

DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE HORIZON PLUS RELATIF A LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES OUVERT LANCEE PAR LA COMMUNE DE NDIAGO POUR LA REALISATION D'UNE PISTE DE PRODUCTION DE 7 ,714 KM ENTRE GINGUINEO ET NDIAGO.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Horizon Plus daté du 21 septembre 2015 et reçu le 22 septembre 2015 ;

Vu la consignation faite le 22 novembre 2015 ;

Madame Marie Delphine NDIAYE, Cellule d'Enquêtes et d'Inspection, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD assisté par ses collaborateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par courrier en date du 21 septembre 2015, reçu le lendemain et enregistré sous le numéro 266/15 le 23 septembre 2015, la société Horizon Plus a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l'attribution provisoire du marché relatif aux travaux de réalisation de la piste de production de 7,714 km entre les communes Guinguinéo et Ndiago, lancé par la Mairie de Ndiago.

LES FAITS

Par avis publié dans le journal « L'Observateur » du 08 avril 2015, la Commune de Ndiago a lancé un appel d'offres ouvert pour la réalisation d'une piste de production de 7,714 km entre la commune de Guinguinéo et celle de Ndiago avec comme date limite de dépôt des offres le 08 mai 2015.

Le premier appel d'offres ayant été déclaré infructueux et après avis favorable du pôle régional des marchés publics en date du 11 juin 2015, la Commune de Ndiago a, à travers un avis publié par le quotidien « Le Soleil » du 24 juin 2015, procédé à la relance du marché, les offres devant être déposées au plus tard le 24 juillet 2015.

A l'ouverture des plis, trois (3) offres ont été reçues et les montants ci-après lus à haute voix :

Noms des soumissionnaires	Montants FCFA TTC
Holding Guèye	128 547 428
Horizon Plus	122 676 760
E.M.A.D	224 373 637

Suite à la publication dans le journal « L 'Observateur» du 08 septembre 2015 de l'avis d'attribution provisoire à la holding GUEYE pour un montant de 128 547 428 FCFA TTC, la société Horizon Plus a, par lettre datée du 10 septembre 2015, introduit un recours gracieux auprès de l'autorité contractante.

Par courrier en date du 16 septembre 2015, cette dernière a répondu, en informant le requérant des motifs du rejet de l'offre.

Non satisfait de la réponse reçue, le requérant a, par correspondance enregistrée au service courrier de l'ARMP le 21 septembre 2015 sous le numéro 2546, introduit une requête auprès du Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester les motifs du rejet de son offre.

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n° 281/ARMP/CRD du 28 septembre 2015.

Par courrier en date du 30 septembre 2015, en vue de l'instruction du dossier, le CRD a demandé à l'autorité contractante de lui communiquer les pièces constitutives du dossier ainsi que ses observations sur le recours.

Par deux lettres des 29 décembre 2015 et 06 janvier 2016 reçus au service courrier de l'ARMP respectivement les 31 décembre 2015 et 08 janvier 2016 soit trois (3) mois après la décision de suspension, la Commune de Ndiago a transmis les documents demandés.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de son recours, le requérant soutient que la procédure est entachée de vices de procédure qui sont les suivants :

- le marché a été relancé sans qu'aucune notification ne soit faite aux soumissionnaires ;
- l'évaluation des offres a eu lieu le 24 juillet 2015 alors que la publication de l'attribution provisoire n'a été effectuée que le 08 septembre 2015 soit plus de 45 jours après, ce qui n'est pas conforme aux dispositions du Code des Marchés publics qui fixe le délai de publication à un mois ;
- le Maire de la Commune de Ndiago a, par courrier daté du 02 août 2015, demandé une prorogation de la durée de validité de la caution de soumission dans les 4 heures ; demande à laquelle il a accédé ;
- jusqu'à l'attribution provisoire, aucune autre évaluation n'a été faite pour ledit marché et aucun autre grief n'a été soulevé à son encontre.
- Le requérant ajoute, en outre, qu'il y a des risques de collusion, le Directeur général de la Holding GUEYE, attributaire du marché, étant le beau-frère du Maire de Ndiago d'où l'existence d'un conflit d'intérêts.

109

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours gracieux, l'autorité contractante relève que l'offre du requérant a été rejetée pour non-conformité de la caution qui n'a pas été actualisée à la date du 24 juillet 2015, date d'ouverture des plis du marché objet de la relance.

L'autorité contractante souligne que, sur suggestion du pôle régional des marchés publics de Kaolack qui ne disposait pas de la caution, elle avait demandé au requérant de proroger la durée de validité de cette dernière.

Elle reconnaît l'avoir fait « à la hâte », dans la mesure où lors de l'analyse de l'offre du requérant, l'autorité contractante s'est rendue compte que la caution devait d'abord viser le marché, objet de la relance, avant examen de sa durée de validité. Elle conclut que la prorogation de la durée ne règle pas la question de la validité de la caution qui, en fait, est relative au marché en date du 08 mai 2015, marché déclaré infructueux.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que le litige porte sur la conformité de l'offre de la société Horizon Plus notamment la validité de la garantie de soumission produite et sur la régularité de la procédure de passation du marché.

EXAMEN DU LITIGE

1) Sur la validité de la garantie de soumission

Considérant que selon les dispositions de l'article 68 du Code des Marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l'article 44 ;

Qu'ainsi, la commission détermine si les offres sont conformes aux conditions et spécifications du cahier des charges ;

Considérant que, l'article 44 du Code des Marchés publics dispose que le défaut de production de la garantie de soumission entraîne le rejet de l'offre ;

Considérant que la garantie de soumission a pour objet d'assurer le caractère fiable de l'offre et qu'elle vise à éviter la remise d'offres qui pourraient être retirées par les candidats avant la fin du processus de sélection ;

Qu'ainsi la référence au marché, objet de la garantie, est un élément substantiel de l'offre et que sa non-conformité la rend inopposable à son bénéficiaire ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse du procès-verbal de la commission d'évaluation du 23 mai 2015 qu'aucun candidat n'avait respecté les critères de qualification, ce qui avait conduit cette dernière à procéder à la déclaration d'infructuosité de l'appel d'offres ;

Considérant que, conformément aux dispositions du Code des Marchés publics, l'autorité contractante a demandé à la DCMP l'autorisation de relancer le marché en procédure d'urgence et que cette dernière y a répondu favorablement ;

Qu'il ressort de l'examen du dossier d'appel d'offres que le marché a, effectivement, fait l'objet d'une relance par un avis publié à travers le quotidien « Le Soleil » du 24 juin 2015 ;

Considérant que l'avis de publication de l'appel d'offres a précisé en son point 10 que les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable 28 jours après l'expiration du délai de validité des offres soit 148 jours après la date limite de dépôt des offres ;

Que l'ouverture des plis est intervenue le 24 juillet 2015 en présence du représentant du requérant qui a émargé sur la feuille de présence ;

Que, l'analyse de l'offre du requérant, révèle que la garantie de soumission produite vise le marché du 8 mai 2015 déclaré infructueux ;

Que la garantie de soumission de l'offre déposée le 08 mai 2015 avec une durée de validité de 148 jours expire le 06 octobre 2015 alors que la garantie afférente à l'offre déposée le 24 juillet 2015 expire normalement le 22 décembre 2015 ;

Que, faute d'avoir produit, lors de l'ouverture des plis des offres du marché relancé, une nouvelle garantie ou un acte de prorogation de la garantie du 08 mai, la commission d'ouverture des plis a, lors de la séance de ce jour, déclaré l'offre d'Horizon Plus non conforme ;

Qu'ainsi le rejet de l'offre du requérant par ladite commission pour ce motif est fondé ;

2) Sur les vices de procédure :

2.1) Le défaut de relance du marché :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que le premier marché en date du 8 mai 2015 a été déclaré infructueux suite à l'évaluation des soumissions et qu'une relance a été faite à travers l'avis publié dans le quotidien « Le Soleil » du 24 juin 2015 avec la mention relance et que le représentant du requérant était présent à la séance d'ouverture des plis et a même émargé sur la feuille de présence ;

Qu'ainsi le moyen soulevé par le requérant sur ce point ne peut prospérer ;

2.2) La publication tardive de l'attribution provisoire :

Considérant que l'analyse du dossier fait ressortir un retard dans la publication de l'attribution provisoire du marché qui n'est intervenue que quarante-cinq jours après, alors que les dispositions du Code des Marchés publics exige un délai de quinze jours, que ces retards ont été certes constatés par le pôle régional des marchés publics qui les a signalés à l'autorité contractante à travers un courrier en date du 29 août 2015 ;

Considérant, cependant, que ledit manquement n'a pas empêché la poursuite de la procédure ;

Considérant que ce moyen ne peut prospérer et qu'il résulte de ce qui précède que, la décision de rejet de l'offre du requérant par l'autorité contractante pour non-conformité, est justifiée ;

2.3) Sur Les conflits d'intérêts :

Considérant qu'une situation de conflit d'intérêts résulte de toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public ;

Considérant que le requérant soulève une situation de conflits d'intérêts qui n'est corroborée par aucun élément pertinent ;

Considérant qu'en définitive que le recours n'est pas fondé, qu'il y a lieu de le rejeter et, d'ordonner en conséquence la poursuite de la procédure et la confiscation de la consignation.

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que le marché de réalisation de la piste entre la Commune de Guinguinéo et celle de Ndiago a fait l'objet d'une relance et que l'ouverture des plis est intervenue le 24 juillet 2015 ;
- 2) Constate qu'à l'ouverture des plis, le requérant n'a pas produit une garantie de soumission ;
- 3) Dit que le rejet de l'offre du requérant, pour non-conformité, est fondé ;
- 4) Constate que la publication de l'avis d'attribution provisoire a accusé un retard qui a été relevé par le pôle régional des marchés publics de Kaolack ;
- 5) Dit que le dit manquement n'a pas fait obstacle à la poursuite du marché ;
- 6) Rejette, en conséquence, le recours ;
- 7) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché susvisé et la confiscation de la consignation ;
- 8) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société Horizon Plus, à la Commune de Ndiago, ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

112

Le Président
Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP	Boubacar MAR	Cheikhou Issa SYLLA
	Le Directeur général	
	Rapporteur	
	Saër NIANG	

Cette position du CRD, qui se fonde sur les articles susvisés, est pertinente parce que la production d'une garantie de soumission non-valide équivaut à un défaut de production de garantie, défaut qui est sanctionné par le rejet de l'offre du soumissionnaire concerné.

Les garanties que les candidats et titulaires des marchés publics doivent fournir sont prévues aux articles 114 à 120 du code de 2014. Il s'agit d'une part de la garantie de soumission et de la garantie de bonne exécution et d'autre part des autres garanties éventuellement fixées par le cahier des charges pour l'exécution d'un engagement particulier.

Le montant de la garantie de soumission est fixé dans le dossier d'appel d'offres et doit être compris entre 1% et 3% de la valeur estimée du marché, exception faite des marchés de prestations intellectuelles ; pour permettre à certaines entreprises particulières de participer au jeu de la concurrence, elles sont dispensées de fournir la

garantie de soumission lorsque la valeur du marché ne dépasse pas 50 millions CFA.

L'article 114 du code qui prévoit la garantie de soumission en fait une condition d'admission aux appels d'offres, mais ne précise pas son objet.

Mais on peut dire qu'elle vise à fiabiliser l'offre en évitant le retrait, par les candidats, des offres avant la fin du processus de sélection ; elle est destinée à protéger l'autorité contractante contre le soumissionnaire en cas de manquement aux obligations de ce dernier.

En effet l'engagement de la banque doit être de payer, sans réserve et d'une manière irrévocable à la première demande de l'autorité contractante.

Relativement à la garantie de bonne exécution (article 115 du code), son objet est bien précisé par le code qui dispose que : « tout titulaire d'un marché d'un montant supérieur ou égal aux seuils fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances doit fournir une garantie de la bonne exécution de celui-ci, destinée à couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie, éventuellement prévu. »

Et son montant est constitué en totalité lors de la signature du marché sans pouvoir dépasser 5% du marché (article 116). Ainsi défini, la « garantie de bonne exécution » prévu par l'article 115 du code sénégalais s'apparente à la « garantie à première demande » prévue par le code français des marchés publics en ses articles 101 et 102 en vertu desquels, « le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fraction sur chacun des versements autres qu'une avance... et son montant ne peut être supérieur à 5% du montant du marché...

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.

Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 102...

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. »

Le Conseil de Régulation de l'ARMP a adopté, par sa résolution n°03 du 9 avril 2013, un dossier-type incluant des modèles de garanties de soumission.

La notion de « garantie de soumission » n'est pas prévue par le code français. Pour la doctrine et la jurisprudence française, « la garantie à première demande » est une obligation autonome du contrat principal, c'est-à-dire qu'elle est indépendante des relations contractuelles existant entre le pouvoir adjudicateur (l'autorité contractante) et le titulaire du marché. Cela a pour conséquence principale que la garantie à première demande a la nature d'un contrat de droit privé, dont le contentieux incombe au juge judiciaire, y compris lorsque le marché a pour objet la réalisation de travaux (CE, ord, 3 novembre 2001, Ste Technibat Aluminium Service).

C.A.A Paris, 6 février 2007, Assistance Publique Hôpitaux de Paris.

14

**L'ABSENCE DE SOUS- CRITERE
PRECIS D'ÉVALUATION EST
SOURCE DE SUBJECTIVITÉ
ENTRAINANT UNE RUPTURE DE
L'ÉGALITE DE TRAITEMENT DES
CANDIDATS**

(ARTICLE 24 NOUVEAU DU COA)

Pour contester la note technique qui lui a été attribuée lors de l'évaluation des offres du marché relatif au recrutement d'un consultant, le cabinet Soluqua, suite au recours gracieux infructueux adressé à l'autorité contractante, saisit le CRD.

Par décision n°363 du 23 novembre 2016, le CRD, après avoir noté qu'aucun sous-critère précis devant permettre une notation objective n'a été prévu dans la demande de propositions, annula la procédure de passation du marché et ordonna sa relance avec les mêmes candidats en faisant valoir que l'absence de sous-critère précis est source de subjectivité entraînant une rupture d'égalité de traitement des candidats et qu'en vertu de l'article 24 nouveau du COA la violation du principe d'égalité de traitement des candidats aux commandes publiques par les acheteurs publics entraîne la nullité de la procédure de passation ou du marché passé.

DECISION N° 363/16/ARMP/CRD DU 23 NOVEMBRE 2016

DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU CABINET SOLUQUA CONSEIL CONTESTANT SA NOTE SUITE A L'EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES RELATIVE A LA DEMANDE DE PROPOSITIONS PORTANT SUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE TROIS (03) ENTREPRISES DANS LE PROCESSUS DE CERTIFICATION DU GLOBAL GAP, LANCE PAR LE MINISTERE DU COMMERCE, DU SECTEUR INFORMEL, DE LA CONSOMMATION, DE LA PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

VU la loi no 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21;

VU le décret no 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

VU le décret n° 2014-11212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

VU la résolution n° 09-12 du 13 décembre 2012 instituant le versement d'une consignation pour la saisine du Comité de Règlement des Différends ;

VU la résolution n°14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP ;

VU le recours du cabinet SOLUQUA Conseil du 02 novembre 2016 ;

VU la quittance de consignation n°100012016005620 du 02 novembre 2016 ;

VU la décision de suspension n°340/16/ARMP/CRD du 07 novembre 2016 ;

Madame Khadijetou DIA LY, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

ADOpte LA PRÉSENTE DÉCISION :

Par lettre du 02 novembre 2016, reçue et enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 312/CRD, le cabinet SOLUQUA Conseil a saisi le CRD pour contester la note technique qui lui a été attribuée, lors de l'évaluation des offres portant sur la demande de propositions relative au recrutement d'un consultant pour l'accompagnement de trois (03) entreprises, dans le processus de certification Global Gap, lancé par le Ministère du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits locaux et des PME (MCSICPPLPME).

LES FAITS

L'Unité nationale de Mise en œuvre du Programme Cadre Intégré Renforcé (UNMOCIR) a obtenu, dans le cadre du Programme d'amélioration de la Compétitivité de la Mangue Sénégalaise (PAMCS), des fonds pour financer l'accompagnement de trois (03) entreprises à la certification Global Gap.

L'UNMOCIR a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché précité, lancé par le Ministère du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits Locaux et des PME.

Dans cette perspective, et suite au dépouillement de l'avis à manifestation d'intérêt lancé à cet effet, elle a, par courrier n°0156/MCSICPPLPME/PCIR/PACMS du 08 août 2016, invité les cinq (05) candidats présélectionnés et listés, ci-après, à présenter leurs propositions :

1. Babacar SAMB, Cabinet BIOSCOPE ;
2. Souleye DIOUF, SOLUQUA Conseil ;
3. Boubacar DRAME, Laboratoire Phytopathologie ;
4. Papa Landing MANE, Cabinet LQT Consulting ; et
5. Papa Ndary NIANG, Cabinet AEC.

A la date d'ouverture des plis, le 02 septembre 2016 à douze (12) heures et zéro (00) minute, les deux (02) propositions ci-après ont été reçues :

1. Babacar SAMB, Cabinet BIOSCOPE ;

2. Souleye DIOUF, SOLUQUA Conseil.

A l'issue de l'évaluation des propositions techniques, la commission a attribué les notes suivantes aux candidats :

N°	Noms des candidats	Notes Techniques
1	BIOSCOPE	94 points
2	SOLUQUA Conseil	87.7 points

Informé de sa note par courrier électronique reçu le 25 octobre 2016, le cabinet SOLUQUA Conseil, utilisant le même canal, a demandé à l'autorité contractante de lui transmettre le détail de ladite note.

Par courrier électronique en date du 25 octobre 2016, le ministère a transmis au requérant le détail demandé.

Non satisfait des éléments fournis, le requérant a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux par lettre reçue le 27 octobre 2016.

En l'absence de réponse de l'autorité contractante à l'expiration du délai de trois jours qui lui était imparti pour répondre, le cabinet SOLUQUA conseil a porté sa réclamation devant le CRD par courrier reçu le 02 novembre 2016.

Par décision n°340/16/ARMP/CRD du 07 novembre 2016, le CRD a jugé le recours de SOLUQUA Conseil recevable, ordonné la suspension de la procédure de passation du marché et saisi l'autorité contractante pour disposer des documents nécessaires à l'instruction.

Par courrier du 15 novembre 2016, le Ministère a transmis à l'ARMP les pièces demandées.

LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de son recours, le cabinet SOLUQUA Conseil soutient que le critère « Expérience spécifique du consultant en rapport avec la mission », noté sur 30 points, est décliné à travers un sous-critère unique, à savoir, « l'expérience particulière dans la conduite de mission d'accompagnement à la certification Global Gap ». Il argue qu'il convient de noter, que même si ce sous-critère qui sert de base à la notation est imprécis, le chapitre IV des termes de référence, intitulé « Profil de l'Expert », précise bien les qualifications requises du consultant, et qui sont ci-après listées :

- avoir une bonne connaissance et une maîtrise de la version en vigueur du référentiel Global Gap ;
- avoir une bonne expérience dans l'accompagnement et la formation au principe du management de la qualité en général et du référentiel Global Gap, en particulier ;

- avoir accompagné au moins quatre (04) entreprises et, notamment, des groupements de producteurs de mangues, à la certification Global Gap, au cours des cinq (05) dernières années ;
- connaître le contexte de la production et de l'exploitation des mangues dans la zone des Niayes et de la Casamance serait un atout ;
- fournir, au moins, quatre (04) attestations de bonne exécution de services similaires.

Le requérant estime, qu'au regard des sous-critères sus-énoncés, son cabinet, ayant fourni dans sa proposition technique, quatre (04) « attestations de services faits » en accompagnement pour la certification Global Gap pour la production de mangues, devait, logiquement, obtenir la note maximale prévue pour le critère « Expérience spécifique du consultant en rapport avec la mission ».

Il signale, par ailleurs, que le chef de mission et l'assistant proposés ont participé à l'ensemble des missions pour lesquelles des références ont été fournies. Il précise, à ce propos, que leurs noms ont été expressément cités sur les attestations de bonne exécution produites, prouvant ainsi leur expérience spécifique dans le domaine.

Il estime, par conséquent, que les notes obtenues par ces derniers au titre, aussi bien de « l'expérience professionnelle » que de « l'expérience dans le domaine de la mission », ne sont pas justifiées.

C'est pourquoi, il a saisi le CRD pour être rétabli dans ses droits.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

L'autorité contractante a transmis les éléments du dossier en soulignant que le cabinet SOLUQUA Conseil a introduit son recours gracieux en contestation de sa note technique après avoir assisté à l'ouverture des offres financières tenue le 27 octobre 2016.

Elle précise qu'en agissant de la sorte, le requérant, qui a eu toutes les informations nécessaires, a ainsi pu faire le calcul lui permettant de connaître son rang, avant d'introduire son recours gracieux.

L'autorité contractante dénonce cette démarche. Elle argue que si le cabinet SOLUQUA Conseil n'était pas satisfait de la note technique qui lui a été attribuée et communiquée depuis le 25 octobre 2016, il aurait dû introduire son recours gracieux bien avant l'ouverture des offres financières ou, tout au moins, manifester son mécontentement lors de la séance d'ouverture des offres financières.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de la saisine et des moyens qui la sous-tendent que le litige porte, d'une part, sur la note technique attribuée au cabinet SOLUQUA Conseil relativement à l'expérience spécifique et l'expérience professionnelle des membres du personnel clé de la mission et, d'autre part, sur la tardiveté alléguée de l'introduction du recours gracieux.

EXAMEN DU LITIGE

1. Sur la tardiveté de l'introduction du recours gracieux portant sur la note technique du cabinet SOLUQUA Conseil

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 80.1 du Code des Marchés publics que les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à une présélection des candidats admis à présenter une offre, puis sont attribués après une mise en concurrence des candidats présélectionnés dans des conditions particulières ;

Qu'aux termes de l'article 80.1.e l'ouverture des propositions suite à la présélection des candidats s'effectue en deux temps :

- dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définis ; et
- dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté les offres jugées techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes ;

Considérant, par ailleurs, que le même Code des Marchés publics dispose, en ses articles 89 et 90, que tout candidat à un marché public doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel à la concurrence, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de trois (3) jours ouvrables imparti à l'autorité contractante pour répondre ;

Que ce recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d'appels d'offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que, par courrier électronique en date du 25 octobre 2016, l'autorité contractante a transmis au requérant sa note technique et l'a convié à l'ouverture des offres financières prévue le 27 octobre 2016 ;

Considérant que le requérant, après avoir réclamé et obtenu le détail de sa note technique le 25 octobre 2016, a introduit un recours gracieux le 27 octobre 2016 pour contester ladite note ;

Considérant que l'autorité contractante souligne la tardiveté de l'introduction du recours gracieux en signalant la démarche peu orthodoxe du requérant qui aurait d'abord, selon l'autorité contractante, assisté à l'ouverture des offres financières le 27 octobre 2016, ensuite procédé à des calculs pour connaître son rang et, par la suite introduit son recours gracieux après l'ouverture des offres financières ;

Considérant que le recours gracieux du cabinet SOLUQUA Conseil a été introduit le 27 octobre 2016, soit deux(02) jours après la réception de la notification de sa note technique ;

Qu'au regard des dispositions des articles 89 et 90 précités, le recours gracieux du requérant a été introduit dans les délais prescrits par la réglementation ;

Que dès lors, les arguments de l'autorité contractante soutenant que le cabinet SOLUQUA Conseil aurait dû porter sa contestation avant l'ouverture des offres financières ne sont pas fondés, d'autant plus que l'autorité contractante n'a prévu que peu de temps, deux (02) jours, entre la notification des notes techniques et la date prévue pour l'ouverture des offres financières ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la tardiveté du recours gracieux alléguée par l'autorité contractante n'est pas fondée ;

2. Sur la note technique attribuée au cabinet SOLUQUA Conseil

Considérant que la section 3 des Données particulières de la DP prévoit que les propositions techniques seront évaluées suivant les trois (03) critères que sont :

1. l'expérience spécifique du consultant en rapport avec la mission, notée sur trente (30) points ;
2. l'adéquation du plan de travail et de la méthodologie proposée vis-à-vis du mandat, notée sur vingt (20) points ; et
3. les qualifications de l'équipe proposée pour la mission, notées sur cinquante (50) points ;

Considérant que le requérant conteste la note technique de 87,7 points qui lui a été attribuée en faisant valoir que son cabinet aurait dû avoir le maximum de points pour les critères 1 et 3 puisqu'ayant l'expérience et les qualifications requises et dûment justifiées dans l'offre présentée ;

Que s'agissant de l'expérience spécifique du consultant dans la conduite de missions d'accompagnement à la certification Global GAP, le requérant a obtenu la note 26.6/30 qui est la moyenne des notes données par les évaluateurs 1, 2 et 3, à savoir respectivement 30, 25, 25 ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que le cabinet SOLUQUA Conseil au titre de l'expérience spécifique, a présenté comme requis quatre (4) attestations de services faits délivrées par :

- le président de COOPROFEL, coopérative de producteurs dont le siège est à keur MBIR NDAO, (certification obtenue en 2013).
- le président de BIO Niayes organisation, groupement de producteurs dont le siège est à Darou Khoudoss (certification obtenue en 2013 pour global gap option 2).
- Amadou ndiaye seck, Directeur général d'ANS import -export SN (certification obtenue en 2011) ;
- Ouattara Dahouido, directeur de Ouattara Trading Sénégal (certification obtenue en 2013 option 1 multi-site) ;

Que l'examen du dossier de l'entreprise BIOSCOPE, qui a obtenu la note globale pour ce sous critère de 28.33 points, a présenté pour prouver son expérience spécifique dans le domaine tout comme le requérant, quatre (4) attestations de bonne exécution délivrées par :

- le chef de mission de la composante 2 du programme d'appui au sous-secteur de l'irrigation de proximité au Mali en 2015,
- le directeur général des « saveurs du Sud » (certification 2015) ;
- Le coordonnateur national du programme de renforcement des capacités commerciales (PRDCC II, 10ème FED) ;
- Le directeur général de l'Exploitation Agricoles de NottoGouyeDiamma Sénégal (EANGDS) pour la période de mai à juin 2016 ;

Qu'au titre de ce critère, les deux soumissionnaires n'ont produit aucun autre document ;

Qu'ainsi, au regard du principe d'égalité des candidats, il n'est pas admissible qu'un soumissionnaire qui a produit les documents requis et similaires à ceux de son concurrent obtienne une note différente d'autant plus qu'aucune explication motivant la note attribuée au cabinet SOLUQUA Conseil n'a été fournie par l'autorité contractante ;

Qu'il y a lieu de reprendre l'évaluation en motivant les notes attribuées relativement à ce sous-critère ;

Que relativement au critère 3 portant sur les qualifications de l'équipe proposée pour la mission, les notes ci-après ont été attribuées aux candidats :

	Note maximale	Cabinet SOLUQUA Conseil	Cabinet BIOSCOPE
3. qualifications	50	40,99	46,31
3. 1 Consultant chef de mission	35	30,33	33,32
3.1.1 Formation académique	10	10	9,66
3.1.2 Expérience professionnelle	10	7	9
3.1.3 expérience dans le domaine de la mission	15	13,33	14,66
3.2 Assistant du consultant chef de mission	15	10,66	12,99
3.2.1 Formation académique	5	4,66	4,66
3.2.2 Expérience professionnelle et dans le domaine	10	6	8,33

Qu'il ressort de l'examen de la demande de propositions qu'aucun sous-critère précis devant permettre une notation objective n'a été prévu dans la demande de propositions ;

Qu'en effet, au titre de la formation académique, le niveau du diplôme requis n'a pas été précisé, il en est de même pour l'expérience professionnelle, le nombre d'années requis n'est pas indiqué ;

Que dans ces conditions, aucune évaluation transparente et objective basée sur des critères précis ne peut prévaloir ;

Qu'en effet, le défaut de transparence et d'objectivité du processus de l'évaluation est source de subjectivité et se traduit, par conséquent par une rupture d'égalité de traitement des candidats ;

Qu'il s'y ajoute qu'aux termes de l'article 24 nouveau de la loi portant Code des Obligations de l'Administration la violation du principe d'égalité de traitement des candidats aux commandes publiques par les acheteurs publics entraîne la nullité de la procédure de passation ou du marché passé ;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner l'annulation de la procédure et la relance de la demande de propositions avec les mêmes candidats, en prévoyant des critères précis permettant une correcte notation ;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu d'ordonner la restitution de la consignation

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que l'autorité contractante a notifié au cabinet SOLUQUA Conseil sa note technique le 25 octobre 2016 et l'a invité, dans le même courrier, à assister à l'ouverture des offres financières prévue le 27 octobre 2016 ;
- 2) Constate que le cabinet SOLUQUA Conseil a introduit un recours gracieux le 27 octobre 2016 ;
- 3) Dit que le recours gracieux du cabinet SOLUQUA Conseil a été introduit dans les délais prescrits par l'article 89 du Code des Marchés publics ;
- 4) Déclare que la tardiveté alléguée par l'autorité contractante n'est pas fondée ;
- 5) Constate que le requérant conteste la note technique qui lui a été attribuée relativement à l'expérience similaire du cabinet et à la qualification de l'équipe d'intervention ;
- 6) Constate, qu'au titre de l'expérience spécifique, le requérant, tout comme le cabinet BIOSCOPE, a fourni les quatre (04) attestations de services faits exigées dans la demande de propositions ;
- 7) Dit qu'en attribuant des notes différentes aux deux candidats qui ont produit les documents requis, l'autorité contractante n'a pas justifié sa notation ;
- 8) Constate qu'au titre de la qualification, aucun sous-critère précis, notamment le niveau du diplôme requis, le nombre d'années d'expérience exigé, n'a été défini dans la demande de propositions, pour permettre une notation objective ;
- 9) Dit que, dans ces conditions, la transparence du processus d'évaluation n'est pas garantie ;
- 10) Dit, ainsi, que le principe d'égalité de traitement des candidats n'est pas assuré ;
- 11) Déclare le recours du cabinet SOLUQUA Conseil fondé ;
- 12) Ordonne, en conséquence, l'annulation de la procédure de passation du marché et sa relance avec les mêmes candidats, en prévoyant des critères précis permettant une notation correcte ;
- 13) Ordonne la restitution de la consignation ;
- 14) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à SOLUQUA Conseil, au Ministère du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits locaux et des PME ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président
Mademba GUEYE

Samba DIOP

Les membres du CRD
Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA
Le Directeur Général,
Rapporteur
Saër NIANG

Le CRD a rendu beaucoup de décisions sur le fondement des articles 24 nouveau du COA et 67 du Code des marchés publics, sièges des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats (décisions numéro 260 du 24 septembre 2014, 11 du 14 janvier 2015, 73 du 25 mars 2015, 180 du 9 juillet 2015). Et à chaque fois que les principes en question ont été violés, il a annulé la procédure de passation du marché.

Le principe de transparence des procédures, le principe de l'égalité de traitement des candidats et le principe de liberté d'accès à la commande publique sont les trois principes fondamentaux du droit de la commande publique.

Au Sénégal, ils sont prévus par l'article 2 de la directive n°04/2005/CM/UEMOA et l'article 24 nouveau du code des obligations de l'administration (COA). En France c'est l'article 1er II du code des marchés publics qui disposent : « les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code. »

Les décisions du Comité de Règlement des Différends vont dans le même sens que la doctrine et la jurisprudence française. La doctrine considère que le principe d'égalité de traitement des candidats résulte du principe d'égalité, principe général du droit énoncé dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Ainsi, déjà en 1906, le commissaire du gouvernement Romieu écrivait dans ses conclusions : « le soumissionnaire évincé a le droit de demander l'annulation de l'adjudication pour inobservation des règles fondamentales, même si elles sont édictées dans l'intérêt de l'administration, du moment où une inégalité a été créée entre les concurrents (C.E, 30 mars 1906 Ballande, Rec, page 281).

Selon une jurisprudence constante, il convient de préciser les sous-critères dans le règlement de la consultation, voire selon certaines juridictions, dès l'avis d'appel public à la concurrence : (T.A. Marseille ; ordonnance du 26 juillet 2006, Communauté de communes de Trois Vallées, req. N° 0604605. Irrégularité de l'absence de précisions dans l'avis du critère valeur technique apprécié au regard de la conformité aux normes et de l'organisation de la mise en place des bacs roulants).

En France et en Europe de nombreuses règles ont été élaborées de même que des solutions jurisprudentielles pour faire respecter les principes d'égalité de traitement et de transparence :

- Les marchés et les critères d'attribution sont définis avec précision (CJCE, 14 octobre 2004, Commission c/France) ;
- Les critères utilisés par le pouvoir adjudicateur pour écarter les candidatures doivent être justifiés et adaptés à l'objet du marché et aux conditions de son exécution (CE, 14 janvier 1998, Ste martin-Fourquin, Rec,p.12) ;
- Le pouvoir adjudicateur doit placer les candidats dans la même situation, en

leur fournisseur, par exemple, les mêmes informations (CE, 13 mars 1998, SA Transport Galière, n°165238).

Pour la même doctrine, le principe de liberté d'accès à la commande publique veut dire que toute personne peut se porter candidate à l'attribution d'un marché public si elle remplit les conditions préalablement fixées par l'Administration.

Certes le pouvoir adjudicateur peut restreindre l'accès à la commande publique, mais à condition que cela résulte de l'objet même du marché ou des conditions de son exécution (CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-Minervois, Rec,p.1035 ;CE, 21 février 2000, syndicat Sud Travail).

La liberté d'accès à la commande publique s'applique à tous les marchés publics, quel que soit leur montant (CE, avis cont 29 juillet 2002, Ste MAJ Blanchisseries de Pantin, req. n°246921).

15

**L'IRRESPECT DE L'OBLIGATION
DE NOTIFICATION DES NOTES
TECHNIQUES AU MOMENT
INDIQUE ET LE FAIT DE NE PAS
LES LIRE A HAUTE VOIX A LA
SEANCE D'OUVERTURE DES
OFFRES FINANCIERES PORTENT
ATTEINTE AU PRINCIPE DE
TRANSPARENCE**

Le bureau de Mise à niveau (BMN) a lancé le 19 janvier 2016 une Demande de Renseignement et de Prix (DRP) restreinte relative à la sélection d'un cabinet pour la réalisation des missions d'assistance comptable et de gestion de sa paie au titre de la gestion 2016.

Appelé à participer à la compétition, le cabinet Grant Thornton, qui a déposé ses propositions technique et financière le 27 janvier 2016, fut invité, par la suite, à la séance d'ouverture des propositions financières tenues le 9 février 2016.

Néanmoins, l'autorité contractante lui fit savoir le 10 février 2016 que le marché a été attribué provisoirement au cabinet KPMG.

Suite au recours gracieux qu'il effectua auprès de l'autorité contractante, le cabinet Grant Thornton saisit le CRD d'un recours contentieux en faisant valoir, entre autres, que non seulement sa note technique ne lui a été communiquée qu'au moment de l'attribution provisoire, mais également que les noms des candidats et des notes techniques n'ont pas été lus à haute voix au cours de la séance d'ouverture des propositions financières.

Par décision n°72 du 9 mars 2016, le CRD prononça l'annulation de la procédure et ordonna sa reprise aux motifs que d'une part il y a eu irrespect de l'obligation d'information des candidats dans la mesure où il y a eu violation de la clause 14.1 des IC qui prévoit qu'à l'issue de l'évaluation de la qualité technique l'autorité contractante informe des notes techniques obtenues par leurs propositions; que les notes techniques n'ayant été communiquées qu'au moment de l'attribution provisoire du marché, le requérant n'a pas pu exercer son droit de recours avant la tenue de la séance d'ouverture des offres financières; que d'autre part le CRD a estimé que la commission des marches n'ayant pas respecté l'obligation de la lecture à haute voix des notes techniques au cours de la séance d'ouverture des offres financières, il y a eu également violation de la clause 14.2 des Instructions aux Candidats (IC).

DECISION N°072/16/ARMP/CRD DU 09 MARS 2016

**DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LE RECOURS DE GRANT THORNTON CONTESTANT
L'ATTRIBUTION PROVISoire DU MARCHE, OBJET DE LA DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX RESTREINTE N° C-BMN-044 RELATIVE A
L'ASSISTANCE COMPTABLE ET LA GESTION DE LA PAIE, LANCE PAR LE
BUREAU DE MISE A NIVEAU (BMN), PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTERE
DU COMMERCE, DU SECTEUR INFORMEL, DE LA CONSOMMATION, DE LA
PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX ET DES PME.**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la résolution n°14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du CRD ;

Vu le recours du cabinet Grant Thornton en date du 17 février 2016 ;

Vu la quittance de consignation du 17 février 2016 ;

Après avoir entendu le rapport de Madame Mame Aïssatou Dieng TRAORE, chef de la Division des Appuis techniques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Khadijetou Dia LY, Contrôleur de Gestion, assurant l'intérim du Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération :

Par lettre du 16 février 2016, reçue le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 046/16, le cabinet Grant Thornton a saisi le CRD pour contester l'attribution provisoire du marché susvisé.

LES FAITS

Le Bureau de Mise à niveau (BMN) a lancé le 19 janvier 2016, la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) restreinte relative à la sélection d'un cabinet pour la réalisation des missions d'assistance comptable et de gestion de sa paie au titre de la gestion 2016.

Le cabinet Grant Thornton, suite à cette invitation, a déposé le 27 janvier 2016, des propositions technique et financière auprès dudit Bureau.

Ce dernier a, par la suite, invité par courrier en date du 08 février 2016, le cabinet Grant Thornton à la séance d'ouverture des propositions financières tenue le 09 février 2016.

Le tableau, ci-après, reflète les offres financières proposées par les soumissionnaires retenus à la suite de l'évaluation des propositions techniques.

N°	CABINETS/ SOUMISSIONNAIRES	PROPOSITIONS FINANCIERES F CFA (TTC)
1	DELOITTE	24 717 991
2	KPMG	19 130 160
3	GRANT THORNTON	16 638 000
4	MAZARS	19 996 000

Le Bureau de mise à niveau a, par courrier en date du 10 février 2016 reçu le lendemain, fait parvenir au cabinet Grant Thornton la notification de l'attribution provisoire du marché à KPMG pour un montant TTC de 19 130 160 FCFA. Il lui fait observer qu'après combinaison de ses notes technique et financière, son résultat ne le classe pas en première position en dépit de sa note technique de 80 points /100, jugée satisfaisante.

Dés réception de ladite notification, le requérant a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux, par courrier en date 12 février 2016.

Non satisfaite de la réponse de l'autorité contractante reçue le 17 février 2016, le requérant a saisi le CRD d'un recours contentieux. Ce dernier, après examen de la demande, a ordonné, par décision N°051/16/ARMP/CRD du 19 février 2016, la suspension de la procédure et sollicité de l'autorité contractante la transmission des éléments du dossier.

Par courrier reçu le 29 février 2016, l'autorité contractante a transmis les pièces demandées aux fins d'instruction.

129

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de son recours, Grant Thornton soutient, d'abord, que la commission des marchés ne lui a communiqué sa note technique qu'au moment de la notification de l'attribution provisoire. Or, selon le requérant, cette notification aurait dû intervenir à la fin des travaux d'évaluation des propositions techniques et avant la séance d'ouverture des propositions financières. Il estime que l'autorité contractante a violé les dispositions des clauses 14.1 et 14.2 des Instructions aux soumissionnaires (IC) qui posent respectivement les obligations suivantes :

- information des candidats sur les notes techniques obtenues à l'issue de l'évaluation des propositions techniques ;
- lecture des noms des candidats et des notes techniques, à haute voix, au cours de la séance d'ouverture des propositions financières.

Le cabinet Grant Thornton fait observer ensuite que la commission des marchés n'a pas attribué le marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme la moins disante comme stipulé par l'arrêté n° 00107 du date du 07 janvier 2015 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan. Il insiste, à nouveau, sur la qualité technique de son offre reconnue par le BMN et également sur le caractère moins disant de sa proposition financière.

LES MOYENS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Relativement à l'absence de notification des notes techniques, la commission des marchés du BMN, au regard des dispositions de l'arrêté du MEF invoqué par le requérant, signale que les différentes étapes de la procédure de DRP ont été respectées.

Concernant le deuxième grief relatif au défaut de rappeler les notes techniques au cours de la séance d'ouverture des propositions financières, le BMN reconnaît ce manquement mais précise, cependant, que les représentants des soumissionnaires n'ont fait aucune remarque dans ce sens bien qu'interpellés par le représentant de la cellule de passation des marchés, avant que le président de séance n'ait procédé à l'ouverture desdites offres financières.

S'agissant enfin du grief soulevé par le requérant et portant sur les critères d'évaluation du marché, l'autorité contractante souligne que la méthode de sélection retenue pour évaluer les propositions soumises dans le cadre de cette DRP est bien celle basée sur le rapport qualité-coût et méthode de sélection relative au moindre coût conformément à la clause 1.1 des Données Particulières (DPAO). Elle ajoute que les clauses 14.3 et 14.4 des DPAO indiquent clairement les poids pour la pondération des notes techniques (70) et financières (30) ainsi que la formule de calcul retenue qui sert de base à l'attribution du marché au candidat ayant obtenu la note totale pondérée la plus élevée et qui accepte les conditions d'exécution du marché. Le BMN conclut en faisant remarquer que la réglementation en la matière a été respectée.

130

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que l'objet du litige porte sur :

- 1) le bien fondé du classement des candidats ;
- 2) le défaut de notification des notes techniques aux candidats à la fin des travaux d'évaluation des propositions techniques ;
- 3) le défaut de lecture, à haute voix, des notes techniques au cours de la séance d'ouverture des offres financières ;

AU FOND

1) Sur le bien fondé du classement des candidats

Considérant que la clause 14.4 des Données particulières de la DRP stipule que : « la formule utilisée est la Sélection qualité coût Soit $Sf = 100 \times Fm/F$, Sf étant le score financier, Fm la proposition la moins-disante et F le montant de la proposition considérée.

Les propositions sont ensuite classées en fonction de leurs scores techniques (St) et financiers (Sf) combinés après introduction des coefficients de pondération :

Considérant que les coefficients de pondération appliqués aux notes techniques et financières sont respectivement de 0,7 et 0,3 ;

Considérant qu'à l'issue de l'évaluation des propositions techniques et financières, la commission des marchés a attribué aux cabinets les notes ci-après et dressé le classement suivant :

Noms des candidats	Evaluation technique		Evaluation financière		Evaluation combinée	
	Notes techniques N(t)	Notes techniques pondérées N(t) x70%	Notes financières N(f)	Notes financières pondérées N(f) x30%	N(t) T + N(f) F	Classement
KPMG	88	62	0,87	26	88	1 ^{er}
MAZARS	89	62	0,83	25	87	2 ^{ème}
G r a n t Thornton	80	53	1,00	30	86	3 ^{ème}
Deloitte	91	64	0,67	20	84	4 ^{ème}

Qu'à l'analyse, il apparaît que la commission des marchés a fait une bonne application des critères retenus pour évaluer les propositions techniques et financières ;

131

Qu'en outre, il ya lieu de retenir qu'une offre financière moins-disante à l'ouverture des plis n'induit pas automatiquement l'attribution du marché à son auteur s'il est constant qu'elle doit faire l'objet d'une évaluation conformément aux critères fixés dans le dossier de consultation ;

Qu'en considération de ce qui précède, la proposition de la commission des marchés d'attribuer provisoirement le marché à KPMG se justifie ;

Qu'à cet égard la demande du requérant n'est pas fondé ;

2°) Sur le défaut de notification des notes techniques à la fin des travaux d'évaluation des offres techniques ;

Considérant que l'article 24 nouveau du Code des Obligations de l'Administration (COA) stipule que « Le non respect des formalités de publicité prescrites et la violation du principe d'égalité de traitement des candidats aux commandes publiques par les acheteurs publics entraînent la nullité de la procédure de passation du marché passé, à la requête de toute personne intéressée au déroulement normal de la procédure » ;

Considérant que la clause 14.1 des IC stipule qu' « à l'issue de l'évaluation de la qualité technique, l'autorité contractante informe les candidats des notes techniques obtenues par leurs Propositions. Dans le même temps, l'autorité contractante (a) notifie aux candidats dont les propositions n'ont pas obtenu la note de qualité minimale, ou ont été jugées non conformes à la Demande de propositions et aux Termes de référence, que leurs Propositions financières leur seront renvoyées sans

avoir été ouvertes, à l'issue du processus de sélection et (b) indique la date, le lieu et l'heure d'ouverture des Propositions financières aux Candidats dont les propositions techniques ont obtenu une note supérieure à la note de qualification minimale »

Considérant que le requérant reproche à la commission des marchés la violation de cette exigence, notamment la non communication des notes techniques aux soumissionnaires à l'issue de l'évaluation des propositions techniques ;

Considérant qu'en réponse à ce reproche, le BMN se justifie en invoquant le caractère simplifié de la procédure de DRP ;

Qu'à ce propos, il reste constant que l'obligation d'information des candidats n'est pas respectée ;

Considérant que l'inobservation de cette formalité est de nature à porter atteinte à la transparence du processus en privant les candidats d'informations sur la procédure de passation de la DRP ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le grief soulevé, par le requérant, est fondé ;

3°) Sur le défaut de lecture, à haute voix, des notes techniques au cours de la séance d'ouverture des propositions financières ;

Considérant que la clause 14.2 des IC stipule que « les Propositions financières sont ouvertes en séance publique par la commission des marchés de l'autorité contractante, en présence des représentants des Candidats qui désirent y assister. Les noms des candidats et les notes techniques sont lus à haute voix. Les Propositions financières des candidats ayant atteint ou dépassé la note de qualification minimale sont examinées pour vérifier qu'elles n'ont été ni décachetées ni ouvertes. Ces Propositions sont ensuite ouvertes et les prix sont lus à haute voix et consignés par écrit. Une copie du procès-verbal est envoyée à tous les candidats » ;

Considérant que la commission des marchés a reconnu que les notes techniques n'ont pas été lues au cours de la séance d'ouverture des propositions financières comme prévu à la clause 14.2 des IC ;

Considérant que seuls les candidats dont les propositions techniques ont atteint une note égale ou supérieure à la note de qualification minimale sont invités à l'ouverture des offres financières ;

Que les notes techniques ont été communiquées au moment de l'attribution provisoire du marché ;

Considérant que le non-respect de cette formalité, a empêché le requérant d'exercer son droit de recours avant la tenue de la séance d'ouverture des offres financières ;

Que dès lors, le recours du requérant sur ce point est justifié ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'ordonner l'annulation de la procédure et sa reprise en respectant les obligations liées à la procédure spécifique de passation d'un marché de prestations intellectuelles ;

En conséquence, le recours ayant prospéré, il y a lieu de restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Déclare recevable le recours du cabinet Grant Thornton ;
- 2) Constate que l'autorité contractante a attribué le marché sur la base de la sélection qualité-coût conformément aux critères d'évaluation prévus dans la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) restreinte ;
- 3) Constate que le requérant n'a pas obtenu la meilleure note globale pondérée ;
- 4) Constate que le Bureau de mise à niveau n'a pas notifié aux candidats les résultats de l'évaluation des propositions financières au moment indiqué ;
- 5) Constate que la commission des marchés n'a pas respecté l'obligation de la lecture, à haute voix, des notes techniques au cours de la séance d'ouverture des offres financières ;
- 6) Dit que ces manquements ont porté atteinte au principe de transparence de la passation du marché ;
- 7) Déclare que le non respect des formalités d'information prescrites entraîne la nullité de la procédure de passation du marché ;
- 8) Ordonne l'annulation de la procédure et sa reprise ;
- 9) Ordonne la restitution de la consignation;
- 10) Dit que le Directeur général de l'autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au cabinet Grant Thornton, au Bureau de Mise à Niveau ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

133

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Pour le Directeur Général, par intérim,

Rapporteur

Khadijetou DIA LY

Cette décision est pertinente dans la mesure où ces manquements de la Commission des marchés ont porté atteinte au principe de transparence de la passation des marchés.

La position du CRD, en la matière, est constante, car à chaque fois que le principe de transparence, prévu par l'article 67 alinéas 2 et 3 du code et l'article 24 du COA, ont été violés il a annulé la procédure ; il en a été ainsi par exemple dans ses décisions numéro 180 du 9 juillet 2014, numéro 11 du 14 janvier 2015 et numéro 73 du 25 mars

2015 ; de même qu'il en a été également ainsi dans sa décision n°3 du 11 janvier 2010 où le Bureau Véritas, qui était attributaire provisoire du marché, avait introduit , par la suite, devant la Cour suprême, un recours en annulation de cette décision n°3 du 11 janvier 2010 ; mais la haute Cour le rejeta, adoptant ainsi la même démarche que le CRD.

En France et en Europe, les décisions vont dans le même sens.

- CJCE (Cour de Justice de l'Union Européenne), 18 novembre 2010, Commission Européenne contre Irlande, Aff. C. 226/09 (conditions de mise en œuvre des critères d'attribution. Impossibilité de modifier la pondération des critères d'attribution en cours de procédure) ;

- C.J.C.E., 12 décembre 2002, Universale – Bau AG, Aff. C.470/99, contrats et marchés publics, mars 2003, n° 51, p. 26, note G. Ekert (obligation de mention de la pondération des critères dans les documents de consultation lorsque le pouvoir adjudicataire les a fixés préalablement) ;

- C.E., 14 janvier 1998, Préfet du Val-d'Oise contre Office Départemental d'HLM du Val d'Oise, réq. N° 165416 (irrégularité d'une précision ou complément d'offres entraînant un ajout à l'offre initiale).

Pour la doctrine française, « la transparence est une obligation quasi générale d'éviter l'opacité des procédures de décision publique, dans le but de permettre la vérification de l'observation d'autres règles, en particulier celle de non-discrimination dans le cadre de la passation des contrats publics, essentiellement au moyen d'une publicité adéquate ou éventuellement une autre forme d'information, par exemple l'accès à certains documents administratifs. La transparence de la passation des contrats publics s'impose en vertu de règles communautaires et constitutionnelles ainsi qu'en application de divers textes, notamment en matière de marché publics. »

16

**LES MANQUEMENTS DU
CANDIDAT RELATIFS A
L'EXECUTION DE MARCHES
ANTERIEURS DOIVENT
ENTRAINER LA SAISINE DU CRD**

(ARTICLE 148 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

Aux termes de l'article 148 du code des marchés publics, en cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises par les candidats et titulaires de marchés, des sanctions peuvent être prononcées par le Comité de Règlements des Différends de l'organe chargé de la régulation des marchés publics, siégeant en formation disciplinaire, contre les auteurs de ces violations.

Les violations commises sont constatées par le CRD qui diligente toutes les enquêtes nécessaires et saisit toutes les autorités compétentes.

Dans le cadre d'un marché lancé par l'Hôpital Général de Grand Yoff, la société Equipement Travaux d'Imprimerie (ETI), qui était soumissionnaire, a été écartée alors que son offre était moins disante que celle de l'entreprise attributaire provisoire, aux motifs qu'ETI avait commis des manquements dans l'exécution de marchés antérieurs.

Après avoir intenté un recours gracieux auprès de l'autorité contractante, la société ETI saisit le CRD qui ordonna l'annulation de la procédure de passation du marché et la reprise de l'évaluation par décision n°123 du 27 avril 2016.

A l'appui de sa décision, le CRD a fait valoir qu'en écartant l'offre de la société ETI pour des motifs autres que ceux relatifs aux violations des dispositions du dossier d'appel d'offres, la commission des marchés n'a pas justifié sa décision, car même si ladite société a commis des manquements relatifs à l'exécution de marchés antérieurs, l'autorité contractante aurait dû en saisir le CRD ou le juge pour obtenir une décision d'exclusion du candidat.

DECISION N° 123/16/ARMP/CRD DU 27 AVRIL 2016

DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

COMMISSION LITIGE SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE EQUIPEMENT TRAVAUX IMPRIMERIE, RELATIF A LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHES D'IMPRIMES ET D'IMPRESSION, LANCEE PAR L'HOPITAL GENERAL DE GRAND YOFF

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

VU la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

VU le décret no 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation ;

VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU la décision n° 005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

VU la résolution n°14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends ;

VU la demande de l'Entreprise Equipement Travaux Imprimerie (ETI) du 07 avril 2016 ;

VU la quittance de consignation du 08 avril 2016 ;

VU la décision n°101/16/ARMP/CRD du 12 avril 2016 portant suspension de la procédure de passation de marchés d'imprimés et d'impression lancée par l'Hôpital général de Grand Yoff ;

Monsieur Baye Samba DIOP, Chef de division régulation et affaires juridiques, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de régulation ;

Adopte la présente décision ;

Par courrier daté le 07 avril 2016, reçu à l'ARMP le 08 avril 2016, Equipement Travaux Imprimerie (ETI) a saisi le CRD pour contester l'attribution provisoire du marché relatif à la fourniture d'imprimés et d'impressions à l'Hôpital Général Grand Yoff.

137

LES FAITS

Par avis publié le 23 janvier 2016 dans le quotidien « Le Soleil », l'Hôpital général de Grand Yoff (HOGGY) a lancé un appel d'offres en deux lots afin d'acquérir des imprimés et impressions.

A l'ouverture des plis, les offres reçues pour les deux lots se présentent ainsi qu'il suit :

Nom ou raison sociale du candidat	Montant de l'offre en FCFA TTC pour le lot 1	Montant de l'offre en FCFA TTC pour le lot 2
SODIC	55 947 340	
ETI	43 843 844	
Imprimerie papeterie et services (I.P.S)	52 113 614	
Imprimerie SALAM	52 160 012	16 789 000
LANIANE ENTREPRISE	57 968 114	16 512 180
BUROTIC CENTER		17 458 100

Après évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d'attribuer les deux lots du marché à l'Imprimerie SALAM.

L'autorité contractante a approuvé la proposition d'attribution des lots et a fait publier l'avis d'attribution provisoire du marché dans le quotidien « Le Soleil » du 01 avril 2016.

Non satisfait, ETI a intenté un recours gracieux, le même jour, au niveau de l'autorité contractante et, auquel cette dernière a répondu par lettre datée du 05 avril 2016 reçue 06 avril 2016.

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n°101/16/ARMP/CRD du 12 avril 2016 et a demandé la transmission du dossier.

Par lettre du 20 avril 2016, HOGGY a transmis les éléments nécessaires à l'instruction du dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, ETI conteste les motifs invoqués par l'autorité contractante en mentionnant n'avoir jamais reçu de procès-verbal de carence encore moins une mise en demeure provenant de HOGGY.

Par ailleurs, il a fait les observations suivantes sur les procès-verbaux de carence :

- le procès-verbal de carence référencé BC 3222 est daté le 03 juin 2014 alors que la date d'attribution du marché est le 11 juin 2014 ;
- la livraison des fournitures concernées par le procès-verbal de carence référencé BC 3228 a démarré avant la réception du bon de commande du 31 juillet 2014 ;
- la commande concernant le procès-verbal de carence référencé BC n°1017-1018 a été livrée et facturée le 21 octobre 2010, bien avant même la date mentionnée dans le procès-verbal de carence.

Il affirme avoir livré et facturé tous les produits et matériaux relatifs aux bons de commande reçus de l'autorité contractante.

ETI déclare, en outre, avoir exécuté durant les cinq (5) dernières années les marchés à la satisfaction de l'autorité contractante qui a délivré des attestations de bonne exécution à cet effet.

Le requérant mentionne aussi n'avoir jamais reçu de retour de produits d'imprimés.

C'est pourquoi, il demande au CRD d'annuler l'attribution provisoire.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse, l'autorité contractante informe que l'entreprise ETI a été attributaire de marchés de fourniture d'imprimés et de consommables informatiques de l'Hôpital de Grand Yoff de 2010 à 2014.

Elle déclare que l'exécution des marchés précités avait engendré des dysfonctionnements substantiels au niveau de l'ensemble des services de l'hôpital, plus particulièrement au niveau des services médico-techniques qui arrêtaient souvent leurs activités pour des raisons liées à des ruptures de stock ou à la très mauvaise qualité des imprimés et produits d'impression livrés par ETI.

Elle ajoute que, cette situation avait fini de placer les praticiens de l'hôpital dans une posture difficile car ils n'arrivaient plus à assurer le suivi des dossiers des patients.

Elle mentionne que selon l'avis du chef du service technique de la maintenance, les cartouches de mauvaises qualités fournies par ETI ont provoqué des pannes de plusieurs équipements informatiques.

Ensuite, elle affirme que des procès-verbaux de carence sont dressés et des lettres de mise en demeure sont adressées au requérant pour lui rappeler l'impérieuse nécessité de respecter ses engagements contractuels afin de mettre un terme au lourd préjudice qu'il portait au fonctionnement régulier de l'ensemble des services de la structure.

Ainsi, l'hôpital déclare que l'attribution du marché à l'ETI représente un réel risque de santé publique et pourrait contribuer à perturber la sérénité qui y règne.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que le litige porte sur le rejet de l'offre du requérant pour des motifs tirés de la défaillance du candidat dans l'exécution de marché antérieur.

AU FOND

Considérant qu'en vertu de l'article 35 du Code des Marchés publics, la commission des marchés de l'autorité contractante a la compétence exclusive pour évaluer les offres des candidats, dans les conditions fixées aux articles 68 et suivants du Code ;

Considérant que l'article 68 du Code des Marchés publics dispose qu'avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission

des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 44, et rejette les offres non recevables ;

Considérant que l'article 44 du Code des Marchés publics prévoit que sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle ou industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, technologiques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence ;

Considérant qu'il apparaît de l'instruction que le requérant a produit les attestations de services faits suivants :

- une attestation de bonne exécution délivrée le 27 février 2014 par le Centre hospitalier national Mathlaboul Fawzaini de Touba ;
- une attestation de service fait délivrée le 22 janvier 2015 par le Centre hospitalier national de Pikine ;
- une attestation de bonne exécution délivrée le 12 février 2014 par le Centre hospitalier de Grand Yoff ;

Considérant qu'il apparaît de l'instruction que le candidat a satisfait aux critères fixés dans le DAO ;

Considérant que l'offre du candidat est moins onéreuse que celle de l'attributaire provisoire pour le lot 1 ;

Qu'en conséquence, la commission des marchés n'a pas justifié le rejet de l'offre du requérant ;

Considérant, par ailleurs que l'autorité contractante reproche au requérant d'avoir commis des fautes dans l'exécution de marchés antérieurs;

Considérant qu'il apparaît de l'instruction que l'autorité contractante a constaté des manquements dans l'exécution des marchés antérieurs du fait du requérant ;

Qu'à cet effet, des procès-verbaux de carence sont dressés le 05 novembre 2010 et le 27 juin 2014 ;

Considérant par ailleurs, que l'autorité contractante a adressé des correspondances pour attirer l'attention sur les manquements constatés notamment :

- par lettre 07 avril 2014, à laquelle le requérant a répondu le 13 mai 2014 en expliquant que ce retard est dû à des difficultés de transports consécutives à un groupage ;
- par lettre de mise en demeure du 28 avril 2014, à laquelle le requérant a répondu le 14 mai 2014 dans laquelle il justifie ce retard du fait des problèmes de paiement qu'ils avaient avec son fournisseur ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 148 du Code des Marchés publics, en cas de contestation de violations des règles de passation des marchés publics commises par le candidat et titulaire de marché, des sanctions peuvent être prononcées par le Comité de Règlement des Différends de l'Organe chargé de la régulation des marchés publics, siégeant en formation disciplinaire, contre les auteurs de ces violations ;

Que les violations commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes ;

Considérant que même s'il est constant que des manquements relatifs à l'exécution de marchés antérieurs sont constatés par l'autorité contractante, elle ne peut pas écarter un candidat d'un marché sans saisir le CRD ou le juge, qui sur peuvent prononcer l'exclusion temporaire ou définitive du candidat ;

Qu'en conséquence, l'autorité contractante aurait dû saisir le CRD ou le juge pour obtenir une décision d'exclusion contre le requérant ;

Qu'en écartant l'offre du candidat pour des motifs autres que ceux relatifs aux violations des dispositions du DAO, la commission des marchés n'a pas justifié sa décision ;

Qu'il y a lieu d'annuler l'attribution provisoire et d'ordonner la reprise de l'évaluation ;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu d'ordonner la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate les motifs de rejet de l'offre de la société Equipement Travaux Imprimerie par l'autorité contractante ne sont pas constitutifs de violation du DAO ;
- 2) Constate que l'autorité contractante a constaté des manquements de la société Equipement Travaux Imprimerie dans l'exécution de marchés antérieurs ;
- 3) Dit que l'autorité contractante ne peut pas écarter un candidat d'un marché sans avoir obtenu au préalable une décision d'exclusion du Comité de Règlement des Différends ou du juge ;
- 4) Dit que l'autorité contractante aurait dû saisir le Comité de Règlement des Différends pour demander l'exclusion temporaire ou définitive du candidat de ses marchés ;
- 5) Dit que le rejet de l'offre du candidat n'est pas fondé ;
- 6) Ordonne l'annulation de la procédure de passation du marché et la reprise de l'évaluation ;
- 7) Ordonne la restitution de la consignation ;
- 8) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la société Equipement Travaux Imprimerie, l'Hôpital

Général de Grand Yoff ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président
Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP **Boubacar MAR**

Directeur Général, par intérim,

Rapporteur

Saër NIANG

Cette décision du CRD s'appuyant sur la règle de l'article 148 susvisé est pertinente parce qu'il appartient au CRD, et non à l'autorité contractante, d'enquêter et de prononcer des sanctions.

17

**L'APPEL D'OFFRES EST LE
PRINCIPE ET L'ENTENTE
DIRECTE OBEIT A DES
CONDITIONS LIMITATIVEMENT
ENUMEREES PAR LA LOI**

**(ARTICLE 26 NOUVEAU DU COA, ARTICLE 76 DU
CODE DES MARCHES PUBLICS ET ARTICLE 38 DE LA
DIRECTIVE 4/2005/UEMOA)**

Le Code des Obligations de l'Administration dispose en son article 26 nouveau, alinéa 1er : « l'appel d'offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les conditions stipulées par le code des marchés publics.»

Par dérogation à ce principe, l'article 76 du code des marchés publics (comme l'article 38 de la directive 4/2005/UEMOA) prévoit la possibilité de conclure un marché par entente directe dans des conditions limitativement énumérées, à savoir en cas de :

- Situation d'exclusivité ;
- Marché complémentaire ;
- Urgence impérieuse ;
- Marchés classés « secret » ;
- Marchés passés dans le cadre de mesure de mobilisation générale.

Ainsi, à chaque fois qu'une autorité contractante saisit la DCMP, soit pour obtenir, selon le cas, son autorisation ou son avis pour conclure un marché par entente directe, cette Direction, chargée du contrôle à priori des marchés publics, vérifie si l'une des conditions visées par l'article 76 susvisé est remplie.

Et si aucune desdites conditions n'existe la DCMP émet un avis négatif. De même que si l'autorité contractante concernée saisit le CRD pour obtenir l'autorisation de poursuivre la procédure, malgré ledit avis, ce dernier, d'une manière générale, en s'appuyant sur les dispositions pertinentes précitées, rejette le recours en ordonnant à l'autorité contractante de conclure le marché dans le respect de la réglementation (décision du CRD n°42 du 18 février 2015 et 86 du 8 avril 2015).

Mais pour la confection des bulletins de vote et des documents électoraux relatifs aux élections locales du 29 juin 2014 (initialement prévues le 16 mars 2014), alors que la DCMP avait estimé que les conditions de recourir à l'entente directe n'étaient pas remplies, par contre le CRD avait estimé que lesdites conditions étaient remplies et avait autorisé la passation des marchés par entente directe en faisant valoir qu'il y'avait une urgence impérieuse résultant de circonstances irrésistibles et extérieures à l'autorité contractante (décision n°65 du 12 mars 2014).

Par ailleurs, en vertu du dernier alinéa de l'article 76 du code de 2014, « le Premier Ministre peut certifier par notification écrite à l'organe chargé de la régulation des marchés publics et à celui chargé du contrôle des marchés publics que, pour des raisons tenant aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d'intérêt général, l'attribution du marché doit être poursuivie immédiatement. »

C'est ainsi que dans le cadre du marché initié par l'APIX, malgré l'avis négatif émis par la DCMP, le CRD a autorisé à l'APIX, à titre exceptionnel, de conclure par entente directe avec le cabinet SYSTRA le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; le CRD s'est fondé sur le fait que le Premier Ministre a certifié, par lettre du 16 décembre 2014 adressée à l'ARMP, la nécessité d'autoriser la conclusion du contrat au regard

de l'intérêt général et des contraintes de délai imposées par le partenaire technique et financier et de l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet (décision CRD n°346 du 17 décembre 2014).

Ici aussi l'article 38 de la directive 04/2005/CM/UEMOA, qui prévoit l'entente directe, ne prévoit pas cette exception accordée suite à une certification d'une autorité.

Néanmoins, il y a lieu de noter qu'en 2016, en la matière, les décisions du CRD vont dans le sens du respect strict de la règle de droit (décisions du CRD n°107 du 13 avril 2016, et n°186 du 1er juillet 2016).

DECISION N° 107/16/ARMP/CRD DU 13 AVRIL 2016

DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE LA CAISSE DE DEPOT ET CONSIGNATIONS (CDC) PORTANT SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PASSER PAR ENTENTE DIRECTE, LE MARCHE RELATIF A L'UTILISATION DE LA DEMARCHE ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

VU la loi no 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

VU la loi n° 2006-03 du 4 janvier 2006 portant création d'un établissement public à statut spécial dénommé « Caisse des Dépôts et Consignations » ;

VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

VU le décret no 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

VU le décret n° 2014-11212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

VU la résolution no 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP ;

VU la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en date du 24 mars 2016, reçue à l'ARMP, le lendemain ;

Monsieur Moustapha NGAIDO, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Khadijetou Dia LY, assurant l'intérim du Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assistée par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre en date du 24 mars 2016, reçue le lendemain, le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a saisi l'ARMP d'une demande d'autorisation de passer par entente directe avec l'entreprise HIRAM Finance, le marché relatif à l'utilisation de l'outil de gestion Asset and Liability Management (ALM).

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 142.3 du Code des Marchés publics, si l'autorité contractante n'accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulés par la direction chargée du contrôle des marchés publics concernant la possibilité d'utiliser une procédure autre que l'appel d'offres ouvert ou relative à la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends (CRD) près l'organe chargé de la régulation des marchés publics ;

146

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, la Commission Litiges statue sur les litiges entre les organes de l'administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public dont le CRD est saisi ;

Considérant que la saisine du CRD fait suite à l'avis négatif de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) sur la demande de la Caisse de Dépôt et Consignations (CDC), visant à obtenir l'autorisation de conclure, par entente directe avec l'entreprise HIRAM Finance, le marché relatif à la mise en place de la démarche Asset and Liability Management (ALM) ou gestion actif-passif ;

Considérant qu'une saisine du CRD dans un tel cas n'est soumis à aucune condition de délai et de forme ;

Qu'à cet égard, il convient de déclarer la saisine de la CDC recevable.

SUR LES FAITS

En vue de se doter d'une plateforme de pilotage financier, la CDC du Sénégal a pris la décision de passer un marché par entente directe pour la mise en place de la démarche Asset and Liability Management (ALM) avec l'entreprise HIRAM Finance.

Le 03 mars 2016, la CDC a saisi la DCMP d'une demande pour obtenir l'autorisation de conclure ledit marché. L'organe de contrôle a priori émet un avis négatif, le 11 mars 2016, au motif que les conditions prévues par l'article 76 du Code des Marchés publics ne sont pas remplies.

L'ARMP est saisie par lettre en date du 24 mars 2016 d'une demande d'autorisation de la CDC pour la conclusion d'un marché, par entente directe, portant sur ledit outil de gestion.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DE LA DEMANDE

Pour la CDC, le modèle de gestion économique et financier, basé sur une démarche Asset and Liability Management (ALM) ou gestion actif passif qui est proposé par la société HIRAM Finance et déjà utilisé au Gabon devrait permettre à la CDC d'assurer ses missions et la pérennité de ses ressources.

L'utilisation de la démarche ALM est d'une certaine simplicité et l'efficacité est assurée par la précision des résultats par rapport à la spécificité des CDC.

En outre, l'outil qui s'accompagne de la formation du personnel cumule les fonctionnalités d'un référentiel de gestion de la trésorerie, d'un référentiel de gestion des risques pour le pilotage des ressources et fonds propres et d'un référentiel de contrôle de gestion orienté suivi et de pilotage budgétaire.

En outre, la spécificité d'une CDC fait que l'ouverture à la concurrence de l'acquisition d'un tel outil allongerait les délais de conception et de développement et ne garantirait pas un produit aussi performant que celui proposé par HIRAM Finance.

147

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

En réponse à la saisine de la CDC, par lettre du 11 mars 2016, la DCMP fait observer que l'article 76 du Code des Marchés publics pose les conditions pour la conclusion d'un marché par entente directe.

Elle rappelle que l'initiative de la commande publique provient de l'entreprise qui a fait une proposition d'offre contrairement à la logique des marchés publics, exception faite des offres spontanées.

Elle rappelle que si l'entreprise HIRAM FINANCE est le concepteur de l'outil, il n'est pas prouvé la détention d'un droit d'exclusivité conformément aux dispositions de l'article 76 2. (b) du Code des Marchés publics et par ailleurs, le marché ne répond pas aux autres conditions fixées pour la conclusion d'un marché par entente directe. En outre, dans le domaine, il existe une concurrence accrue.

De plus, la DCMP signale qu'il existe une concurrence accrue dans ce domaine et que l'ouverture à la concurrence sur la base d'un dossier de qualité pourrait permettre de garantir l'obtention d'offres de qualité comparable.

En conclusion, la DCMP a émis un avis défavorable à la passation dudit marché par entente directe.

L'OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que la demande porte sur l'autorisation de passer, par entente directe, avec la société HIRAM FINANCE, le marché relatif à l'acquisition de l'outil de gestion ALM ou gestion actif-passif.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 26 du Code des Obligations de l'Administration (COA), l'appel d'offres ouvert constitue le mode de passation de contrats auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe ;

Que lorsque des situations particulières surviennent, il est possible de déroger au principe d'appel d'offres ouvert afin de permettre aux acheteurs publics de réaliser les commandes de biens, services et travaux ;

Qu'à cet égard, la procédure d'entente directe figure parmi les modes de passation dérogatoires auxquels les autorités contractantes peuvent recourir à la condition de se trouver dans l'une des situations limitativement énumérées par le Code des Marchés publics ;

Considérant que, par lettre du 24 mars 2016, la CDC a saisi le CRD, suite à l'avis négatif de la DCMP pour la passation par entente directe d'un marché relatif à la mise en place de la démarche Asset and Liability Management (ALM) ou gestion actif-passif avec l'entreprise HIRAM FINANCE ;

Considérant que, ni la détention d'un droit d'exclusivité par l'entreprise HIRAM FINANCE, ni l'existence de la situation d'urgence, figurant parmi les conditions de mise en œuvre de l'article 76 du Code des Marchés publics, n'ont été prouvées ;

Qu'au surplus, la transparence et l'intégrité du système de passation des marchés ne peuvent être préservées que si le taux de marchés par entente directe est réduit au strict minimum ;

Considérant, par ailleurs, que le Code des Marchés publics permet, en son article 60, l'utilisation de la procédure de l'appel d'offres ouvert pour sélectionner les candidats sur la base de critères garantissant l'ouverture à la concurrence pour des marchés d'une telle nature ;

Considérant, enfin, qu'une bonne planification aurait permis à l'autorité contractante de dérouler le processus de passation par appel d'offres et de finaliser la procédure sans être confrontée à un problème de délai, si elle avait déroulé la procédure d'acquisition de l'outil de gestion depuis plusieurs mois ;

Qu'en conséquence, Il y a lieu de rejeter la demande de conclusion, par entente directe, du marché relatif à la mise en place de la démarche Asset and Liability Management avec l'entreprise HIRAM Finance et ordonner la passation du marché par la procédure d'appel d'offres ouvert ;

PAR CES MOTIFS

- 1 Déclare recevable la saisine de la CDC ;
- 2) Dit que l'appel d'offres ouvert est la procédure de passation des marchés publics, en principe ;
- 3) Dit qu'un marché par entente directe ne peut être passé que sous certaines conditions limitatives énumérées par l'article 76 du Code des Marchés publics ;
- 4) Constate qu'aucune de ces conditions n'est remplie par le marché que la CDC veut passer avec HIRAM FINANCE ;
- 5) Dit que rien n'empêche à l'autorité contractante de passer le marché par appel d'offres ouvert ;
- 6) Rejette la demande d'autorisation de passer le marché, par entente directe, avec HIRAM FINANCE ;
- 7) Ordonne la passation du marché par la procédure appel d'offres ouvert ;
- 8) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Caisse des Dépôts et Consignations et à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhou Issa SYLLA

Pour le Directeur Général, par intérim

Rapporteur

Khadijetou Dia LY

18

**LA DÉROGATION D'OUVRIR UN
MARCHÉ A L'INTERNATIONAL
NE SE LIMITE PAS AU SEUL CAS
D'INEXISTENCE DE COMPÉTENCE
DANS L'ESPACE UEMOA**

(ARTICLE 52 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

L'article 52 du Code des marchés publics de 2014 dispose : « La participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l'article 2 du décret est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l'UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent dans les cas suivants :

Lorsque les marchés concernés ne peuvent être exécutés par les entreprises ci-dessus visées ;

Lorsque, du fait de l'envergure financière du marché et/ou de la complexité technique des travaux, fournitures ou services, la faible concurrence locale ne garantit pas une compétition transparente ou une exécution économique et diligente du marché. »

Afin de sélectionner un cabinet capable d'effectuer la mission de supervision des travaux de construction du pont à péage de Foundiougne, l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGERROUTE) sollicite de la DCMP l'autorisation d'ouvrir à l'international, l'appel à manifestation d'intérêt.

La DCMP émet un avis négatif en arguant que l'incapacité des cabinets communautaires, invoquée pour solliciter l'ouverture à l'international, doit être démontrée par une procédure de passation restée infructueuse.

Suite à l'avis de la DCMP, l'AGERROUTE saisit le CRD pour obtenir l'autorisation d'ouvrir la consultation au niveau international.

Par décision n°16 du 13 janvier 2016, le CRD autorisa l'AGERROUTE à ouvrir la manifestation d'intérêt à l'international dans les conditions prévues par l'article 52-2 du Code des marchés publics. A l'appui de sa décision le CRD fit valoir, à juste raison, qu'en motivant son avis négatif par l'absence de preuve établie sur la base d'une procédure infructueuse, la DCMP ne fait référence qu'à la dérogation prévue dans le cas où il n'existe pas de compétence dans l'espace UEMOA, alors qu'une situation marquée par une faible concurrence liée à la complexité du projet peut également justifier l'ouverture à l'international.

En effet le CRD précisa, valablement, qu'au regard de l'argumentaire basé sur la complexité de la mission attendue, l'envergure du projet et l'importance des financements à mobiliser, une consultation uniquement réservée aux candidats de l'espace UEMOA ne permet pas d'assurer une concurrence large à travers la participation de nombreux cabinets ayant l'expertise de réaliser de telles prestations.

DECISION N° 016/16/ARMP/CRD DU 13 JANVIER 2016

DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE L'AGENCE DES TRAVAUX ET DE GESTION DES ROUTES (AGERROUTE) SOLLICITANT L'AUTORISATION DE LANCER

UNE CONSULTATION AU NIVEAU INTERNATIONAL POUR LA SELECTION D'UN CONSULTANT CHARGE DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT A PEAGE DE FOUNDIOUGNE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande d'autorisation introduite par l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) par lettre du 06 janvier 2016 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 06 janvier 2016 reçue le lendemain au secrétariat du CRD sous le n°006/16, l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir à l'international, l'appel public à manifestation d'intérêt pour la sélection d'un consultant chargé de la supervision des travaux de construction du pont à péage de Foundiougne.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

Considérant que le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que la saisine du Comité de Règlement des Différends (CRD) par AGEROUTE fait suite à l'avis négatif rendu par la DCMP par lettre n°006605/MEFP/DCMP/DCV/26 du 05 décembre 2014 ;

Considérant que le Code des Marchés publics ne fixe pas, dans ce cas de figure, un délai de saisine du CRD ;

Qu'il y a lieu de déclarer la saisine d'AGEROUTE recevable, par application de l'article 22 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.

LES FAITS

Afin de sélectionner un cabinet capable d'effectuer la mission de supervision des travaux de construction du pont à péage de Foundiougne, l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) a saisi la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) par lettre du 3 décembre 2014 pour solliciter l'autorisation d'ouvrir à l'international, l'appel à manifestation d'intérêt.

En réponse, par courrier du 05 décembre 2014, la DCMP a émis un avis négatif sur la demande en arguant que l'incapacité des cabinets communautaires, invoquée pour solliciter l'ouverture à l'international, doit être démontrée par une procédure de passation restée infructueuse.

Par la suite, l'Etat du Sénégal a obtenu l'accord du Gouvernement chinois pour le financement du projet de construction, clef en main, du pont à péage de Foundiougne, après la signature d'un contrat commercial avec le groupement China Greal Wall Industry Corporation/ China Henan International Corporation Group Co.Ltd.

Compte tenu de l'avis négatif de la DCMP, AGEROUTE qui souhaite démarrer la procédure de sélection du cabinet chargé d'assurer la supervision des travaux, a saisi le CRD par lettre du 06 janvier 2016 pour obtenir l'autorisation d'ouvrir la consultation au niveau international.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DE LA DEMANDE

A l'appui de la demande, AGEROUTE invoque l'importance du projet de construction du pont pour le désenclavement du pays, son envergure et la complexité des types de contrats y afférents.

Ainsi, l'autorité contractante indique que l'ouvrage avec un linéaire de 1 300 m en béton précontraint sera le plus grand pont du Sénégal.

Selon le requérant, la réalisation du pont de Foundiougne requiert la mobilisation de montants importants. En outre, la préparation et la mise en œuvre de ce type de contrats complexes nécessitent la réunion de compétences multiples avec un haut degré d'expertise.

Poursuivant l'argumentaire, AGEROUTE précise que cinq (05) missions sont attendues du consultant, commençant par le suivi des études d'avant projet détaillé, des études d'exécution et d'adaptation pour la construction du pont jusqu'aux études de trafic, élaboration d'une matrice des risques du modèle financier, élaboration du dossier de sélection de l'opérateur privé chargé de l'exploitation de l'ouvrage.

Le requérant estime que ces prestations qui ne sont pas courantes dans la zone UEMOA seront difficiles à réaliser par les seules entreprises de l'espace communautaire.

C'est pourquoi, pour pouvoir sélectionner un consultant doté de l'expertise nécessaire et, par voie de conséquence, garantir les intérêts de l'Etat durant la gestion des futurs contrats, AGEROUTE sollicite l'autorisation d'ouvrir la consultation à l'international.

SUR LES MOTIFS DE LA DCMP

En réponse à la saisine d'AGEROUTE, la DCMP a estimé que l'incapacité des bureaux communautaires, à défaut d'être justifiée autrement, ne peut être démontrée qu'à la suite d'une manifestation d'intérêt restée infructueuse.

C'est pourquoi, après avoir rappelé qu'elle exerce un contrôle de légalité, la DCMP a indiqué qu'elle ne peut autoriser la dérogation demandée par AGEROUTE.

L'OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) souhaite obtenir l'autorisation de lancer à l'international, la manifestation d'intérêt pour la sélection d'un consultant chargé de la supervision des travaux de construction, clef en main, du pont de Foundiougne.

AU FOND

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 52 du Code des Marchés publics, la participation aux appels à la concurrence, lorsque le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes, est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité ;

Que toutefois, une dérogation à la disposition susvisée est prévue dans les cas suivants :

1. lorsque les marchés concernés ne peuvent être exécutés par les entreprises ci-dessus visées ;
2. lorsque, du fait de l'envergure financière du marché et/ou de la complexité technique des travaux, fournitures ou services, la faible concurrence locale ne garantit pas une compétition transparente ou une exécution économique et diligente du marché ;

Que dans les cas de la dérogation ci-dessus rappelée, l'accès aux marchés est autorisé aux entreprises communautaires, aux groupements réunissant des

entreprises communautaires à des entreprises non communautaires, aux entreprises non communautaires ;

Considérant qu'en motivant son avis négatif par l'absence de preuve établie sur la base d'une procédure infructueuse, la DCMP ne fait référence qu'à la dérogation prévue dans le cas où il n'existe pas de compétence dans l'espace UEMOA ; or une situation marquée par une faible concurrence liée à la complexité du projet, peut également justifier l'ouverture à l'international ;

Qu'au demeurant, il importe de relever qu'au regard de l'argumentaire basé sur la complexité de la mission attendue, l'envergure du projet et l'importance des financements à mobiliser, une consultation uniquement réservée aux candidats de l'espace UEMOA ne permet pas d'assurer une concurrence large à travers la participation de nombreux cabinets ayant l'expertise de réaliser de telles prestations ;

Que dès lors, le lancement de la procédure préalablement au niveau communautaire, en plus d'allonger les délais, ne garantit pas la transparence du fait d'un risque d'entente liée à la faible concurrence et ne donne pas l'assurance de permettre la sélection d'un consultant ayant l'expertise recherchée ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de permettre l'ouverture de la consultation à l'international afin d'améliorer la concurrence et de choisir le cabinet qui remplit au mieux les critères attendus avec le meilleur rapport qualité/coût ;

Considérant, toutefois, que l'ouverture à l'international avec la formation de groupements entre entreprises communautaires et non communautaires, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 52 du Code des Marchés publics permet aux cabinets locaux de nouer un partenariat avec des bureaux étrangers expérimentés et de bénéficier en conséquence, d'un transfert de technologies ;

Qu'à cet égard, il convient d'envisager l'ouverture à l'international en encourageant dans l'avis d'appel à manifestation d'intérêt, la formation de groupements entre bureaux étrangers et communautaires et en prévoyant une préférence au profit de tels groupements dans des conditions à définir dans la Demande de Propositions ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que les prestations attendues du consultant revêtent une complexité liée à l'envergure du projet, au type de financement et aux contrats futurs de choix d'opérateurs privés pour l'exploitation de l'ouvrage ;
- 2) Constate que l'ouvrage projeté avec le mode de gestion envisagé n'est pas courant dans l'espace communautaire ;
- 3) Dit qu'une faible concurrence au niveau local peut justifier l'ouverture d'une consultation à l'international ;
- 4) Dit, en conséquence, qu'AGEROUTE est autorisée à ouvrir la manifestation d'intérêt à l'international dans les conditions prévues par l'article 52.2 du Code des Marchés publics ;

5) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

19

**LES MARCHÉS A COMMANDE
SONT SOUMIS A L'AVIS DE LA
DCMP QUEL QUE SOIT LEUR
MONTANT**

(ARTICLE 141 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

Il résulte de l'article 141 alinéa 2 du Code des marchés publics que « les marchés qui n'ont pas atteint les seuils de revue de la Direction chargée du contrôle des marchés publics sont examinés par la cellule de passation des marchés publics de l'autorité contractante dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.»

Cependant le même article précise en son alinéa 1a que ladite Direction assure le contrôle à priori des procédures de passation des marchés et qu'à ce titre elle émet un avis sur les dossiers d'appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation concernant, notamment, les marchés à commande.

Ainsi, il résulte desdites dispositions que les marchés à commande, quel que soit leur montant, sont soumis, avant leur lancement, à l'avis préalable de la DCMP, organe chargé du contrôle a priori.

Se fondant sur ces dispositions, la DCMP a notifié à l'Unité de coordination pour la Gestion des déchets solides(UCG) sa décision de ne pouvoir procéder à l'immatriculation d'un marché à commande, que ce dernier ne lui avait pas soumis pour avis avant son lancement.

Ayant saisi le CRD d'une demande d'autorisation de poursuivre le marché, suite à la décision de refus d'immatriculer de la DCMP, le CRD estima, à juste raison, que la décision de refus d'immatriculation de l'organe de contrôle à priori est justifiée parce que l'autorité contractante a commis un manquement dans la procédure de passation du marché pour n'avoir pas soumis le dossier d'appel d'offres à l'avis préalable de l'organe chargé du contrôle à priori ; en effet, il y a eu violation des dispositions de l'alinéa 1a de l'article 141 du code des marchés publics.

Néanmoins le CRD a quand même ordonner à la DCMP d'assurer la revue du marché et de procéder à son immatriculation, si des manquements substantiels de nature à compromettre la régularité du dossier d'appel à la concurrence n'ont pas été commis ; le CRD a fait valoir que la relance d'une autre procédure pourrait causer un retard préjudiciable aux populations et à l'autorité contractante qui intervient dans un domaine sensible du service public, car le marché a pour objet l'acquisition de matériels de nettoyage et une éventuelle rupture de stocks pourrait occasionner un dysfonctionnement du service de nettoyage des espaces publics (décision du CRD n° 116 du 2 avril 2016).

DECISION N° 116/16/ARMP/CRD DU 20 AVRIL 2016

DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, SUR LA SAISINE DE L'UNITE DE COORDINATION DE LA GESTION DES DECHETS SOLIDES DU MINISTERE DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, SUITE AU REFUS DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS D'IMMATRICULER LE MARCHE RELATIF A L'ACQUISITION DE PETITS MATERIELS DE NETTOIEMENT.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

VU la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration, modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

VU le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

VU le décret n° 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation ;

VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

VU la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

VU la résolution n° 14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité de Règlement des Différends ;

VU la demande de l'Unité de Coordination pour la Gestion des Déchets Solides (UCG), suivant lettre n°000468/MGLDAT/UCG/COORD/SPM du 23 mars 2016, reçue le même jour à l'ARMP, puis enregistrée sous le n° 087au secrétariat du CRD ;

Madame Catherine Aïssata BA, Commissaire à la Cellule d'Instruction des recours, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, assisté de ses collaborateurs, observateurs ;

Adopte la présente décision :

Par lettre datée du 23 mars 2016, l'Unité de Coordination pour la Gestion des Déchets solides (UCG) du Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire a saisi le CRD du litige qui l'oppose à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), suite au rejet de sa demande d'immatriculation du marché susvisé.

A l'appui de sa saisine, l'UCG a transmis les documents suivants :

- copie de l'avis d'appel d'offres publié dans le journal « Le Soleil » du 26 octobre 2015 ;
- le dossier d'appel d'offres ;
- le procès-verbal d'ouverture des plis ;

- le rapport d'évaluation des offres ;
- le procès-verbal d'attribution provisoire ;
- un rapport de présentation et une attestation d'existence de crédits ;
- copie de la lettre n° 001218/MEFP/DCMP/86 du 17 mars 2016 ;
- copie de la publication de l'Avis d'attribution provisoire du marché paru dans le journal « Le Soleil » du 14 décembre 2015 ;
- 07 exemplaires du contrat de marché ;
- une copie de la décision n° 009/16/ARMP/CRD du 13 janvier 2016.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends de statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public ;

160

Considérant que la saisine de l'Unité de Coordination pour la Gestion des Déchets solides (UCG) du Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, en sa qualité d'autorité contractante, est consécutive au refus de la DCMP, organe de contrôle a priori de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, d'immatriculer le marché susvisé.

Que la saisine est, dès lors, recevable.

LES FAITS

L'Unité de Coordination pour la Gestion des Déchets solides (UCG) du Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire a publié dans le quotidien « Le Soleil » du 26 octobre 2015 l'avis d'appel d'offres relatif à l'acquisition de petits matériels de nettoyage. Huit (08) candidats ont présenté leurs offres à la date limite de dépôt des offres. L'ouverture des plis a eu lieu le 26 novembre 2015 à 12 heures.

Les noms des soumissionnaires et les montants suivants ont été lus à haute voix :

Soumissionnaires	Montant offres en Francs CFA TTC
Dismat	76 458 100
Groupe Delta	97 807 500
Ozesuarl	114 271 938
Wade Trading Compagny	114 961 500
Touneq International	115 701 950
Abso Trading	116 119 375
PBS	132 744 100
LNF Suarl	135 614 450

Après correction, évaluation et comparaison des offres, le marché a été provisoirement attribué à Wade Trading Compagny pour un montant de cent quatorze millions neuf cent soixante et un mille cinq cents (114 961 500) Francs CFA TTC. L'avis d'attribution provisoire a été publié dans « Le Soleil » du 14 décembre 2015 et les autres soumissionnaires ont été informés du rejet de leurs offres. Après observation du délai de recours, le marché a été souscrit le 12 janvier 2016 et approuvé le 1er mars 2016. Suite à la décision de refus de la DCMP d'immatriculer le marché, l'UCG a soumis le litige au CRD.

LES MOTIFS DEVELOPPES PAR L'UCG A L'APPUI DE SA SAISINE

161

L'UCG expose qu'elle soumet le dossier au CRD pour pouvoir poursuivre la procédure afin d'éviter une éventuelle rupture de stocks pouvant entraîner un dysfonctionnement du service public.

Elle fait observer, par ailleurs, que le marché n'a pas été soumis à la DCMP pour avis car elle estime que conformément aux dispositions de l'article 141 du Code des Marchés publics, les marchés qui n'ont pas atteint le seuil de revue sont soumis au contrôle de la cellule de passation des marchés de l'autorité contractante.

LES MOTIFS DE REJET DE LA DCMP

Selon la DCMP, l'UCG n'a pas respecté les dispositions de l'article 141alinéa 1 a) du Code des marchés publics qui prévoient que les marchés à commande, quel que soit leur montant, sont soumis, avant leur lancement, à l'avis préalable de l'organe chargé du contrôle a priori.

Compte tenu de ce manquement, elle a notifié au requérant sa décision de ne pouvoir procéder à l'immatriculation du marché et a lui suggéré de reprendre la procédure ou, à défaut, de requérir l'avis de l'ARMP.

OBJET DU LITIGE

Il ressort des faits et motifs ci-dessus développés que la saisine porte sur une demande d'autorisation de poursuivre le marché susvisé, suite à la décision de refus d'immatriculation de la DCMP.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 141 du Code des Marchés publics dispose en son alinéa 2 que les marchés qui n'ont pas atteint les seuils de revue de la Direction chargée du contrôle des marchés publics (DCMP) sont examinés par la Cellule de passation des marchés publics de l'autorité contractante, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances ;

Considérant, toutefois, que le même article précise en son alinéa 1 a) que ladite Direction assure le contrôle a priori des procédures de passation de marchés et qu'à ce titre, elle émet un avis sur les dossiers d'appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation concernant, notamment, les marchés à commande ;

Considérant, ainsi, qu'il s'infère des dispositions suscitées de l'alinéa 1 a) que les dossiers d'appel à la concurrence des marchés à commande sont soumis à l'avis de la DCMP quels que soient leurs montants estimés, même inférieurs aux seuils de revue ;

162

Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le marché litigieux est un marché à commande ;

Considérant, dès lors, que l'UCG avait l'obligation de soumettre le dossier d'appel à la concurrence du marché litigieux, à l'avis de la DCMP, avant le lancement de la procédure de passation ;

Qu'elle n'a, toutefois, pas satisfait à cette formalité et qu'elle a, de ce fait, commis un manquement dans la phase de préparation dudit marché ;

Considérant, dès lors, que la DCMP a justifié sa décision de refus d'immatriculation ;

Considérant, toutefois, que la procédure de passation a été déroulée jusqu'à la phase de l'attribution définitive ;

Qu'aucun recours n'a été enregistré au niveau du CRD ;

Considérant, en outre, que le marché a pour objet l'acquisition de matériels de nettoyage et qu'une éventuelle rupture de stocks pourrait occasionner un dysfonctionnement du service de nettoyage des espaces publics ;

Que, dès lors, pour faire l'économie d'une autre procédure qui risquerait de causer un retard préjudiciable aux populations et à l'autorité contractante qui intervient dans un domaine sensible du service public de l'Etat, il y a lieu d'ordonner à l'organe chargé du contrôle a priori d'assurer la revue, conformément aux dispositions de l'article 141 alinéa 1a) du Code des Marchés publics et, en l'absence de manquements substantiels de nature à compromettre la régularité du dossier d'appel à la concurrence, de procéder à l'immatriculation dudit marché ;

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que l'Unité de Coordination pour la Gestion des Déchets solides (UCG) du Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire a lancé le marché à commande relatif à l'acquisition de petits matériels de nettoyage ;
- 2) Constate que le dossier d'appel d'offres n'a pas été soumis à l'avis préalable de l'organe chargé du contrôle a priori ;
- 3) Dit que l'UCG a commis un manquement dans la procédure de passation du marché susvisé ;
- 4) Dit que la décision de refus d'immatriculation de la DCMP est justifiée ;
- 5) Constate, toutefois, que le marché a pour objet l'acquisition de matériels de nettoyage et qu'une éventuelle rupture de stocks pourrait occasionner un dysfonctionnement du service de nettoyage des espaces publics ;
- 6) Dit que la relance d'une autre procédure pourrait causer un retard préjudiciable aux populations et à l'autorité contractante qui intervient dans un domaine sensible du service public ;
- 7) Ordonne à l'organe chargé du contrôle a priori d'assurer la revue, conformément aux dispositions de l'article 141 alinéa 1 a) du Code des Marchés publics et, en l'absence de manquements substantiels de nature à compromettre la régularité du dossier d'appel à la concurrence, de procéder à l'immatriculation du marché ;
- 8) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier l'Unité de Coordination pour la Gestion des Déchets solides (UCG) du Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire et à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

163

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

Cheikhoulssa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

